

跨國製藥企業保障藥物近用 權利之人權責任^{*} — 演繹與規範

吳全峰^{**}

目次

壹、前言	伍、跨國製藥企業是否應負擔藥物近用權利保障之人權責任？
貳、藥物近用與健康人權	一、跨國企業在人權體系之地位
參、國家實踐藥物近用權利之困境	二、跨國製藥企業在健康人權體系之地位
一、藥物近用權利與貧窮問題之連結	三、跨國製藥企業人權責任之擴張對藥物智慧財產權體系之衝擊
二、藥物近用權利與智慧財產權之衝突	陸、重新思考跨國製藥企業與藥物近用權利之關係
三、藥物近用權利影響因子之多元	一、跨國製藥企業之直接責任 (Direct Responsibilities)
肆、跨國製藥企業與藥物近用權利之侵害	二、跨國製藥企業之人權責任定位
一、不適當之政策干預	柒、未來展望
二、不適當之藥物定價策略	
三、不適當之藥物智慧財產權保護手段	

* 投稿日：2012年6月7日；接受刊登日：2012年11月20日。〔責任校對：杜芸珮〕。

本文初稿發表於中央研究院法律學研究所主辦之「科技發展與法律規範：健康與科學之人權議題」研討會，承蒙與會者提供之指正與意見，評論人交通大學科技法律研究所王立達助理教授、臺北醫學大學醫學人文研究所楊培侃助理教授及兩位匿名審查人之費心評議，使作者得以反思並修正本論文論述不足之處，謹此特致謝忱；本文尚有若干粗疏之處，由作者自負文責。本文之完成亦要感謝研究助理許欣萍小姐及杜芸珮小姐於研究期間提供之寶貴協助。

** 中央研究院法律學研究所助研究員。

摘要

民眾藥物近用權利(the right to access medicines)之保障，近年來已受到越來越多之挑戰，包括昂貴藥物價格所形成民眾近用藥物之經濟障礙(economic burdens)、對民眾近用藥物權利之不平等對待或剝奪。而在貿易自由化與經濟全球化之發展下，這類健康人權(the right to health)之限制或侵害已非由國家所單獨造成；跨國製藥企業(transnational pharmaceutical corporations, TNPCs)藉由其迅速攀升之經濟與政治影響力，從而具備挑戰國家主權與影響全球健康事務之實力，並因此透過直接之價格制定或間接之政策遊說，而成為影響民眾藥物近用權利之重要角色。有鑑於跨國製藥企業之介入，使得單純透過規範國家保障健康人權之義務，已不足以對經濟全球化下之藥物近用權利形成充分完整之保障；因此，本文便嘗試從跨國製藥企業之人權責任出發，分析討論跨國製藥企業是否應負擔滿足民眾藥物近用權利之保障以及該保障義務之正當性基礎、具體內涵與限制，以填補在公領域(public domain)以外民眾藥物近用權利保障之空白。

關鍵詞：跨國製藥企業、健康人權、藥物近用權利、人權責任、基本健康。

Transnational Pharmaceutical Corporations' Human Rights Responsibilities for Access to Affordable Medicines: Theory and Development

*Chuan-Feng Wu**

Abstract

For decades, the lack of access to needed and affordable medicines has unduly restricted individuals' right to access medicines. The high prices charged for life-saving drugs have disproportionately burdened poor households with health expenses and imposed negative effects on individuals' health and equality of health in society at large. However, in addition to the states, transnational pharmaceutical corporations (TNPCs) also play an important role in the protection of the right to access medicines. Globalization has contributed to the increasingly central role of TNPCs and transformed governments' ability to monitor and protect human rights. In other words, TNPCs have become one of the most powerful economic and political entities in the world and have greater economic power over markets than do states. Through abusing their power of market dominance by charging excessive prices and through lobbying against the legislations that protect the right to access medicines protection, TNPCs constantly impose human rights burdens on pharmaceutical accessibility. Therefore, it is misleading to impose human rights responsibilities only on the states. Based upon the human

* Assistant Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

rights paradigm, this article reevaluates the justifications and contents of TNPC's human rights responsibilities for providing affordable medicines.

KEYWORDS: transnational pharmaceutical corporations (TNPCs), right to health, right to access medicines, human rights responsibilities, minimal health.

壹、前言

依據世界衛生組織（World Health Organization，以下簡稱WHO）之研究顯示，每年約有17億人口因無法近用(access)基本藥物(essential medicines)¹而飽受疾病、疼痛、死亡之威脅²；尤其對發展中國家及低度發展國家（least developed countries，以下簡稱LDCs）而言，昂貴之藥物價格（尤其是與健康或生命密切相關之藥物），不僅形成民眾近用健康照護之主要經濟障礙(economic burdens)，更形成跨國界的公共健康危機³。舉例而言，ARV 等愛滋病用藥之支出，便佔發展中國家整體健康支出之25%-70%，相較於已發展國家相同之藥物支出比例則僅佔約15%⁴。而在健康照護上所形成之開發中國家與已開發國家之經濟差異（尤其是藥物價格所造成之經濟負擔差異），以及後續形成之健康不均(health inequality)問題（15%之世界人口消耗掉91%之藥物生產價值）⁵，對於發展中國家民眾健康人權(the right to health)之保障便形成嚴重之威脅。因此，藥物近用不僅是民眾生命健康維持之必要且不可或缺之要件，對於健康人權之保障更有其重要性⁶。

1 所謂基本藥品係指「能滿足具優先性健康照護需要之藥物(those that satisfy the priority health care needs of the population)」；其判斷標準為有效性與安全性(efficacy and safety)、相對成本效益(relative cost-effectiveness)、品質(adequate quality)、公共衛生相關性（如社經環境、疾病分佈、藥廠之設備與庫存）等。World Health Organization, *The Selection of Essential Medicines, WHO Policy Perspectives on Medicine No. 4*, WHO Doc. WHO/EDM/2000.4, available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.2.pdf (last modified on Oct. 15, 2009). See Carmel Shalev, *Access to Essential Drugs, Human Rights and Global Justice*, in BIOETHICS IN A SMALL WORLD 93, 99 (Felix Thiele & R.E. Ashcroft eds., 2005).

2 WHO, *MEDICINES STRATEGY: COUNTRIES AT THE CORE 2004-2007*, 14 (2004).

3 ED SCHOONVELD, *THE PRICE OF GLOBAL HEALTH: DRUG PRICING STRATEGIES TO BALANCE PATIENT ACCESS AND THE FUNDING OF INNOVATION* 210-11 (2010).

4 WHO, *supra* note 2, at 14.

5 *Id.* at 15.

6 有關藥物近用在國際健康人權體系之地位與內涵，詳見吳全峰，從健康人權之角度論國際藥品智慧財產權制度之發展，收於：洪德欽編，*歐盟與美國生物科技政策*，頁589-600（2011年）。*Id.* at 15.

但民眾藥物近用權利(the right to access medicines)⁷之保障，在貿易自由化與經濟全球化之發展下，卻受到越來越多之挑戰——包括對民眾近用藥物權利之不平等對待（如健康照護體系對偏遠地區、貧窮族群之漠視）或剝奪（如遠高出一般民眾所能負擔之藥物價格）；而其中一項值得注意的議題，便是這類健康人權之挑戰，卻已非單獨由國家或世界貿易組織（World Trade Organization，以下簡稱 WTO）所造成，跨國製藥企業(transnational pharmaceutical corporations)亦透過直接之價格制定或間接之政策遊說，成為影響藥物可近性之重要角色⁸。但檢視目前平衡藥物專利權與健康人權不同典範衝突之機制，卻不難發現不論是國際智慧財產權體系或國際人權體系，規範主體多仍以傳統國際法上作為人權保障義務主體之國家為核心⁹；即令跨國製藥企業超越國界之鉅額投資與深遠之政經影響力，已被證明對健康人權之保障或侵害具有舉足輕重之影響力¹⁰，但對於跨國製藥企業是否應負擔健康人權保障之義務，卻

7 依我國藥事法第4條之定義，「藥物」一詞係同時含括「藥品」及「醫療器材」兩大分類。而在國際人權典範中所廣泛討論之「the right to access medicines」，亦被學者認定應同時包括藥品與醫療器材之近用，並在內涵上將兩者做某種程度之細分——如經濟、社會、文化權利委員會（Committee on Economic, Social and Cultural Rights，以下簡稱 CESCR）第十四號意見書(General Comment No. 14)第12段討論可利用性(availability)與可近性(accessibility)時，便以「health-care goods」泛稱同意見書第41段所指稱之藥品(medicines)與醫療器材(medical equipment)。因此，本文所討論之案例雖然大多以藥品為主，但為避免混淆，本文仍將「the right to access medicines」定義為「藥物近用權利」。U.N. Econ. & Soc. Council [ECOSOC], Comm. On Econ., Soc. & Cultural Rts. [CESCR], *General Comment No. 14: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Right to the Highest Standard of Health*, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (Aug. 11, 2000) [hereinafter CESCR General Comment 14].

8 Justice C. Nwobike, *Pharmaceutical Corporations and Access to Drugs in Developing Countries: The Way Forward*, 4 INT'L J. ON HUM. RTS. 127, 127 (2006).

9 有關國家在國際藥物智慧財產權制度下之健康人權保障義務，詳見吳全峰（註6），頁649-657。

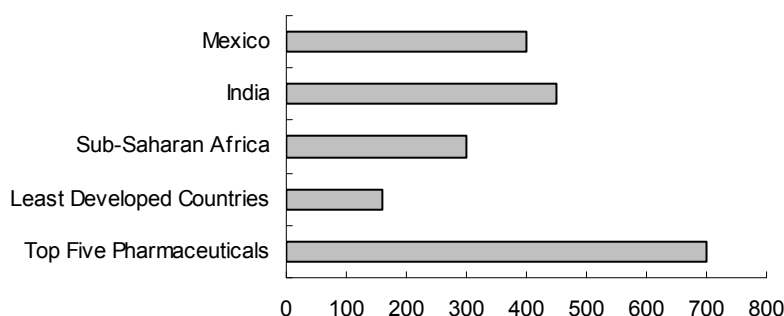
10 Paul Gordon Lauren著，徐子婷、司馬學文、楊雅婷譯，國際人權的進展，頁558（2008年）。M. E. Crow, *The Human Rights Responsibilities of Multinational Tobacco Companies*, 14 TOBACCO CONTROL ii14, ii15 (2005). Barbara Cochrane Alexander, *Lack of Access to HIV/AIDS Drugs in Developing Countries: Is There A*

仍未有相對應比重之討論與重視¹¹，並導致健康人權在國際藥物智慧財產權制度下之保障，出現無法填補之空隙與難以落實之困境¹²。

有鑑於跨國製藥企業挑戰國家主權與影響全球健康事務之實力迅速攀升——如全球前五大跨國製藥企業之市場資本額(market capitalization)總額，便已超過墨西哥或印度之經濟規模，並約為非洲南撒哈拉國家國民生產總額（gross national product，以下簡稱GNP）總和之兩倍^{13、14}——單純透過規範國家保障健康人權之義

Violation of the International Human Right to Health?, 8 HUM. RTS. BRIEF 12, 14 (2001).

- 11 See RAJAT KHOSLA & PAUL HUNT, HUMAN RIGHTS GUIDELINES FOR PHARMACEUTICAL COMPANIES IN RELATION TO ACCESS TO MEDICINES: THE SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH CONTEXT 9 (2008), available at http://www.essex.ac.uk/human_rights_centre/research/rth/docs/Final_pharma_for_website.pdf (last visited Mar. 20, 2012).
- 12 Lissett Ferreira, *Access to Affordable HIV/AIDS Drugs: The Human Rights Obligations of Multinational Pharmaceutical Corporations*, 71(3) FORDHAM L. REV. 1133, 1170 (2002). ANDREW CLAPHAM, HUMAN RIGHTS IN THE PRIVATE SPHERE 93-94 (1993).
- 13 OXFAM, CUT THE COST: PATENT INJUSTICE: HOW WORLD TRADE RULES THREATEN THE HEALTH AND POOR PEOPLE 11 (2001), available at <http://www.maketradeair.com/en/assets/english/patent.pdf> (last visited Dec. 1, 2010). 陳宜超，生技醫藥公司之投資評估研究——生物倫理與社會責任之價值，國立政治大學科技管理研究所碩士論文，頁111（2005年）。（引用英國衛報之資料）。



- 14 另以美國為例，製藥產業在2008年之獲利率為15.8%，為 Fortune 雜誌評選全美500大企業（47項產業）排行之第3位（其他產業之平均值約為5.7%；且25大企

務，顯然已不足以對經濟全球化下之藥物近用權利形成充分完整之保障¹⁵。蓋因漠視跨國製藥企業與藥物近用權利之關係，一方面（從消極之角度觀察）將忽略跨國製藥企業擁有足夠之政治與經濟實力，足以對民眾藥物近用權利形成直接或間接侵害(direct or indirect violations)¹⁶之事實；另方面（從積極之角度觀察）亦將忽略跨國製藥企業因沒有政府之負擔與限制，因此在面對傳統國家主權之主張與慣例時，擁有足夠之空間將藥物近用權利之保障帶入兼具機會與挑戰之嶄新領域¹⁷。但目前分析跨國製藥企業與藥物近用權利間關係之文獻仍屬有限，且方法論之選擇（如立基於社會責任(social responsibility)而非國際人權典範之觀點¹⁸）與責任內容之討論（如僅著重於藥物近用權利之特定面向¹⁹，或僅提供宣示性規

業中，製藥公司便佔了4家。Marcia Angell 著，曾育慧譯，藥廠黑幕，頁36（2006年）。Eleanor D. Kinney, *For Profit Enterprise in Health Care: Can It Contribute to Health Reform?*, 36 AM. J.L. & MED. 405, 423 (2010).

15 Paul Gordon Lauren 著，徐子婷、司馬學文、楊雅婷譯（註10），頁559。

16 傳統上對於跨國企業直接侵犯人權之行為——如戰爭罪(war crimes)、反人道與種族滅絕罪(crimes against humanity and genocide)——是否應負擔人權責任，學者間多持正面見解，爭論點僅侷限於行為之態樣與責任之強度；但對於間接侵犯人權之企業行為——如提供資源（包括金錢、資訊、財貨或服務）予具侵犯人權之虞之政府——跨國企業究應對其與國家等與政府共謀(complicity)之行為負擔法律義務(legal obligations)或道德責任(ethical responsibilities)，則多所爭論。但限於篇幅，相關爭議並不在本文之討論範圍。Iren Khan, *Understanding Corporate Complicity: Extending the Notion Beyond Existing Laws* 3-7, Address at the Business Human Rights Seminar (AI Index POL/34/001/2006) (Dec. 8, 2005), available at <http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL34/001/2006/en/c866d1a9-d44b-11dd-8743-d305bea2b2c7/pol340012006en.pdf> (last visited Mar. 24, 2012).

17 Paul Gordon Lauren 著，徐子婷、司馬學文、楊雅婷譯（註10），頁558。

18 See, e.g., Klaus M. Leisinger, *Corporate Responsibilities for Access to Medicines*, 85(1) J. BUS. ETHICS 1, 1-21 (2009) (published online in Novartis Foundation for Sustainable Development, DOI 10.1007/s10051-008-9944-4), available at <http://www.novartisfoundation.org/platform/apps/Publication/getfile.asp?id=612&el=2735&se=124414503&doc=184&dse=5> (last visited Feb. 26, 2011). Klaus M. Leiginger, *The Corporate Social Responsibility of the Pharmaceutical Industry: Idealism without Illusion and Realism without Resignation*, 15(4) BUS. ETHICS Q. 577, 577-94 (2005).

19 See, e.g., Sarah Joseph, *Pharmaceutical Corporations and Access to Drugs: The "Fourth Wave" of Corporate Human Rights Scrutiny*, 25 HUM. RTS. Q. 425, 425-52

範²⁰) 均有其侷限；因此，本文便嘗試從跨國製藥企業之人權責任出發²¹，分析討論跨國製藥企業是否應負擔滿足民眾藥物近用權利之保障²²，以及該保障義務之正當性基礎、具體內涵與限制，以填

(2005). Chuan-Feng Wu, *Transnational Pharmaceutical Corporations' Legal and Moral Human Rights Responsibilities*, 7 AJWH 77, 118-19 (2012). Ferreira, *supra* note 12, at 1133-79.

²⁰ See, e.g., KHOSLA & HUNT, *supra* note 11, at 1-23.

²¹ 要注意者為，本文並不討論跨國製藥企業是否具有國際人格此一爭議問題。蓋多數國際法學者雖然肯認跨國公司(transnational corporations, TNCs)深遠之政經影響力，但對於其是否僅具特定國家之國民身分(nationals)並應服膺地主國法律，亦或具備國際人格之實體，則未有定見。但姑且不論跨國企業之國際人格議題，多數學者均同意，在目前國際貿易體系下，跨國公司掌握相當比例之投資金額與商業活動，有必要將國際法之管制範圍擴充，重新規範國家在面臨管制跨國公司時所面臨之超國界權利與義務問題（如管轄權之界定）；亦應將跨國企業納入國際典範(international norms)之形成過程中（如在國際會議中邀請跨國公司以觀察員或專家身分參與討論）。同時，跨國企業之責任（accountability，包括人權責任）亦一再被提及，主要原因在於跨國企業既然有能力對於分散於世界各地之商業活動採取同一標準管理，則實在並無理由允許其隱藏於不同國家之管轄權(jurisdiction)後，以虛幻之不同（而非單一）法人人格要求於不同國家負擔不同之責任標準，迴避其應盡之全球義務(global responsibilities)。因此，跨國製藥企業之人權責任內涵，並不會因其國際人格之爭議而有所減損。姜皇池，國際公法導論，2版，頁390（2008年）。LORI F. DAMROSCH ET AL., INTERNATIONAL LAW: CASES AND MATERIALS 424-25 (2001). Sol Picciotto, *Introduction: What Rules for the World's Economy?*, in REGULATING INTERNATIONAL BUSINESS: BEYOND LIBERALIZATION 1, 6-7 (Sol Picciotto & Ruth Mayne eds., 1999).

²² 在此需先釐清者為，本文對跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任，立場究係採民眾有給付請求權之給付義務？還是國家基於國際人權法課予之保護義務，所立法課予跨國製藥企業之相關法律義務？抑或跨國製藥企業基於國際人權法所負擔之社會義務？（1）首先，本文並不主張民眾有直接請求跨國製藥企業為給付之權利。其理由不僅係因國家仍屬人權責任之主要負擔者，故不宜混淆國家與企業之責任；且因跨國製藥企業對股東負責，若強制要求其犧牲利潤並無償（或低價）供應藥物，則對市場體系之運作將形成負面影響（詳見第陸、二之說明）。（2）另，國家雖然基於國際人權法課與其保障人民藥物近用權利之保護義務，而具有間接義務(indirect responsibilities)規範跨國製藥企業相關法律義務，以達成藥物近用權利保障之目的。但國家在跨國製藥企業之壓力下仍有可能對於相關法律之制定或執行採取不作為之消極態度（詳見第參之說明）。雖然民眾仍可要求國家履行其人權保障之義務；但此時若對於造成國家保障藥物近用權利困境之跨國製藥企業，不能要求其負擔直接之人權責任(direct responsibilities)，便可能形成藥物近用權利保障架構之漏洞（詳見第陸、一之說明）。（3）因此，本文僅強調當國家採行必要措施促進藥物近用時（如強制授權），跨國製藥企業基於國際人權法應負擔直接人權責任，包括對其營

補在公領域(public domain)以外民眾藥物近用權利保障之空白。

貳、藥物近用與健康人權

國際人權與健康事務(health affairs, 包括健康與健康照護)間之密切關聯性,在許多國際人權文獻中已有具體之規範與實踐,亦成為國際人權法上重要之內容;如世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights, 以下簡稱 UDHR)第25條、世界衛生組織憲章(Constitution of the World Health Organization, 以下簡稱 WHO 憲章)前言、經濟、社會、文化權利國際公約(International Covenant on Economic, Social and Culture, 以下簡稱 ICESCR)第12條、消除對婦女一切形式歧視公約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 以下簡稱 CEDAW)第12條、兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child, 以下簡稱 CRC)第24條、殘疾人權利公約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 以下簡稱 CRPD)第25條等。而健康人權內涵經不同國際文件之擴充,亦從傳統受益權(positive rights)中之物質性給付與服務(泛指民眾有獲得充分之保健服務與醫療照護之權利,以保障可達到最高水準之健康狀態²³與符合人性尊嚴之生活),加入防禦權(negative rights)與程序性權利(rights to due process)之概念²⁴——如經濟、社會、文化權利委員會(Committee

業自由與財產權宜有所限縮,以確保民眾近用維持基本健康所必要之藥物(如不能任意杯葛或反對強制授權、平行輸入、藥價折扣等措施,詳見第陸、二、(三)之說明)。而這類人權責任之實踐,並不要求國家行為之參與,即可直接要求跨國製藥企業負擔藥物近用保障之人權責任。

23 依據 WHO 憲章前言,健康之定義為「生理、心理、社會之完適狀態」而非單指疾病之排除(health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity)。

24 S. P. Stich, *The Many Rights to Health and Health Care, in* RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN MODERN MEDICINE 15, 15-31 (M. D. Basson ed., 1981). UNITED

on Economic, Social and Cultural Rights，以下簡稱 CESCR）第十四號意見書(General Comment No. 14)第8段便規範民眾有要求保障其健康狀態有自主決定且不受干預、侵害之權利²⁵，以及第43(f)段主張保障民眾參與醫療政策制定之權利²⁶。

而在健康人權之廣泛內容中²⁷，多數學者均同意藥物近用權利(the right to access medicines)實為健康人權之重要內涵^{28、29}；蓋若缺

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2000, 93 (2000).

- 25 Paragraph 8 of the CESCR General Comment No. 14, “The right to health is not to be understood as a right to be *healthy*. The right to health contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation. By contrast, the entitlements include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health.”
- 26 Paragraph 43(f) of the CESCR General Comment No. 14, “To adopt and implement a national public health strategy and plan of action, on the basis of epidemiological evidence, addressing the health concerns of the whole population; the strategy and plan of action shall be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; they shall include methods, such as right to health indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all vulnerable or marginalized groups.”
- 27 健康人權之具體內涵可參見吳全峰、黃文鴻，論醫療人權之發展與權利體系，月旦法學，148期，頁140-156（2007年）。
- 28 Ferreira, *supra* note 12, at 1159-72. KHOSLA & HUNT, *supra* note 11, at 2. Molly Beutz Land, *Protecting Rights Online*, 34 YALE J. INT’L L. 1, 15 (2009). Stephen P. Marks, *Access to Essential Medicines as a Component of the Right to Health*, in REALIZING THE RIGHT TO HEALTH 80, 86-94 (Andrew Claphan & Mary Robinson eds., 2009). Holger P. Hestermeyer, *Access to Medication as a Human Right*, 8(1) MAX PLANCK Y.B. U.N. L. 101, 125-44 (2004).
- 29 亦有學者依據 ICESCR 第15(1)(b)條規定，主張藥品作為科學進步及應用所產生之利益，民眾依據 ICESCR 第15(1)(b)條有關享受科學、文學與藝術所產生之精神與物質利益之權利保障之規定，自應享有近用之權利；且依據 CESCR General Comment No. 17第4段之規定，該條項所保障民眾享受科學進步之權利，應足以與 ICESCR 第15(1)(c)條所保障之藥物智慧財產權相互抗衡。Article 15 of the ICESCR, “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific

乏適當之藥物供給或合理之近用環境，則健康人權所重視之核心要素(essential elements)，包括減低死胎率和嬰兒死亡率（ICESCR 第12(2)(a)條）、預防治療和控制傳染病（ICESCR 第12(2)(c)條）、提供基本藥物³⁰（CESCR General Comment No. 14第43(d)段）、主要傳染病之疫苗接種（CESCR General Comment No. 14第44(b)段），均無具體實現之可能性，更不可能達成 ICESCR 第12(1)條所強調保障民眾「享有可達到之最高之生理與心理健康之標準(the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health)」³¹。因此，CESCR General Comment No. 14第12段及第43段便主張，國家所應負擔之核心義務(core obligations)，應包括在不

progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.” Paragraph 4 of the CESCR General Comment No. 17, “The right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one’s scientific, literary and artistic productions seeks to encourage the active contribution of creators to the arts and sciences and to the progress of society as a whole. As such, it is intrinsically linked to the other rights recognized in article 15 of the Covenant, i.e. ... the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications (art. 15, para. 1 (b))” U.N. ECOSOC CESCR, *General Comment No. 17: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from Any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author*, U.N. Doc. E/C.12/GC/17 (Jan. 12, 2006) [hereinafter *CESCR General Comment 17*]. Marks, *supra* note 28, at 87-88. 吳全峰（註6），頁591。

30 所謂基本藥物係指「能滿足具優先性健康照護需要之藥物（those that satisfy the priority health care needs of the population）」。Carmel Shalev, *Access to Essential Drugs, Human Rights and Global Justice*, 24 ETHICS OF SCI. & TECH. ASSESSMENT 93, 99 (2005).

31 吳全峰（註6），頁589-590。舉例而言，對急性傳染病之積極有效治療需要抗生素(antibiotics)、對黴菌感染之治療需要抗黴菌藥(antifungal agents)、對病毒感染（如 AIDS）之治療需要抗病毒藥(antiviral agents)或干擾素(interferons)；且醫師在條件許可下未能提供一般醫學知識同意具備療效之藥物，亦可能因違反注意義務而構成醫療過失(malpractice)——如某項藥物為治療特定疾病之唯一可適用之治療方法時，醫師若棄置不用便有顯著疏失。因此，若缺乏對藥物近用之確保，則對相關疾病之治療將形成極大之障礙。曾淑瑜，*醫療倫理與法律*15講，頁107（2010年）。

歧視之基礎上提供數量充分（即可利用性，availability）³²且可近用（即物質上、經濟上、資訊上之可近性，accessibility）³³之基本藥物，以保障民眾具體實現健康人權之權利³⁴；第35段則更進一步強調國家應負擔管制藥物行銷販售之義務，以確保民眾近用藥物之權利不受到第三人之干預或限制³⁵。聯合國（United Nations，以下簡稱 UN）及相關組織亦已作成多項決議，確認藥物近用為健康人權之重要元素(fundamental element)——如人權委員會(Commission on Human Rights)第2001/33號決議³⁶、經濟社會理事會(Economic

³² Paragraph 12(a) of the CESCR General Comment No. 14, “[F]unctioning public health and health-care facilities, goods and services, as well as programmes, have to be available in sufficient quantity within the State party. ... They will include ... essential drugs, as defined by the WHO Action Programme on Essential Drugs.”

³³ Paragraph 12(b) of the CESCR General Comment No. 14, “Health facilities, goods and services have to be accessible to everyone without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has [some] overlapping dimensions: ... Physical accessibility: health facilities, goods and services must be within safe physical reach for all sections of the population, especially vulnerable or marginalized groups Economic accessibility (affordability): health facilities, goods and services must be affordable for all. ...”

³⁴ Paragraph 43 of the CESCR General Comment No. 14, “... these core obligations include at least the following obligations: (a) To ensure the right of access to health facilities, goods and services on a non-discriminatory basis, especially for vulnerable or marginalized groups; ... (d) To provide essential drugs, as from time to time defined under the WHO Action Programme on Essential Drugs; (e) To ensure equitable distribution of all health facilities, goods and services;”

³⁵ Paragraph 35 of the CESCR General Comment No. 14, “Obligations to *protect* include ... the duties of States ... to control the marketing of medical equipment and medicines by third parties...also ensure that third parties do not limit people’s access to health-related information and services.”

³⁶ Paragraph 1 of the U.N. High Commissioner for Human Rights resolution 2001/33, Access to Medication in the Context of Pandemics such as HIV/AIDS, “[t]he Commission on Human Rights... [r]ecognizes that access to medication ... is one fundamental element for achieving progressively the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.” U.N. High Commissioner for Human Rights, *Access to Medication in the Context of Pandemics such as HIV/AIDS*, para. 1, U.N. Doc. E/CN.4/RES/2001/33 (Apr. 20, 2001), available at http://www.temple.edu/lawschool/drwilttext/docs/UN%20Commission%20on%20Human%20Rights%20Res%202001_22.pdf (last visited

and Social Council)下之人權保障及促進次級委員會(Sub-Commission on the Protection and Promotion of Human Rights)第2001/21號決議³⁷、聯合國千年發展目標(Millennium Development Goals, 以下簡稱 MDGs)³⁸、關於 HIV/AIDS 問題承諾宣言(Declaration of

Nov. 8, 2010). See also Commission on Human Rights resolution 2003/29, 2004/36 and 2005/23.

37 Preamble of the U.N. Sub-Commission on Human Rights resolution 2001/21, Intellectual Property and Human Rights, “[w]elcoming Commission on Human Rights resolution 2001/33 of 20 Apr. 2001 on access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS.” 另，該決議第2段亦主張承認聯合國人權事務高級專員有關智慧財產權對人權之影響報告(“welcomes the report of the High Commissioner on the impact of the TRIPS Agreement on human rights (E/CN.4/Sub.2/2001/13)”)，而該報告中便直接承認國家有義務保障民眾之藥品近用。(Paragraph 32 of the report of the High Commissioner on the impact of the TRIPS Agreement on human rights, “[s]tates are bound to promote the right to health through the ensuring access to affordable treatments.” Paragraph 30 of the report also argues that, “[t]he following summary of the General Comment [No. 14] extracts those elements most relevant to a discussion of [ICESCR] article 15 in the context of health. Of particular relevance are references to: the promotion of research; access to affordable treatments, in particular essential drugs; HIV/AIDS; national measures for the promotion of the right to health; clarification of international obligations; and acts that constitute violations of the right to health.” Intellectual Property and Human Rights, C.H.R. Res 2001/21, para. 2 (Aug. 16, 2001), available at [http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.SUB.2.RES.2001.21.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.2001.21.En?Opendocument) (last visited Apr. 9, 2012). U.N. Comm’n on Hum. Rts., Sub-Comm’n on the Promotion & Protection of Hum. Rts., *Report of the High Commissioner: Impact of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on Human Rights*, paras. 30, 32, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/13 (June 27, 2001), available at [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/590516104e92e87bc1256aa8004a8191/\\$FILE/GO114345.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/590516104e92e87bc1256aa8004a8191/$FILE/GO114345.pdf) (last visited Apr. 9, 2012).

38 2000年9月，191個會員國政府領導人，就消除世界貧窮、飢餓、疾病、文盲、環境惡化、及婦女歧視等重要國際社會關心議題發表聯合國千年宣言(Millennium Declaration)，商定一套有時限且能計量成果的工作發展目標；而這些目標被置於全球事務的核心地位，並統稱為「聯合國千禧年發展目標」(UN Millennium Development Goals, 以下簡稱MDG)。而千年宣言第19段(MDG第6點)便強調國家應面對AIDS、瘧疾、其他疾病之挑戰，並進一步遏止HIV病毒之蔓延趨勢及瘧疾與其他主要疾病之發生率與盛行率；而具體之實踐方式，除對弱勢族群(vulnerable populations, 如婦女、孩童、老人)之充權(empowerment)外，國家亦應投入適當資源以確保民眾近用特定健康照護(如緊急產科照護、基本藥品)之機會。另，依據UN千年發展目標差距問題工

Commitment on HIV/AIDS)³⁹等。

再就健康人權保障之實務發展來看，雖然許多國家之憲法已明文規範健康人權之保障，但多數並未將藥物近用權利予以明文特定⁴⁰；因此，為避免健康人權實踐上之落差，不難發現各國法院在相關判決與政策（如國家藥物政策（national medicines policy，以下簡稱 NMP））⁴¹中，均嘗試在廣義健康人權之架構下對藥物近用權利之內涵給予實質保障。舉例而言，南非憲法(South Africa Final Constitution)第27(1)(a)條雖然對於健康人權有所規範⁴²，但其條文

作小組2008年報告(MDG Gap Task Force Report 2008)，健康應為國家憲法所應保障之基本權利，而近用健康照護（包括近用基本藥品）則是實踐健康人權之必要前提要件(prerequisite)（“... the national constitutions define the fundamental political principles of a country and usually guarantee certain rights to their people. Health is a fundamental human right recognized in at least 135 national constitutions. Access to health care, including access to essential medicines, is a prerequisite for realizing that right.”）。Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, at para. 19, U.N. Doc. A/55/L.2 (Sept. 18, 2000). UNITED NATIONS MILLENNIUM PROJECT, INVESTING IN DEVELOPMENT: A PRACTICAL PLAN TO ACHIEVE THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS xviii, 79-81 (2005), available at <http://www.unmillenniumproject.org/documents/MainReportComplete-lowres.pdf> (last visited Mar. 29, 2012). U.N., MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL 8: DELIVERING ON THE GLOBAL PARTNERSHIP FOR ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS: MDG GAP TASK FORCE REPORT 2008, 42 (2008), available at <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a54bbf1d.html> (last visited Mar. 25, 2012).

³⁹ Paragraph 15 of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS, “Recognizing that access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS is one of the fundamental elements to achieve progressively the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.” *Declaration of Commitment on HIV/AIDS*, at para. 1, U.N. Doc. A/RES/S-26/2 (June 27, 2001), available at http://data.unaids.org/publications/irc-pub03/aidsdeclaration_en.pdf (last visited Apr. 9, 2012).

⁴⁰ 依據MDG Gap Task Force Report 2008，雖然用藥物近用為健康人權實踐之必要要件，但目前卻仍僅有5個國家在其憲法內明確地承認國家有保障民眾藥物近用權利之義務。U.N., *supra* note 38.

⁴¹ 所謂國家藥物政策，依 WHO 之定義，係指由國家與各部門針對醫藥物協商後所確定之中長期目標、專先專案與實施方法，為政府對公眾之承諾，亦為醫療界協調之準則。WHO, PROGRESS IN ESSENTIAL DRUGS AND MEDICINES POLICY 1998-1999, 9-10 (1999).

⁴² 南非憲法第27(1)(a)條規定，「每個人均有權利近用健康照護服務，包括生育健

中並未明文特定出藥物近用為健康人權之重要內涵，不過在 Minister of Health v. Treatment Action Campaign 乙案中⁴³，憲法法院主張國家有義務在合理可利用之資源範圍內，最大程度滿足民眾近用 HIV/AIDS 藥品(Nevirapine)之權利⁴⁴；在 Minister of Health v. New Clicks South Africa (Pty) Ltd.乙案中，憲法法院則進一步超越既有之南非憲法架構，確認藥物近用為憲法所保障健康人權之重要成分⁴⁵，且因「過高之藥物價格…將形成對民眾近用健康照護權利之直接限制與侵害(prohibitive pricing of medicines ... would in effect equate to a denial of the right of access to health care)」⁴⁶，提供可負擔之藥物供民眾使用應視為政府應盡之義務；南非競爭委員會(Competition Commission of South Africa)在 Hazel Tau v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim 案中亦再度確認近用健康照護服務為健康人權之重要要素，並應受憲法所保障(constitutionally protected right to access to health care services)⁴⁷。委內瑞拉最高法院在 Cruz Bermúdez v. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 乙案中亦確認健康人權之

康照護服務(Everyone has the right to have access to —(a) health care services, including reproductive health care.)」。

43 南非憲法法院認為在藥廠已提供公立醫院低價Nevirapine（防止愛滋病垂直感染之藥品）之前提下（意謂全面性提供Nevirapine 並不會造成竭盡國家資源之後果），公立醫院若仍僅在特定少數公立醫院提供Nevirapine，而拒絕全面性地在所有公立醫療機構（包括公立研究機構）提供罹患AIDS/HIV孕婦適當藥品以防止垂直感染，將屬侵害民眾健康人權之違憲行為。Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others 2002 (10) BCLR 1033 (CC) at para. 122 (S. Afr.). 吳全峰（註6），頁597。

44 Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others 2002 (10) BCLR 1033 (CC) at para. 135 (S. Afr.).

45 Minister of Health & Professor D. McIntyre No v. New Clicks South Africa (Pty) Ltd. & Others, 2006 (2) SA 311 (CC), at paras. 514, 704 (S. Afr.).

46 Minister of Health & Professor D. McIntyre No v. New Clicks South Africa (Pty) Ltd. & Others, 2006 (2) SA 311 (CC), at paras. 659, 706.

47 Statement of Complaint in Terms of Section 49B(2)(b) of the Competition Act 89 of 1998, Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at para. 60.5, available at <http://www.section27.org.za/wp-content/uploads/2010/10/TauvGSKEvidenceAndLegalSubmissions.pdf> (last visited Nov. 25, 2010).

內涵應包括近用 HIV/AIDS 藥品（泛指所有抗反轉錄病毒藥物治療 (antiretroviral therapies)）之權利⁴⁸。在美國，雖然學界及實務界對於健康照護是否為憲法上可得主張之權利仍然多所爭論⁴⁹，但如在 *Youngberg v. Romeo*⁵⁰、*Estelle v. Gamble*⁵¹、*Horizon Health Center v. Felicissimo*⁵²、*Right to Choose v. Byrne*⁵³等案中，即令法院確認不存在藥物近用之憲法權利⁵⁴，仍主張確保民眾得以近用健康照護（包括藥物）為政府之「重要利益」(significant government interest)⁵⁵，遂使得藥物近用之實質內涵仍受到相關實體醫療衛生法規範之保障⁵⁶。

48 Cruz Bermudez et al. v. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Case No. 15.789, Decision No. 916 (1999) (Venez.). Mary Ann Torres, *The Human Right to Health, National Courts, and Access to HIV/AIDS Treatment: A Case Study from Venezuela*, 3 CHI. J. INT'L L. 105, 112 (2002). Noah Novogrodsky, *The Duty of Treatment: Human Rights and The HIV/AIDS Pandemic*, 12 YALE HUM. RTS. & DEV. L.J. 1, 27-28 (2009).

49 詳細討論可參考吳全峰（註6），頁639。Kenneth R. Wing, *The Right to Health Care in United States*, 2 ANNALS HEALTH L. 161, 163 (1993). Carolynne Shinn, *The Right to the Highest Attainable Standard of Health: Public Health's Opportunity to Reframe a Human Rights Debate in the United States*, 4(1) HEALTH & HUM. RTS. 114, 115 (2000).

50 在 *Youngberg v. Romeo* 乙案中，法院承認政府應有義務(the affirmative responsibility)提供非自願住院隔離之精神病患者適當之健康照護服務與醫療設備。*Youngberg v. Romeo*, 457 U.S. 307 (1982).

51 在 *Estelle v. Gamble* 乙案中，法院肯認在監犯人應有有限度之憲法上權利要求政府為一定健康照護服務之給付(a limited constitutional right to medical treatment)。*Estelle v. Gamble*, 429 U.S. 97 (1976).

52 在 *Horizon Health Center v. Felicissimo* 乙案中，法院承認健康之維護在紐澤西州憲法中雖非法定權利，但仍應享有優先滿足之地位(a high priority to the preservation of health)，國家亦因此有「顯著利益(significant interest)」確保民眾健康照護近用上不受到任意之限制。*Horizon Health Center v. Felicissimo*, 638 A.2d 1260, 1269 (N.J. 1994).

53 在 *Right to Choose v. Byrne* 乙案中，政府或保險人並不能任意限制民眾近用（或選擇）特定健康照護之權利。*Right to Choose v. Byrne*, 450 A.2d 925, 936-37 (N. J. 1982).

54 See, e.g., *Abigail Alliance for Better Access to Developmental Drugs v. Von Eschenbach*, 495 F.3d 695, 697 (D.C. Cir. 2007) (holding that there is no constitutional right to access experimental drugs).

55 *Horizon Health Center v. Felicissimo*, 638 A.2d 1260, 1269 (N. J. 1994).

56 需要說明者為，在前述案例中，保障之主體僅限監所犯人與精神病患者（而

而藥物近用權利在國際人權體系下實質內涵，依前述 CESCR General Comment No.14第12段宣示，應包括可利用性(availability)與可近用性(accessibility)；而該權利是否受到限制之具體判斷標準，則包括不歧視(non-discrimination)⁵⁷、實體可近性(physical accessibility)⁵⁸、經濟可近性(economic accessibility / economic affordability)⁵⁹。WHO 依據該標準，便進一步提出之藥物近用模型(access framework)⁶⁰，並點出影響藥物近用之四大要素包括（見圖

不及於一般民眾)；且保障之權利雖包括近用醫療照護之權利(the right to medical treatment)與獲得適當生活及衛生條件之權利(the right to sanitary and healthy conditions)，但法院判決之基礎卻係援引美國憲法第八修正案有關禁止酷刑之規定(“[e]xcessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted”)。惟，判決內容雖然與國際人權法中藥物近用權利保障之內涵不盡相同，但仍有學者據此主張，類似判決應可作為美國健康人權發展之基礎。Kenneth R. Wing, *The Right to Health Care in the United States*, 2 ANNALS HEALTH L. 161, 163 (1993). William P. Gunnar, *The Fundamental Law That Shapes the United States Health Care System: Is Universal Health Care Realistic Within the Established Paradigm?*, 15 ANNALS HEALTH L. 151, 173-74 (2006).

57 Paragraph 12(b) of the CESCR General Comment No. 14, “... Non-discrimination: health facilities, goods and services must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds. ...”

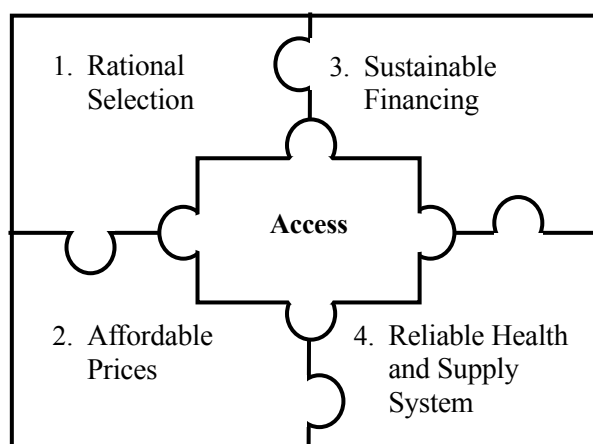
58 Paragraph 12(b) of the CESCR General Comment No. 14, “... Physical accessibility: health facilities, goods and services must be within safe physical reach for all sections of the population, especially vulnerable or marginalized groups, such as ethnic minorities and indigenous populations, women, children, adolescents, older persons, persons with disabilities and persons with HIV/AIDS. Accessibility also implies that medical services and underlying determinants of health, such as safe and potable water and adequate sanitation facilities, are within safe physical reach, including in rural areas. Accessibility further includes adequate access to buildings for persons with disabilities. ...”

59 Paragraph 12(b) of the CESCR General Comment No. 14, “...Economic accessibility (affordability): health facilities, goods and services must be affordable for all. Payment for health-care services, as well as services related to the underlying determinants of health, has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with health expenses as compared to richer households. ...”

60 WHO, *Equitable Access to Essential Medicines: A Framework for Collective Action*,

一)：合理之選擇與使用(rational selection)、可負擔之藥物價格(affordable prices)、穩定之財務系統(sustainable financing)、可信賴之健康照護體系與藥物供應系統(reliable health and supply system)。

圖一 藥物近用之要素(Access Framework)



1. 合理之選擇與使用：指國家需負擔確保藥物品質與合理使用之義務，包括在基本藥物清單(national lists of essential medicines)之選擇與利用、國家治療指引(national treatment guidelines)之制定，均應立基於理性做出合理之判斷。舉例而言，資源有限必然導致國家無法滿足民眾所有之健康需要，且有必要將不同之治療方式與藥物進行優先排序；但在健康照護資源之分配過程中，國家應避免恣意排序，而必須依據臨床決定、專業訓練、品質確信(quality assurance)及藥物之效果與預後等做出理性之政策決定⁶¹。但要注意者，在基本藥物清單之選擇上，除堅實之科學證據外，亦不應僅以經濟利益之追求與成本效益分

8 WHO POL'Y PERSP. ON MED. 2 (2004), available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.4.pdf (last visited Dec. 14, 2010).

⁶¹ *Id.* at 3.

析 (cost and benefit analysis, 簡稱 CBA) 作為決定發展、選定、給付 (或捐贈) 基本藥物之基礎; 除效益主義(utilitarianism) 外, 亦應考慮如何將成本或效益所不易量化之人性尊嚴納入分析, 並廣泛地建立一套兼顧社會結構、文化、純粹理性等不同價值觀之體系, 以作為發展基本藥物清單之基礎。

2. 可負擔之藥物價格: 指適當之藥物定價策略, 亦即在藥物價格之訂定上, 除尊重自由市場競爭與 WTO 「與貿易有關之智慧財產權協定」 (Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights, 以下簡稱 TRIPS 協定)⁶²之規範 (亦即對專利藥廠市場獨占權之尊重) 外, 亦應避免專利藥廠濫用市場獨占 (monopoly) 之地位, 訂定不合理之高額藥物價格 (excessive drug prices)⁶³, 以及重視資訊之公開透明。詳言之, 除藥物研發之適當報酬及鼓勵製藥企業投入高風險藥物研發之經濟誘因外, 非經濟之因素——如對消費者生命與健康之負面影響、對國際健康人權之限縮等——均應納入藥物定價策略之考量範圍⁶⁴。另一方面, 因國家亦負擔保障健康人權不受第三人之任意干預之義務, 故國家應排除影響藥物價格或供給 (作為藥物近用之重要指標) 之負面因素⁶⁵; 如藥物市場之特殊性所造成資訊不對等 (information asymmetry), 對合理市場之價格競爭可能產生不利影響, 故在不影響營業秘密之前提下, 國家應建立透明之藥價審核機制, 並確保藥物定價資訊適度公開, 以確保藥物之可利用性與可近性。更進一步, 若民眾健康人權可能因不合

⁶² Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, available at http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (last visited Nov. 5, 2010).

⁶³ *Id.*

⁶⁴ See generally Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at para. 47.

⁶⁵ 吳全峰 (註6), 頁592。

理之昂貴藥價而受到嚴重侵害之可能性下，政府亦應適度介入市場，並以價格控制(price control)之手段確保民眾近用藥物權利⁶⁶。

3. 穩定之財務系統：主要指完善藥物財政政策之建立，亦即政府部門有義務建立適當之藥物財政政策，且除建立穩定之公共預算以支應健康照護支出外，亦應透過經濟支持以發展醫療保險（包括公共保險、小規模社區保險、私人保險）及社會救助等事業，以減少民眾對藥物之自費負擔(out-of-pocket)⁶⁷。
4. 可信賴之健康照護體系與藥物供應系統：不論廣義之健康照護體系(health care system)或狹義之藥物供應系統(medicines supply system)，若產生效率不彰之情形（如公共藥物供應系統未及於偏遠地區），均將對民眾之藥物近用產生直接之影響；且研究亦發現，適當之健康照護體系將有效阻止不適當之用藥行為（如使用過期或劣質藥物，或僅服用部分劑量）⁶⁸。因此，健康照護體系之設計與執行，應將藥物可近性納入整體之考量，除定期監督藥物供應之數量與品質外，並應整合公共體系、私有企業、非政府組織之資源，以極大化藥物供應系統之範圍⁶⁹。而藥物供應系統所應考量者，亦不應僅限於末端之藥

⁶⁶ See, e.g., Minister of Health & Professor D. McIntyre No v. New Clicks South Africa (Pty) Ltd. & Others 2006 (2) SA 311 (CC) (S. Afr.).

⁶⁷ 民眾自費負擔之增加往往被視為政府配置健康照護資源上之效率不彰，以及對民眾藥物近用之主要障礙。WHO, *supra* note 60, at 4.

⁶⁸ U.N., MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL 8: THE GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT: TIME TO DELIVER: MDG GAP TASK FORCE REPORT 2011, 55-56 (2011), available at http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2011/mdg8report2011_engw.pdf (last visited Apr. 21, 2012).

⁶⁹ 於許多非洲國家，因資源之極度缺乏與公共建設之不足，往往導致即使有足夠之藥物供應，亦無法透過政府體系將藥物送至偏遠且亟需該藥物之地區；因此，便有學者主張不妨利用可口可樂或聯邦快遞等私人體系之物流系統，將藥物送至政府資源所無法照護之偏遠地區。Unite for Sight, Learning From Coca Cola: The Science of Healthcare Delivery, available at <http://www.uniteforsight.org/>

物銷售，而應整體考量從藥物生產至消費者使用之完整生產鏈過程，以確保單位藥物量所需費用之合理性、藥物供應商之適格性(competence)、藥物供應之及時性等⁷⁰。

由前述分析不難發現，藥物近用權利之內涵並不僅限於藥物之價格因素（經濟可近性），尚重視藥物之品質與數量、資源配置之合理性與平等性等要素。蓋前者固然可能嚴重剝奪開發中國家經濟上弱勢族群追求其他社會財貨(social goods)或基本需要之能力⁷¹（高昂之藥物價格往往佔家戶所得之25-70%⁷²），但價格並非藥物近用之唯一障礙；WHO 在推動國家藥物政策時便強調，政府應針對依藥物訂定中長期目標、政策執行之優先順序與實施方法，並透過適當之立法程序以促進整合政府與製藥產業之合作，以達到支持公共健康需要之目的⁷³。

在細緻化之藥物近用概念下，國家尊重、保障、實踐(respect, protect, fulfill)藥物近用權利之義務便得以具體呈現並加以評估⁷⁴——亦即不健全健康照護體系財務規劃(inadequate financing for health)、不適當之資源優先配置(poor priority setting)、不當之藥物處方(inappropriate drug selection)、不充分之健康照護體系(weak health and supply system)，均足以構成國家對健康人權義務保障之侵害(violations)。舉例而言，WHO 在推動國家藥物政策時便強

global-health-university/science-of-healthcare-delivery (last visited Dec. 3, 2010).

70 謝季峰，WTO 智慧財產權規範與藥物可近性的研究——探討藥物專利保護政策與公共衛生的平衡點，國立陽明大學衛生福利研究所碩士論文，頁55（2003年）。

71 研究便發現，每年約有總人口數約5%之越南人，因高昂之藥價負擔而落入貧窮線以下。SAMUEL S. LIEBERMAN & ADAM WAGSTAFF, HEALTH FINANCING AND DELIVERY IN VIETNAM: LOOKING FORWARD 56-60 (2009).

72 WHO, *supra* note 2, at 14.

73 *Id.* at 27. WHO, *supra* note 41, at 5-6.

74 Dep't for Int'l Dev., *Increasing Access to Essential Medicines in the Developing World* 11, available at <http://www.cepis.org.pe/bvsacd/milenio/sidadfid.pdf> (last visited Dec. 1, 2010).

調，若政府未能針對不同藥物訂定中長期目標、政策執行之優先順序與實施方法，並透過適當立法程序以促進並整合政府與製藥產業之合作，達到支持公共健康需要之目的，便可能違反健康人權保障之義務。

參、國家實踐藥物近用權利之困境

但藥物近用權利保障面臨之主要困境在於，在全球市場競爭及藥物智慧財產權保障之壓力下，國家（尤其是發展中國家）不必然具備足夠能力與充分資源保障民眾之藥物近用權利⁷⁵（另一個困境則是跨國製藥企業對藥物近用權利之侵害，詳見第肆節）。尤其在資源或預算不足、國際藥物智慧財產權管制架構之過度擴張⁷⁶、藥物近用權利內涵多元等因素交互影響下，發展中國家之公部門往往無法提供充分且平價之藥物供民眾使用，遂使病人不得不向製藥企業購買價格較為昂貴之藥物。舉例而言，2001-2009年間僅有42%公部門健康保險機構可以取得基本藥物，但私營健康保險機構之比例卻達64%⁷⁷；另如非傳染性疾病或慢性疾病防治之成本效益(cost-

⁷⁵ 關於國家實踐藥物近用權利保障之人權義務之廣泛討論，請參考吳全峰（註6），頁613-683。本文在此節並不嘗試對此議題再作完整之分析，而僅嘗試證明國家在尊重與實踐藥物近用權利之人權義務上，有其困境；而該困境之存在（甚至因國際藥物智慧財產權體系之建立而惡化），則使得跨國製藥企業之人權責任——可在國家無能力履行其人權義務時作為補充人權保障之途徑——有進一步討論之空間。因此，本節之討論內容便集中並限縮在「國家實踐藥物近用權利之困境」，而非「國家實踐藥物近用之責任」。

⁷⁶ 近年來，藥物專利權之保障範圍不斷擴張，如美國對於萃取之基因材料給予專利保護，甚至可能延伸到「解釋疾病發生過程與潛在藥物對象」之上游發明；而開發中國家亦聯合修改 TRIPS 協定，提高對智慧財產權之保護門檻，阻礙較便宜之學名藥進入市場。楊智傑，如何解決藥物近用落差與研發落差？——TRIPS 下各種解決方案與大學專利政策之檢討，台灣科技法律與政策論叢，5卷2期，頁83（2008年）。李素華，從公共衛生之觀點論醫藥專利權之保護與限制，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，頁137-138（2006年）。

⁷⁷ U.N., *supra* note 68, at 51.

benefit ratio)往往偏低，因此發展中國家往往以健康人權之實現僅係在可利用資源範圍內漸進滿足為理由⁷⁸，迴避相關藥物之廣泛提供，並導致僅有慢性疾病治療需要之家庭中僅有27%獲得治療⁷⁹；再如藥物智慧財產權之嚴格限制或濫用，也使得原開發藥廠得以排除其他業者之競爭，並在獨占市場中維持偏高藥價（發展中國家之專利藥(patented drugs)價格約為學名藥(generic drugs)之2.6倍）⁸⁰，導致經濟能力較差之患者無法獲得適當之治療⁸¹。因此，單純倚賴國家之政策或作為以期滿足民眾對藥物近用權利之相關主張，而忽略跨國製藥企業之人權責任，顯然有其盲點。

一、藥物近用權利與貧窮問題之連結

貧窮(poverty)在開發中國家與已開發國家所造成之影響截然不同；就前者而言，貧窮之本質與基本需要(basic needs，包括健康照護需要)或基本能力(capabilities)之剝奪殊無二致⁸²，且與後者所了解或測量之低收入(lowness of incomes)截然不同⁸³。換言之，貧窮問題往往使得低收入國家無法提供充分支持之社會條件（包括基本藥物）以滿足民眾之健康需要，而惡化之健康遂進一步剝奪個人基本能力並限縮其經濟機會，國家之財政收入遂因此減縮，從此陷入惡性循環之貧窮陷阱⁸⁴。

78 U.N. ECOSOC CESCR, *General Comment No. 3: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Nature of States Parties Obligations*, para. 9, U.N. Doc. E/1991/23 (Dec. 14, 1990) [hereinafter *CESCR General Comment 3*].

79 U.N., *supra* note 68, at 52-53.

80 *Id.* at 54.

81 林彩瑜，WTO TRIPS 協定下醫藥專利與公共健康之問題及其解決方向，政大法學評論，78期，頁6-9（2004年）。陳文吟，探討因應醫藥品專利之合理措施，中正法學集刊，8期，頁4-5（2002年）。

82 AMARTYA SEN, *DEVELOPMENT AS FREEDOM* 87 (1999).

83 林萬億、周淑美，全球化與人類福利，頁109（2004年）。

84 Jeffery D. Sachs 著，鐵人庸譯，終結貧窮，如何在我們有生之年做到？，頁318-321（2007年）。

而貧窮問題與藥物近用權利之連結便具體反映在公共健康照護服務提供之不足。舉例而言，世界銀行（World Bank，以下簡稱WB）之調查便發現，低收入國家每年之公共健康照護支出約僅佔其GDP之1.3%，開發中國家約佔1.9%，但均遠不及已開發國家之6.2%⁸⁵；而偏低之公共健康照護支出，便可以被解釋為藥物在數量上之可利用性與經濟上之可近性均明顯不足，並使開發中國家與其民眾飽受藥物近用權利保障不平等之情境⁸⁶。另如作為HIV/AIDS主要治療方式之抗反轉錄病毒藥物治療之價格約為350至1,200美金⁸⁷，要求僅能負擔每人每年約8美金健康照護費用之低收入國家，保障民眾近用遠超過其負擔能力之藥物，亦顯屬不能⁸⁸；而治療肺結核(tuberculosis)與瘧疾(malaria)之藥物亦有類似之情形⁸⁹。進一步，除數量與藥價等要素外，專業人力與設備之不足，也造成低收入國家在藥物品質之確保與藥物之適當使用上，面臨嚴重之困境⁹⁰；如低收入國家每年均面臨數千名醫事人員離職（如被已開發國家招募），或是訓練醫事人員所需之教育資源與設備流失等嚴重

⁸⁵ WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/2001: ATTACKING POVERTY 286-88 (2000).

⁸⁶ Ames Thuo Gathii, *Third World Perspectives on Global Pharmaceutical Access, in* ETHICS AND THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 336, 342-44 (Michael A. Santoro & Thomas M. Gorrie eds., 2005). FREDERICK M. ABBOTT & GRAHAM DUKES, GLOBAL PHARMACEUTICAL POLICY: ENSURING MEDICINES FOR TOMORROW'S WORLD 117 (2009). Amir Attaran, *How Do Patents and Economic Policies Affect Access to Essential Medicines in Developing Countries?*, 23(3) HEALTH AFF. 155, 155 (2004). INT'L INTELL. PRO. INST., PATENT PROTECTION AND ACCESS TO HIV/AIDS PHARMACEUTICALS IN SUB-SAHARAN AFRICA 2 (2000), available at http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/pdf/iipi_hiv.pdf (last visited May 14, 2012).

⁸⁷ Amir Attaran & Lee Gillespie-White, *Do Patents for Antiretroviral Drugs Constrain Access to AIDS Treatment in Africa?*, 286(15) JAMA 1886, 1891 (2001).

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ Rudolf V. Van Puymbroeck, *Basic Survival Needs and Access to Medicines – Coming to Grips with TRIPS: Conversion + Calculation*, 38(3) J.L. MED. & ETHICS 520, 520-21 (2010).

⁹⁰ ABBOTT & DUKES, *supra* note 86, at 117.

問題⁹¹，並對包括藥物近用在內之健康人權形成極大威脅⁹²。換言之，貧窮問題將嚴重限制開發中國家保障藥物近用權利之能力，並進一步施壓限制貧窮人口近用必要藥物之機會。

但依據 ICESCR 第2(1)條⁹³及 CESCR General Comment No. 3第9段⁹⁴之規定，國家僅須承擔其最大能力範圍內所能採取之個別步驟（包括行政、立法、司法等措施，或經由國際援助與合作等適當方法），漸進滿足(*progressively realization*)藥物近用權利之充分實現即可⁹⁵；因此，在貧窮問題之限制下，國家便可以其可運用之有限資源為界線，正當化其民眾之藥物近用權利所受到之限制。而此時，若仍以國家中心主義(*state-centrism*)作為藥物近用權利保障之主導思維，而忽略跨國製藥企業在市場與經濟系統面向之主導能力，則顯然無法有效解決國際健康不平等(*global health inequality*)及

91 Thomas Pogge, *Access to Medicines*, 1(2) PUB. HEALTH ETHICS 73, 75 (2008).

92 Nir Eyal & Samia A. Hurst, *Physician Brain Drain: Can Nothing Be Done?*, 1(2) PUB. HEALTH ETHICS 180, 181 (2008).

93 Article 2(1) of the ICESCR, "Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures."

94 Paragraph 9 of CESCR General Comment No. 3, "The principal obligation of result reflected in article 2 (1) is to take steps 'with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized' in the Covenant. The term 'progressive realization' ... is on the one hand a necessary flexibility device, reflecting the realities of the real world and the difficulties involved for any country in ensuring full realization of economic, social and cultural rights. On the other hand, the phrase must be read in the light of the overall objective, indeed the *raison d'être*, of the Covenant which is to establish clear obligations for States parties in respect of the full realization of the rights in question. It thus imposes an obligation to move as expeditiously and effectively as possible towards that goal. Moreover, any deliberately retrogressive measures in that regard would require the most careful consideration and would need to be fully justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant and in the context of the full use of the maximum available resources."

95 吳全峰、黃文鴻（註27），頁147-148。

藥物近用權利保障等問題⁹⁶。且從許多國家之公共衛生實務發展中亦不難窺見，即令公共部門負責主導並規劃社會整體之藥物利用，但因其於藥物近用之路徑規劃上常會受制於財務緊縮之影響，因此私有部門往往被期待能適度介入（暫不論其是基於市場利益布局或企業社會責任而介入）並彌補這一部分之空隙⁹⁷。

二、藥物近用權利與智慧財產權之衝突

除資源有限之限制外，藥物近用權利與智慧財產權間不可切割之密切關聯，也對國家實踐藥物近用權利形成障礙；尤其在 WTO 制訂通過 TRIPS 協定後，藥物近用權利與藥物智慧財產權之衝突與矛盾便引起廣泛之辯論，也造成開發中與已開發國家間之對立。一方面，智慧財產權典範對製藥產業有其獨特之重要性⁹⁸：（1）因藥物研發往往需要長時間之投入、繁瑣之法規登記時間、鉅額之研發資源與經費耗用⁹⁹，故藥物智慧財產權保障所賦予發明創作人（專利藥廠）一定範圍內之技術領域享有排他之權利，同時伴及市場上（獨占）經濟利益與回饋，除可確保製藥產業之獲利以回收龐大成本，亦可進一步提供研發創新(research and development, R&D)之經濟誘因。（2）因藥物研發所重視者為知識之創新，而在研發成

96 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Jr., *Globalization: What's New? What's Not? (and So What?)*, 118 FOREIGN POL'Y 104, 118 (2000).

97 ABBOTT & DUKES, *supra* note 86, at 121-23.

98 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南，專利法解讀，頁14-16（2000年）。吳全峰（註6），頁606-607。

99 研究發現，一項藥物研發需要約10-12年之長時間投入與約3.5億美金之龐大成本（如1998年美國製藥產業在研發之投資規模約佔所有工業投資規模之18.7%；較電子製造業之9.6%、高科技儀器製造業之7.8%、化學製造業之6.2%與重機械製造業之5.5%均高），且其風險亦相對偏高（一個新化學成分約僅有1/4,000-1/10,000之機率上市）；但因其製造成本相對低廉，因此若無法藉由智慧財產權制度確保具創新意義之專利新藥可自市場獨占中獲得相當利潤，則將無法提供研發之原動力。謝季峰（註70），頁81-92。朱懷祖，新藥科技與智慧財產權保護，收於：朱懷祖、梁啟銘、孔繁璐編，藥物科技發展與智財權保護，頁4-6（2006年）。

果出現後，複製之成本便相對低廉¹⁰⁰；因此，若無適當之藥物智慧財產權保障，則大量仿製藥物之出現將減損製藥產業之利潤，並削弱製藥產業研發新藥之能力¹⁰¹。(3) 因藥物之專利權申請相對明確，其權利受侵害時之舉證亦較容易，故藥物智慧財產權制度可提供專利藥廠較有效率之保障¹⁰²。但另一方面，因藥物價格與智慧財產權之規範密度互動關係緊密¹⁰³，過度嚴格之藥物智慧財產權保護（以及其賦予專利藥廠之排他性市場獨占權利）便被認為是造成高額藥價之重要因素，並將形成經濟障礙(financial barriers)並對藥物可近性造成衝擊。如 WHO 便估計專利藥物大多以其邊際成本（接近學名藥之價格）之20-100倍價格銷售¹⁰⁴；Laurens M. Niëns 之研

100 若以航太產業為例，即令缺乏智慧財產權之保障，因仿製者除須取得創新之知識外，尚須有大量之金錢與設備（與原創者投入之資源相當）建造等比例模型、模擬風洞、製造精密零件、設計複雜電路系統，始能達到仿製之目的；且即令其在一段時間後仿製成功，原創者亦已在技術上再創新並維持領先地位。

101 F. M. Scherer, *Pharmaceutical Innovation*, Harvard University JFK School of Government Faculty Research Working Paper No. RWP07-004, 28 (June, 2007). Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁70。

102 F. M. Scherer, *The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals*, Address at the AIDE Conference on Pharmaceutical Patents, Innovation and Public Health (Dec. 1998).

103 Carmel Shalev, *supra* note 30, at 98. 謝季峰（註70），頁93。

104 林彩瑜（註81），頁275。另如聯合國人權委員會(Commission On Human Rights)於2001年所作之研究便發現，150毫克愛滋病藥物 fluconazole 在印度（藥物專利權保障在當時較不完整）之價格約為55美元，但在馬來西亞、印尼、菲律賓等對藥物專利權保障較為完整之國家，其價格則高達697、703、817美元；另以205毫克抗生素 Ciprofloxacin 為例，在2001年之跨國研究中同樣發現其價格可從專利藥廠之4.67美元（美國 Bayer）遽降至學名藥廠之0.06美元（印度 FDC）。南非競爭委員會在 *Hazel Tau v. GlaxoSmithKline, Boehringer* 乙案之調查報告則發現，專利藥廠所定之愛滋病用藥價格約為學名藥價格之2-8倍（見下表）。

Product	Price sold to private sector	WHO pre-qualified generic
AZT (300mg)	US\$ 0.92	US\$ 0.25
Lamivudine (150mg)	US\$ 1.02	US\$ 0.32
AZT/ Lamivudine (300mg/150mg)	US\$ 1.27	US\$ 0.85
Nevirapine (200mg)	US\$ 0.57	US\$ 0.60

U.N. Comm'n on Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights: The impact

究更進一步發現，相當比例之人口將可能因需要購買昂貴之專利藥物而被推至(pushed)貧窮線以下¹⁰⁵。

有鑑於智慧財產權制度對公共健康之衝擊，TRIPS 協定中便採行一般例外規定，對智慧財產權之行使設有一定限制，以嘗試平衡公共利益（整體公眾之健康人權保障）與私益（對發明創造者之補償）之衝突¹⁰⁶；如第7條主張智慧財產權之制度設計與政策執行，應兼顧技術革新與傳播、社會與經濟福利之進步、權利與義務之平衡¹⁰⁷；第8(1)條¹⁰⁸對智慧財產權保障設有一般例外規定（或稱彈性

of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on human rights: Rep. of the High Commissioner, para. 44, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/13 (June 27, 2001). Kavaljit Singh, *War Profiteering: Anthrax, Drug Transnationals and TRIPs 2*, available at <http://www.madhyam.org.in/admin/tender/War%20Profiteering%20Anthrax,%20Drug%20Transnationals%20and%20TRIPs.PDF> (last visited Oct. 26, 2010). Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at paras. 35-39.

¹⁰⁵ 舉例而言，購買 Atenolol（治療高血壓之專利藥）將可能導致菲律賓人口中之12%落入每天1.25美元之貧窮線以下；但若使用低價之學名藥，則受影響之民眾將降至7%。另，Salbutamol（哮喘藥品）、Glibenclamide（糖尿病藥品）、Amoxicillin（成人呼吸感染藥品）所影響之人口群分別為10%、11%及17%。Laurens M. Niëns et al., *Quantifying the Impoverishing Effects of Purchasing Medicines: A Cross-Country Comparison of the Affordability of Medicines in the Developing World*, 7(8) PLOS MED. 1, 1-8 (2010).

¹⁰⁶ 如在 TRIPS 協定前言中便提到，該協定應承認各國保護智慧財產權體制與保護公共利益的基本目標，包括發展和技術目標([r]ecognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives)；也承認最不發達國家在其國內實施法律及其細則方面享受最大程度靈活性的特殊需要，以便使它們能夠建立一個堅實和有效的技術基礎([r]ecognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base)。

¹⁰⁷ Article 7 of the TRIPS, “The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

¹⁰⁸ Article 8(1) of the TRIPS, “Members may, in formulating or amending their laws

條款)，允許會員國以公共利益或國家安全作為協定義務例外排除之基礎；若進一步符合第31條¹⁰⁹之特定條件，會員國尚可自行使用或授權第三人使用受專利保障之發明創作（即強制授權）¹¹⁰；另為避免智慧財產權規範對開發中及低度開發國家造成不利影響，TRIPS 協定尚訂有過渡規定（第65條¹¹¹及第66條¹¹²），並要求智慧

and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.” 本條規定主要係保障會員國在制訂及執行智慧財產權法律時，留有彈性的空間，得在制訂或修正其國內智慧財產權法律及規章時，於符合 TRIPS 協定的規定下得採行必要的措施，以保護公共健康與營養、促進對該國之社會經濟及科技發展極為重要之部門之公共利益。

109 Article 31 of the TRIPS, “Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected”

110 但須注意者為，強制授權之展開並非毫無前提限制，TRIPS 第31條中所規範之6項實施專利強制授權的具體事由包括：專利權未實施或未充分實施、專利權人拒絕授權、國家緊急危難或其他緊急狀況、非營利性公共使用、反競爭行為、從屬專利。詳言之，凡會員國欲主張強制授權，須符合以下之條件：（1）授權必須基於個案之考量；（2）除非在國家緊急危難或其他緊急情況或基於非營利公共使用的情形下，申請人必須已經以合理的商業條款與條件積極向權利人爭取授權，且於合理期間內無法取得授權；（3）使用之範圍與期間應限於被授權之目的；（4）授權屬非專屬授權；（5）授權不具可移轉性；（6）授權應以供應授權國內市場需要為主；（7）若授權原因消滅且恢復可能性不高時，應終止授權；（8）授權決定之合法性及補償均應受司法獨立審查。

111 Article 65 of the TRIPS, “... (2) A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application (3) Any other Member which is in the process of transformation from a centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is undertaking structural reform of its intellectual property system and facing special problems in the preparation and implementation of intellectual property laws and regulations, may also benefit from a period of delay as foreseen in paragraph 2. ...”

112 Article 66 of the TRIPS, “(1) In view of the special needs and requirements of least-developed country Members, ... such Members shall not be required to apply the [TRIPS] ... for a period of 10 years from the date of application The Council for TRIPS shall, upon duly motivated request by a least-developed country Member, accord extensions of this period. (2) Developed country Members shall provide incentives to enterprises and institutions in their territories for the purpose of

財產權之保護應同時兼顧促進技術合作與移轉（第67條¹¹³及第69條¹¹⁴）。除 TRIPS 協定之例外條款外，WTO 更於2001 年與2003 年進一步通過「TRIPS 協定與公共健康宣言」（Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health，以下簡稱 Doha 宣言）¹¹⁵與「執行 TRIPS 協定與公共衛生宣言第六段決議」（Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health，以下簡稱2003年決議）¹¹⁶，藉以建立一套明確之強制授權出口制度，以補強無製藥能力會員國實質上無法利用 TRIPS 協定強制授權制度之問題。如 Doha 宣言第3段¹¹⁷及第5(b)段¹¹⁸除明白揭示應重視智慧財產權保護對藥物價格之影響，並除重申會員國在緊急急迫情形下強制授權生產學名藥物之權利外，第5(c)段更進一步例示（但不限）國家緊急或其他危急情況包括 HIV/AIDS、結

promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members in order to enable them to create a sound and viable technological base.”

- 113 Article 67 of the TRIPS, “In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed country Members shall provide ... technical and financial cooperation in favour of developing and least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall include support regarding the establishment or reinforcement of domestic offices and agencies relevant to these matters, including the training of personnel.”
- 114 Article 69 of the TRIPS, “Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating international trade in goods infringing intellectual property rights. For this purpose, they shall ... be ready to exchange information on trade in infringing goods ... [and to] promote the exchange of information and cooperation between customs authorities”
- 115 World Trade Organization, Ministerial Declaration of 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/2, 41 I.L.M. 755 (2002) [hereinafter Doha Declaration].
- 116 Decision of the General Council, Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WT/L/540 (Aug. 30, 2003), 43 I.L.M. 509 (2004) [hereinafter Paragraph 6 Decision].
- 117 Paragraph 3 of the Doha Declaration, “We recognize that intellectual property protection is important for the development of new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices.”
- 118 Paragraph 5(b) of the Doha Declaration, “Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted.”

核病、瘧疾及其他傳染病之流行¹¹⁹；2003年決議為解決發展中國家在強制授權時所面臨之製藥能力與財政資源不足之問題，遂允許暫時豁免(waiver)其 TRIPS 協定第31(f)條¹²⁰（強制授權之藥物使用應限於准許該使用行為之締約方國內市場）及第31(h)條¹²¹（強制授權在任何情況下都必須向專利權人支付適當的費用，費用的數目取決於該准許的經濟價值）之義務¹²²。因此，發展中國家便具備某種程度之經濟資源與政策空間，而得以實際操作強制授權制度以處理公共衛生危機。

跨國製藥企業往往據此主張 TRIPS 協定之相關調和機制已足以作為國際經貿自由化中容納公共健康考量之處所¹²³，並強烈反對

119 Paragraph 5(c) of the Doha Declaration, “Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.”

120 Article 31(f) of the TRIPS, “...any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use.”

121 Article 31(h) of the TRIPS, “... the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization.”

122 Paragraph 2 of the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, “The obligations of an exporting Member under Article 31(f) of the TRIPS Agreement shall be waived with respect to the grant by it of a compulsory licence to the extent necessary for the purposes of production of a pharmaceutical product(s) and its export to an eligible importing Member(s) in accordance with the terms set out below in this paragraph:” Paragraph 3 of the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, “Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in this Decision, adequate remuneration pursuant to Article 31(h) of the TRIPS Agreement shall be paid in that Member taking into account the economic value to the importing Member of the use that has been authorized in the exporting Member. Where a compulsory licence is granted for the same products in the eligible importing Member, the obligation of that Member under Article 31(h) shall be waived in respect of those products for which remuneration in accordance with the first sentence of this paragraph is paid in the exporting Member.”

123 James Thuo Gathii, *International Justice and the Trading Regime*, 19 EMORY INT’L L. REV. 1407, 1422 (2005).

將健康人權之典範強加於國際智慧財產權體系上；且因 TRIPS 協定例外規定已賦予國家足夠之能力與資源保障民眾藥物近用權利，故在國家實踐該義務並無窒礙之假設下，跨國製藥企業亦宣稱其僅需扮演國際合作中之協助角色即可¹²⁴。(1) 首先，就理論發展而言，跨國製藥企業宣稱智慧財產權典範所影響者，不限於單純經濟利益之保障，更將促進藥物研發與疾病治療，並間接達成健康人權保障之目的。蓋若開發中國家能改變藥物智慧財產權欠缺保障之狀況，或國際間對於藥物智慧財產權之保障能有一致之標準¹²⁵，則不僅能刺激開發中國家製藥產業之發展與創新，達到鼓勵新藥研發之目的；亦某種程度協助經濟體中藉由確保國際貿易秩序、擴大生產與貿易自由化機制、適當散布科技知識，取得增進經濟發展之成果並作為解決開發中國家貧困與經濟增長之動力，使民眾能夠以最有利之經濟代價換取其認為最佳之社會財貨供應（包括健康照護），而有助於藥物近用之普遍性¹²⁶。(2) 其次，跨國製藥企業亦主張國

124 Virginia Barbour et al., *Drug Companies Should Be Held More Accountable for Their Human Rights Responsibilities*, 7(9) PLoS MED. 1, 1-2 (2010) (published online in PLoS Medicine, e1000310. doi:10.1371/journal.pmed.1000310), available at <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000344> (last visited Jan. 9, 2012).

125 此即 TRIPS 前言所稱，應建立與貿易有關智慧財產權之獲得、範圍與行使之一致性適當標準和原則（“[r]ecognizing ... the need for new rules and disciplines concerning ... the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights; [and] the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems. ...”）。

126 主要是因藥物近用之分析不應侷限於後端之價格因素，而應統整考慮包括研發創新、生產、品質控制、適當分配網絡等連串因素；而藥物智慧財產權保障對於前述經濟與非經濟因素之適當發展均有深遠影響（如藥品智慧財產權保障可對專利藥廠持續研究發展新藥品提供實質誘因），可藉由促進更多藥品之研發與（相對應）更多疾病之治療，間接達成促進與保障公共健康之目的。如 GSK 總裁(Sir Richard Sykes)便強調，藥物智慧財產權並非發展中國家藥物近用問題之原因；相對而言，藉由藥物智慧財產權制度之建立，將可進一步健全開發中國家藥物研發與製造之能力，並改善其藥物近用問題(“Few would argue with the need for IP protection in the developed world, but some

際智慧財產權體系下之強制授權規範已足以在健康政策中扮演重要之角色，賦與開發中國家在僅能取得數量有限（可利用性不足）或價格高昂（可近性不足）之專利藥物時，得不經專利權人（原開發藥廠）之同意，授權第三人使用該藥物研發之成果逕行大量生產較便宜之學名藥，以解決藥物近用所面臨之實體與經濟障礙。（3）最後，若國際智慧財產權規範之平衡機制已能有效調和貿易典範與人權典範之衝突，以目前國際人權法將義務主體侷限於國家且跨國企業之人權責任範圍仍有爭論之前提下，則似無空間亦無必要將跨國製藥企業納入健康人權之架構下，並賦予其滿足民眾藥物近用權利之義務；蓋國家可依循 TRIPS 協定尊重健康人權之精神，於內國法中對跨國製藥企業之商業行為為一定之規範。且若任意將跨國製藥企業之智慧財產權保障與健康人權義務扣合將模糊前者維護發明創作人（如原開發藥廠）排他性權利保障、促進知識創造與商業開發等規範目的¹²⁷，亦將使發明創作人失去與大眾分享發明創作成果

question whether it is appropriate to extend its coverage to the developing world, which the TRIPS agreement is gradually doing. As I have said, IP protection is not the cause of the present lack of access to medicines in developing countries. At Doha last November, WTO members agreed to defer TRIPS implementation for the least developed countries until 2016. I do not believe that TRIPS will prevent other developing countries like Brazil and India from obtaining access to the medicines they need. On the other hand, I firmly believe that these countries have the capacity to nurture research-based pharmaceutical industries of their own, as well as other innovative industries, but this will only happen when they provide the IP protection that is enshrined in TRIPS. TRIPS needs to be recognised as an important industrial development tool for developing countries.”) 。WTO, THE FUTURE OF THE WTO: ADDRESSING INSTITUTIONAL CHALLENGES IN THE NEW MILLENNIUM: REPORT BY THE CONSULTATIVE BOARD TO THE DIRECTOR-GENERAL SUPACHAI PANITCHPAKDI 10 (2004). Nathan Ford, *Patents, Access to Medicines and the Role of Non-Governmental Organisations*, 2(1) J. GENERIC MED. 137, 137 (2004). Jamie Feldman, *Compulsory Licenses: The Dangers Behind the Current Practice*, 8 J. INT’L BUS. & L. 137, 140 (2009). Presentation by Sir Richard Sykes at Royal Institute of International Affairs, London, 14 Mar. 2002. 吳全峰（註6），頁601。

¹²⁷ See, e.g., Jose E. Alvarez, *How Not to Link: Institutional Conundrums on an Expanded Trade Regime*, 7 WIDENER L. SYMPOSIUM J. 1, 10 (2001); Lorand Bartels, *Article XX of GATT and the Problem of Extraterritorial Jurisdiction: The Case of Trade Measures for the Protection of Human Rights*, 36 J. WORLD TRADE 353, 363

之動機，並因而減緩新穎知識技術之廣泛傳播與民眾福祉之進步¹²⁸。

但問題在於，實證研究所透露出之訊息卻非如跨國製藥企業所宣稱之樂觀；且相關研究亦顯示，TRIPS 協定下健康人權與智慧財產權之調和機制在面臨規範設計缺失與現實環境、製藥先進國家與跨國製藥企業之挑戰下，其運作往往面臨瓶頸而無法完全排除智慧財產權規範對國際健康人權造成之深遠影響¹²⁹，並導致國家保障健康人權之義務便無法完全或適度地發揮其功能時。故若持續忽視跨國製藥企業之優勢經貿實力與影響力，並將其完全排除於國際健康人權體系之外，則對於國家藥物政策之發展與藥物近用權利之保障，均將造成嚴重之負面影響。

(一) 平衡機制之不足

受限於不同性質與主題之國際法規範各有其空間與主體性¹³⁰——國際智慧財產權涉及產品與智力成果之跨境流通與交換價值之實現，屬國際間私有部門(private sectors)之規範；而健康人權則體現個人自由平等之生存與發展等各項權利之尊重與保障，傳統上係規範作為公共部門(public sectors)之國家——國際人權體系與國際智慧財產權體系遂發展出不同且互不相容之運作及實施機制，並

(2002). Robert Howse, *Human Rights in the WTO: Whose Rights, What Humanity? Comments on Petersman*, 13 EUR. J. INT'L L. 651, 658 n.7 (2002); SUSAN ARIEL AARONSON & JAMIE M. ZIMMERMAN, *TRADE IMBALANCE – THE STRUGGLE TO WEIGH HUMAN RIGHTS CONCERNS IN TRADE POLICYMAKING* 191 (2008).

¹²⁸ 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南（註98），頁14-16。

¹²⁹ See Patrick Wojahn, *A Conflict of Rights: Intellectual Property under TRIPS, the Right to Health, and AIDS Drugs*, 6 UCLA J. INT'L L. & FOREIGN AFF. 463, 457-89 (2002); Ben Kiromba Twinomugisha, *Implications of the TRIPS Agreement for the Protection of the Right of Access to Medicines in Uganda*, 2(2) MALAWI L.J. 253, 253-56 (2008). Ellen't Hoen, *TRIPS, Pharmaceutical Patents, and Access to Essential Medicines: A Long Way from Seattle to Doha*, 3 CHI. J. INT'L L. 27, 28-29 (2002). 林彩瑜（註81），頁290-292。吳全峰（註6），頁613-612。

¹³⁰ 劉超，論國際貿易的人權問題，南京財經大學學報，148期，頁79（2007年）。

使得健康人權與貿易典範間之互動功能大幅限縮，且不時出現齟齬¹³¹。雖然 TRIPS 協定例外規定嘗試平衡智慧財產權與藥物近用權利之衝突，但在典範衝突無法解決之前提下¹³²，仍面臨適用規範之模糊且不統一之問題¹³³，更遑論從其中得出國家在藥物近用權利與智慧財產權保障義務間應如何取得平衡之論述。

舉例而言，Doha 宣言第5(c)條雖承認國家為因應傳染病(epidemics)之預防與治療，應可作為智慧財產權保障之例外事項，但對於何謂「傳染病」之具體內涵卻未有進一步之解釋¹³⁴；即令條文中「國家緊急狀況(national emergency)」與「公共衛生危機(public health crises)」等敘述，似可作為判斷國家在面臨何種傳染病之威脅下，運用 TRIP 協定之例外規定始具有正當性，但這些敘述對於判斷「傳染病」之具體內涵實無太大助益，亦使發展中國家在利用如強制授權等例外規定時，面臨正當性不確定之困境¹³⁵。如2005年台灣在無任何禽流感疫情之前提下，是否有足夠正當性將現在未發生且未來亦不一定發生之傳染病事件視為「國家緊急狀況」，限制原開發藥廠之權利並強制授權克流感(Tamiflu)，便可能

131 吳全峰（註6），頁632。

132 傳統上 WTO 對貿易與人權衝突之處理態度往往較為保守，對於非貿易關切之事項（non-trade concerns，如健康議題），除非與人類福祉強化有必要關聯性，否則多將其排除在貿易政策討論之範疇外。吳全峰（註6），頁632-633。

133 Vishal Gupta, *A Mathematical Approach to Benefit-Detriment Analysis as a Solution to Compulsory Licensing of Pharmaceuticals under the Trips Agreement*, 13 CARDOZO J. INT'L & COMP. L. 631, 659 (2005).

134 有學者認為這類模糊空間在 TRIPS 協定與 Doha 宣言之協商通過上，為符合不同國家利益之最大公約數有其必要性。蓋因「傳染病」之內涵與範圍將不可避免與會員國行駛強制授權權利之「必要性」具有緊密關聯性，因此具有高度敏感性；而會員國間往往在類似規範上各有符合其利益之規劃方向，因此若欲明確界定出判斷之標準，便可能導致會員國間之歧異爭執並導致相關協議之談判失敗。也因此，TRIPS 協定例外規定之模糊與彈性空間，往往被認為較為符合各國利益與實益，且可賦予各國空間依據其特定之社經狀況做出適當之判斷。林彩瑜（註81），頁291。吳全峰（註6），頁619-620。

135 相關討論請參考吳全峰（註6），頁624。

出現爭議¹³⁶。而類似之空泛規範內容，亦因無法提供智慧財產權人發明創新經濟利益之保障與公共健康之維護間之合理比重關係，而可能導致國家得以恣意地將經濟利益置於公共衛生之上，使其受國際人權典範約束所應盡之藥物近用權利保障義務，在有意無意間被忽略¹³⁷。如泰國於2006年主張對 Plavix（心臟病藥物）進行強制授權，便引起其他已開發國家之反彈，並藉此主張所有慢性疾病均不符合 TRIPS 協定第31條（國家緊急狀況）或 Doha 宣言第5(c)條（傳染病）之限制¹³⁸，而忽略公共衛生危機之本質應不限於急性傳染病¹³⁹，亦忽略 TRIPS 協定或 Doha 宣言並未限制國家可針對何種健康問題取得強制授權^{140、141}。因此，TRIPS 協定相關平衡機制在

136 牛惠之，淺論認定國家緊急狀況與強制授權克流感的正當性與必要性，台灣本土法學雜誌，79期，頁5-6（2006年）。

137 牛惠之，從 WTO 自由貿易論「杜哈 TRIPS 協定與公共衛生宣言」對「國家緊急危難或其他緊急狀況」的解釋與潛在爭議——兼論預防原則的運用，第七屆國際經貿法發展學術研討會，國立政治大學國際經貿組國際法律研究中心主辦，頁16（2007年3月25日）。

138 Pier DeRoo, "Public Non-Commercial Use" *Compulsory Licensing for Pharmaceutical Drugs in Government Health Care Programs*, 32 MICH. J. INT'L L. 347, 351-52 (2011). Peter Maybarduk & Sarah Rimmington, *Compulsory Licenses: A Tool to Improve Global Access to the HPV Vaccine?*, 35 AM. J.L. & MED. 323, 330 (2009). Roger Bate, *Thailand's Patent Attack*, N.Y. SUN, Feb. 13, 2007, available at <http://www.nysun.com/opinion/thailands-patent-attack/48499> (last visited Apr. 30, 2012).

139 Brent Savoie, *Thailand's Test: Compulsory Licensing in an Era of Epidemiologic Transition*, 48 VA. J. INT'L L. 211, 238-40 (2007). Kevin Outterson, *Should Access to Medicines and TRIPS Flexibilities Be Limited to Specific Diseases?*, 34 AM. J.L. & MED. 317, 318, 336-38 (2008).

140 依據 TRIPS 協定第31(b)條前段("[e]ach Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency")及 Doha 宣言第5(b)段("[e]ach Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted")之規定，所謂緊急急迫之情形，除例示包括 HIV/AIDS、結核病、瘧疾及其他傳染病之流行外，國家亦有權自行決定判斷可視為國家處於緊急情況或其他極度危急環境。有學者因此認為泰國之政策符合 TRIPS 協定與杜哈宣言之規定，因會員有權自行認定國家緊急危難之狀況。Frederick M. Abbott, *The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines under the Amended TRIPS Provisions*, 10 J. INT'L ECON. L. 921,

內容空泛之限制下，似乎無法充分解決國家缺乏能力與資源以確保藥物近用之疑慮¹⁴²。

再就自由貿易協定（Free Trade Agreement，以下簡稱 FTA）中頻繁出現較 TRIPS 協定規範更為嚴格之藥物智慧財產權保護措施（即 TRIPS 加碼，以下簡稱 TRIPS-plus）觀察，TRIPS-plus 之興起亦使得國際智慧財產權體系對健康人權保障之平衡機制，更加傾斜向國際貿易自由化與經濟利益極大化之追求，並對開發中國家民眾之藥物近用權利保障形成嚴峻考驗¹⁴³。如資料專屬權(data exclusiveness)¹⁴⁴與專利連結(patent linkage)¹⁴⁵等較 TRIPS 協定更為

952-57 (2007). Maybarduk & Rimmington, *supra* note 138, at 330.

- 141 有一點值得注意的是，泰國之後強調其並非以 TRIPS 第31條有關「國家緊急危難」之理由要求強制授權，而係以同條之「非營利公益考量（public- non-commercial use）」作為理由，強調該強制授權之藥物係為國內公立健康保險之所用。但因 WTO 對於所謂「非營利公益考量」之內涵亦未有解釋，因此泰國主張之正當性仍受到嚴格之挑戰與檢視。THAI MINISTRY OF PUBLIC HEALTH & NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE, FACTS AND EVIDENCE ON THE 10 BURNING ISSUES RELATED TO THE GOVERNMENT USE OF PATENTS ON THREE PATENTED ESSENTIAL DRUGS IN THAILAND 23, 38-46 (2007), available at <http://www.moph.go.th/hot/White%20Paper%20CL-EN.pdf> (last visited May 4, 2012). Jon Matthews, *Renewing Healthy Competition: Compulsory Licenses and Why Abuses of the TRIPS Article 31 Standards are Most Damaging to the United States Healthcare Industry*, 4 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 119, 136 (2010).

- 142 Rudolf v. Van Puymbroeck 在泰國之研究便發現，泰國若在不行使強制授權之前提下具體落實 TRIPS 規範，將導致愛滋病藥物價格於2000年至2003年間遽增約340%，而第二線藥物(second line drugs)之價格亦將大幅成長。Van Puymbroeck, *supra* note 89, at 534.

- 143 *Id.* at 945.

- 144 即給予提出原始登記藥物研發資料之專利權人一段時間之有效市場獨占權。

- 145 亦即將藥物登記與專利保護加以連結，對於尚在專利保護期間之藥物，主管機關除非經該藥物專利擁有者之同意或默許，不得核准該藥物之學名藥行銷許可。專利扣合之緣起係來自美國藥價競爭與專利期間回復法案（Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984，亦稱為 Hatch-Waxman Act），該法案希望一方面藉由規範藥價競爭(drug price competition)及簡化學名藥申請許可上市程序，滿足消費者儘速取得較便宜學名藥之關切；另一方面藉由回復專利期(patent term restoration)作為補償原開發藥廠之手段，以繼續促進藥物之研發與創新活動。但美國在與其他國家協商談判 FTA 之過程中，往往僅重視專利扣合制度，並希望藉由該制度達成迫使簽約國對原開發藥廠之

嚴格規範之出現，便展現已開發國家另行創造規範藥物智慧財產權之管道之企圖，並運用龐大之市場與不對稱之經貿權力關係要求發展中國家接受¹⁴⁶，以延緩或防止較便宜之競爭學名藥之生產與上市，以維護專利藥廠市場獨占之經濟利益；但相對而言，相關規範卻也對處於較貧窮或製藥產業不發達國家民眾之藥物近用權利保障，更是形成嚴峻考驗。如美國在與馬來西亞之 FTA 談判中，便強力要求馬來西亞藥物管制局（Drug Regulatory Agency，以下簡稱 DRA）在專利扣合制度下尚需負擔實質判斷學名藥廠所申請之資料是否侵害原開發藥廠之專利權¹⁴⁷；但在能力資源均有限之前提下¹⁴⁸，類似之規範將使審查時程延長並大幅延後學名藥之上市時程¹⁴⁹。而 Nusaraporn Kessomboon 針對美泰自由貿易協定(US-Thai FTA)之研究則發現，相關 TRIPS-plus 之規定將導致泰國所有（而非少數幾種）藥物價格在20年內攀升32%-67%¹⁵⁰。因此，在藥物智慧財產權之保障逐漸出現由多邊而雙邊(bilateral)之趨勢以及 TRIPS-plus 之介入下¹⁵¹，可預期國家將無法繼續以既有 TRIPS 協

專利利益提供更充分保障之目的；而刻意忽略專利扣合制度實僅為 Hatch-Waxman Act 中作為權衡新藥研發誘因與加速學名藥上市之多種機制之一，從而使得 Hatch-Waxman Act 中所強調之另一主軸（規範藥價競爭）與相對應之其他權衡措施在 FTA 之內涵中顯得相對模糊甚至是隱藏消失。

146 Susan K. Sell, *Trade Issues and HIV/AIDS*, 17 EMORY INT'L L. Rev. 933, 944 (2003).

147 Robert Galantucci, *Data Protection in a U.S.-Malaysia Trade Agreement: New Barriers to Market Access for Generic Drug Manufacturers*, 17 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1083, 1103 (2007).

148 研究發現，甚至連美國藥物食品管理局(Food and Drug Administration, FDA)亦無能力與專業實質檢視藥物之專利內容。Minority Staff of H.R. Comm. on Govt. Reform, 109th Cong., *Trade Agreements and Access to Medications under the Bush Administration* 7 (2005), available at <http://www.democrats.reform.house.gov/Documents/20050609094902-11945.pdf> (last visited May 4, 2012).

149 Galantucci, *supra* note 147, at 1103-04.

150 Nusaraporn Kessomboon et. al., *Impact on Access to Medicines from TRIPS-plus: A Case Study of Thai-US FTA*, 41(3) SOUTHEAST ASIAN J. TROP. MED. PUB. HEALTH 667, 673 (2010).

151 Carlos M. Correa, *Implications of Bilateral Free Trade Agreements on Access to Medicines*, 84(5) BULL. OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 399, 399 (2006). 牛

定之調和規範阻擋藥物新增之智慧財產權能大幅倒向或利益專利醫藥公司與製藥先進國家，亦無法避免民眾藥物近用權利所可能受到之嚴重限制¹⁵²。

(二) 經貿實力之落差

除 TRIPS 協定相關調和規範無法充分改善智慧財產權與健康人權保障間之失衡狀態外，國際經貿實力嚴重失衡之現實則進一步限制強制授權之運用，並惡化國家實踐藥物近用權利之困境。詳言之，原本國際智慧財產權規範之例外規定，本就係設計以平衡民眾健康人權保障與跨國製藥企業經濟利潤追求之天平；但因開發中國家或對工業化已開發國家之巨大市場具有極大經貿依存性¹⁵³、或因經貿實力較弱而不具談判籌碼¹⁵⁴、或因覬覦跨國製藥產業之鉅額投資，遂使開發中國家對已開發國家或跨國製藥企業之經貿依賴形成一種不對稱權力關係，並具體反映在執行 TRIPS 協定例外條款之意願、範圍與強度上。舉例而言，發展中國家在直接貿易制裁或間接經濟壓力(economic coercion)下，便可能放棄或縮減執行如強制授權等例外規定（如南非在美國壓力下對於運用強制授權便有所遲疑¹⁵⁵，或如巴西承諾透過 TRIPS 協定未規範之早期警告系統於實施強制授權前通知美國¹⁵⁶），或制定緊縮健康人權保障之更嚴格藥物智慧財產權保護政策（即 TRIPS-plus，如韓國在美韓 FTA 第 18.9.1 條便明文規定簽約國須承諾將藥物登記與專利保護間加以連結¹⁵⁷），造成開發中國家運用強制授權之自由受到嚴格限制，從而

惠之（註137），頁38。

152 就如何應用人權取徑，以避免 TRIPS 協定例外規定（如強制授權）在解決藥物近用問題時所面臨之內在缺陷與困境，請參考吳全峰（註6），頁581-693。

153 Sell, *supra*, note 146, at 944.

154 牛惠之（註137），頁38。

155 林彩瑜（註81），頁300。

156 林彩瑜（註81），頁299-300。

157 Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea, U.S.-S. Korea, Mar. 15, 2012. Jeffery J. Schott, Scott C. Bradford & Thomas

使原本平衡智慧財產權與健康人權典範之天平出現傾斜之現象。換言之，TRIPS 協定調和機制之相關功能討論，因未正視已開發國家與開發中國家之間所存在資源落差、國際健康不均、與製藥產業過度集中等問題，遂使得國家對藥物近用權利之保障，在智慧財產權體系下出現理論與實務之落差。

即令在藥物價格之控制上，也可以發現將藥物近用權利之保障義務侷限於國家有其盲點。在藥物智慧財產權與健康人權衝突之案例中，不難發現跨國製藥企業以捐贈藥物或大幅調整價格之行為，搭配母國(home country)之訴訟威脅，使地主國(host country)在運用例外條款時受到非法規之束縛¹⁵⁸。舉例而言，在南非與美國之 AIDS 藥物智慧財產權爭端案中，南非雖威脅修法將強制授權規範納入「國內藥物及相關物質控制修正案」(Medicines and Related Substances Control Amendment Act)中，但在(1)美國依 WTO 爭端解決規則與程序了解書之規定提出控訴申請(最後撤銷)，及(2)跨國製藥企業採降價之方式嘗試解決問題並避免進入實質之訴訟程序之雙重影響下¹⁵⁹，仍放棄將強制授權納入國內法規範之企圖¹⁶⁰。

Moll, *Negotiating the Korea-United States Free Trade Agreement*, 10 (Policy Brief 06-4, June 2006), available at <http://www.iie.com/publications/pb/pb06-4.pdf> (last visited May 4, 2012).

¹⁵⁸ Joseph, *supra* note 19, at 436.

¹⁵⁹ 跨國製藥企業之降價行為，主要是為避免爭端解決小組對強制授權之相關要件(包括國家緊急危難之定義)做出判斷，而對跨國製藥企業之利益產生重大衝擊；換言之，先進國家或跨國製藥企業並未無意願在法律上肯認強制授權之正當性，亦未對強制授權之範圍明確表態(如是否包括 AIDS 相關藥物外之急迫性藥物)，而僅是在國際政治之壓力下作出讓步。林宜男、許佳惠，WTO 醫療專利與公共健康議題之研析——兼論我國未來之發展趨勢，清法科技法律與政策論叢，2卷1期，頁218(2005年)。Jem M. Spectar, *Patent Necessity: Intellectual Property Dilemma in the Biotech Domain and Treatment Equality for Developing Countries*, 24 Hous. J. Int'l L. 227, 265 (2002). William Baue, *Rio + 10 Series: UNAIDS Accelerating Access Initiative May Decelerate Access* (July 19, 2002) (unpublished manuscript, on file with Social Funds), available at <http://www.socialfunds.com/news/print.cgi?sfArticleId=887> (last visited Dec. 7, 2010).

¹⁶⁰ 林彩瑜(註81)，頁300。

若再加上發展中國家對於跨國製藥企業之規範亦面臨同樣之困境——亦即在經濟壓力下對於跨國製藥企業之內國管制往往規範較為寬鬆或無法徹底執行；故跨國製藥企業在缺乏適當制衡且 TRIPS 協定調和機制亦出現問題之前提下，便可能透過種種不適當之手段積極擴張智慧財產權之保障範圍以增加其利潤，同時也對藥物近用權利之保障形成嚴重威脅（詳見第肆節之討論）。

因此，在發展中國家因客觀缺乏能力（如缺乏製藥之科技能力）或主觀沒有意願（如優先追求經濟利益之成長甚於健康人權之保障），而無法或刻意迴避採取適當且有效之國家藥物政策，以平衡藥物智慧財產權政策對藥物近用權利之負面影響時，傳統國際人權法以國家為規範主體之架構，顯然已無法確保藥物近用權利之具體實踐；此時，跨國製藥企業對藥物近用權利保障責任之合法性與具體內涵，其與民眾藥物近用權利主張間之衝突，便成為一項重要議題¹⁶¹。

三、藥物近用權利影響因子之多元

在智慧財產權之影響下，整體藥物價格因缺乏學名藥生產之競爭而居高不下，並對藥物近用權利產生極大之負面影響；但值得注意的是，促進藥物近用之有效策略並不限於藥物價格之控制，而是由包括合理之選擇與使用（如研發創新、生產、品質控制）、可信賴之藥物供應系統（如適當分配網絡）、穩定之健康照護財務體系等連串因素所構成¹⁶²（詳見第貳節）。但這些因素中，除穩定之健

161 INT'L COUNCIL ON HUMAN RIGHTS, BEYOND VOLUNTARISM: HUMAN RIGHTS AND THE DEVELOPING INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATIONS OF COMPANIES 65 (2002).

162 According to Nathan Ford, "[e]ffective disease treatment relies on a long chain of factors, including R&D of appropriate medicines; production; quality control; adequate distribution networks; good drug supply management; reliable information for, and adequate training of, healthcare professionals; financial accessibility; and good patient compliance." Ford, *supra* note 126, at 137. WHO, *supra* note 41, at 15. WHO, *supra* note 60, at 2.

康照護財務體系為專屬政府部門之權責外，其餘因素在藥物市場之運作中，均有可能與跨國製藥產業之商業活動產生直接或間接之互動，並受其影響；因此，在藥物近用影響因子呈現多元之前提下，期望單純由國家負擔保障藥物近用權利之義務，顯然有所不足。

首先，如前節所述，目前 TRIPS 協定與相關規範在平衡藥物智慧財產權與健康人權之機制規劃中，似乎仍以價格與數量作為主要之考量因素，而忽略其他因素對藥物近用之影響；而該漠視也導致國家在利用例外規定以實踐其保障藥物近用權利義務時有所不足，僅能於有限範圍內（即僅涉及價格與數量之因素時）嘗試平衡不同典範之衝突。蓋理論上國家雖可利用強制授權機制使藥物之數量增加與價格下降，但若因該國之疾病型態、罹病機制、或生理機能特殊，而導致無適當之藥物提供，則強制授權機制便完全無用武之地¹⁶³；且藥品近用除實體與經濟之可近性外，尚包括品質控管，但強制授權製造之藥物卻可能因種種因素而不具備足夠之品質¹⁶⁴，而此亦非 TRIPS 協定關心之範疇。因此，TRIPS 協定在推論智慧財產權制度有利於藥物研發活動，或推論 TRIPS 例外條款有助於藥物智慧財產權與健康人權之平衡等結論時，便可能因忽略不同國家資源差異與健康不平等(health inequality)之複雜情況，而陷於武斷¹⁶⁵並忽略其並未賦予發展中國家足夠之政策工具以保障藥物近用權利。

其次，藥物市場之運作在藥物近用權利之保障中占有重要之地位，而藥物市場之運作普遍以自由競爭作為基礎，因此跨國製藥企

¹⁶³ 研究發現現有之國際智慧財產權制度對於發展中國家所亟需之藥物研發並無法發揮經濟上之誘因。Amy Kapczynski et al., *Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations*, 20 BERKELEY TECH. L.J. 1031, 1039 (2005).

¹⁶⁴ Matthews, *supra* note 141, at 137.

¹⁶⁵ 楊智傑（註76），頁83。

業多認為藥物近用權利之保障應為政府之人權義務¹⁶⁶，而不宜強制要求跨國製藥企業負擔與其商業行為無關之藥物近用權利保障義務¹⁶⁷。但問題在於藥物市場具有外部性(externality)、資訊不對稱性(information asymmetry)與不確定性(uncertainty)等可能造成市場失靈(market failure)之特性¹⁶⁸，故若仍將藥物近用權利之保障義務侷限於公共部門，而忽略私有部門（跨國製藥企業）之人權責任與參與空間，顯然並不利於該權利之保障：（1）藥物自由市場或跨國製藥企業之運作仍是以經濟利益最大化作為主要考量；因此，即令開發中國家民眾之生命與健康可能廣受某些特定疾病之威脅，但因其並無資力負擔負擔過高比例之健康照護費用，跨國製藥企業便無動機針對這類藥物進行研發，甚至有可能透過藥物智慧財產權制度而阻礙其他有意研發或進入市場者。以藥物之研究發展為例，研究發現在全球藥物研發之過程中，僅有10%之資源用於研發90%疾病（集中於發展中國家）所需之藥物¹⁶⁹；再就佔全球失能比例達16.4%之「受忽略疾病」(neglected diseases)¹⁷⁰——指對弱勢族群（如窮人）造成嚴重健康負擔(health burdens)之疾病（多為可治療之傳染性疾病）¹⁷¹——卻僅佔全球藥物研發資源之2-3%¹⁷²，其中更

166 Marianne Buckley, *Looking Inward: Regional Parallel Trade as a Means of Bringing Affordable Drugs to Africa*, 41 SETON HALL L. REV. 625, 662-63 (2011).
 Geralyn S. Ritter, *Are Drug Companies Living up to Their Human Rights Responsibilities? The Merck Perspective*, 7(9) PLOS MED. 1, 1 (published online in PLoS Medicine, e1000310. doi:10.1371/journal.pmed.1000310), available at <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000344> (last visited May 4, 2012).

167 Barbara Cochrane Alexander, *Lack of Access to HIV/AIDS Drugs in Developing Countries: Is There a Violation of the International Human Right to Health?*, 8(3) HUM. RTS. BRIEF 12, 12 (2001).

168 謝啟瑞，健康經濟學，頁9-11（1996年）。

169 PAUL HUNT, NEGLECTED DISEASES: A HUMAN RIGHTS ANALYSIS 38 (2007). 楊智傑（註76），頁83。

170 William W. Fisher & Talha Syed, *Global Justice in Healthcare: Developing Drugs for the Developing World*, 40 U.C. DAVIS L. REV. 581, 612 (2007).

171 受忽略疾病並無明確之定義。廣泛而言，其範圍主要包括熱帶病(tropical diseases)、瘧疾(malaria)、肺結核(tuberculosis)、AIDS、利什曼原蟲症

有80%係用於研發 AIDS 相關藥物¹⁷³。因此，在1975年至1999年間有高達99%之疾病（造成11.4%之全球健康負擔）是缺乏實質藥物研發資源投入與可治療之藥物近用¹⁷⁴。（2）即令國家有意全面滿足藥物近用權利之保障，但若無跨國製藥企業之協助，前者顯然並無足夠之資源廣泛介入研發創新、生產、價格訂定、產品配置、財務體系建立等多元影響藥物近用之相關變項。以前述受忽略疾病藥物之研發為例，國家雖然可以透過直接之資源挹注或間接之稅金減免、智慧財產權保障期間延長等方式，改變藥物研發之市場導向(market-driven)機制，並鼓勵製藥產業增加對受忽略疾病藥物之研發¹⁷⁵；但對於發展中國家而言，其提供基本藥物之資源與能力便已受到侷限，若仍僅著重於國家之人權義務保障者角色，要求其提供資源挹注於特定疾病之藥物研發，而忽略製藥企業之角色¹⁷⁶，則對於藥物近用權利之保障不啻緣木求魚¹⁷⁷。再如，即令印度之學名藥

(leishmaniasis)、昏睡病(sleeping sickness)、查加斯氏病(chagas disease)等。
Taiwo A. Oriola, *Strong Medicine: Patents, Market, and Policy Challenges for Managing Neglected Diseases and Affordable Prescription Drugs*, 7 CAN. J.L. & TECH. 57, 61 (2009).

172 Bernard Pecoul et al., *Access to Essential Drugs in Poor Countries: A Lost Battle?* 281(4) JAMA 361, 364-65 (1999); Patrice Trouiller et al., *Drug Development for Neglected Diseases: A Deficient Market and a Public-Health Policy Failure*, 359 LANCET 2188, 2189 (2002).

173 80% of neglected disease research spending is for HIV, malaria and TB, TND NEWS, (Mar., 2009), http://apps.who.int/tdr/svc/publications/tdrnews/issue-82/tdr-briefly#_80%_of_neglected (last visited Dec. 6, 2010).

174 Press Release, Médecins Sans Frontières, Drugs for Neglected Diseases Initiative: Teaming up to Address Neglect (Mar. 12, 2003), available at <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000343> (last visited Dec. 6, 2010).

175 HUNT, *supra* note 169, at 38.

176 如千年發展差距工作小組(MDG Gap Task Force)便主張國家與私有部門再藥物研究發展之合作，將對研究開發適當產品以因應影響發展中國家民眾之疾病，有莫大助益。UN, *supra* note 68, at 57-58.

177 WALTER STRAUS, SAFER, FASTER, CHEAPER: IMPROVING CLINICAL TRIALS AND REGULATORY PATHWAYS TO FIGHT NEGLECTED DISEASES (REPORT OF THE CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT'S WORKING GROUP ON CLINICAL TRIALS AND REGULATORY PATHWAYS) 17 (2011).

製藥產業十分發達，但其多數研發人員選擇至歐美國家工作，導致印度國內藥物研發基礎薄弱¹⁷⁸，以及外資擁有極高比例之藥物智慧財產權之現實¹⁷⁹，遂使印度在面對 TRIPS 協定之壓力與製藥產業之轉型時，無法兼顧民眾藥物近用權利之保障¹⁸⁰。另亦有學者指出，在較龐大之市場（如中國或印度），因中上階級便已形成足夠之市場規模以負擔相當之藥物價格，因此在逐漸轉向專利藥為主之市場時，對於中下階級之藥物近用權利保障便有賴國家對於藥物價格之管控機制加以保障¹⁸¹；但在藥物智慧財產權制度之設計（即使在嘗試平衡對公共健康之影響後）仍是以貿易自由化(trade liberalization)及效益主義(utilitarianism)為基礎之前提下¹⁸²，國家之藥價管控機制往往無法持續¹⁸³，因此製藥企業在藥物市場中之定價策略及利潤追求上之自我節制，便扮演十分重要之角色。

肆、跨國製藥企業與藥物近用權利之侵害

除前述因國家保障藥物近用權利之國際人權義務面臨具體落實之困境，因此有必要正視傳統以國家作為治理主體外，跨國製藥企業亦具備足夠之能力擴張藥物近用權利保障之空間，並彌補國家能力與資源之不足；另一個需要連結跨國製藥企業與藥物近用權利之原因，便在於跨國製藥企業本身或其與政府合作或共同投資經營之過程中，對藥物近用權利所形成之侵害與限制。蓋因跨國企業往往

178 Le-Nhung McLeland & J. Herbert O'Toole, *Patent Systems in Less Developed Countries: The Cases of Indian and the Andean Pact Countries*, 2 J.L. & TECH. 229, 237-38 (1987).

179 Diane Kroeger May, *Pharmaceutical Crisis in India: Transcending Profits with Human Rights*, 10(1) WIS. INT'L L.J. 40, 44-45 (1992).

180 *Id.* at 60-61.

181 謝季峰（註70），頁160。

182 吳全峰（註6），頁658。

183 謝季峰（註70），頁160。

在多數國家執行商業行為，故若其母國在人權保障與企業治理之相關措施上出現問題時，其負面影響將擴及多數被投資國，甚至使其被迫放棄既有之管制而形成人權保障之「競相逐底(race to the bottom)」現象¹⁸⁴。以藥物近用權利之保障為例，若母國對於跨國製藥企業之定價策略之透明化、製造品質之控管、或遊說過程之管制等，並無適當之規範，則企業不當行為對藥物近用之負面影響，將廣及該跨國製藥企業藥物銷售所及之所有國家¹⁸⁵。因此，若國家義務之具體實踐並無法期待時，跨國企業之人權責任將更形重要。

而跨國製藥企業對藥物近用權利之影響可能透過以下幾種方式呈現¹⁸⁶：

一、不適當之政策干預

跨國製藥企業對於藥物近用權利之侵害往往涉及多樣且複雜之

184 競相逐底之現象本是用於描述發展中國家為維持經濟上吸引外國投資之誘因，遂造成各國競相調降其內國勞動標準之現象。但本文認為該現象可能不僅限於勞動市場，而廣泛之人權保障與法律規範上亦可能出現類似之現象，故借用該觀念加以說明。Human Rights Watch, “Race to the Bottom”: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship, 18(8C) HUM. RTS. WATCH 1, 7, 70, 73 (2006), available at <http://www.hrw.org/en/news/2006/08/08/china-internet-companies-aid-censorship> (last visited Dec. 7, 2010). 陳彥君，跨國公司與國際勞動人權保障——管制類型的觀點，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁35（2009年）。

185 另如菸草控制框架公約(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)第13(1)條強烈要求各國應廣泛禁止廣告、促銷和贊助以減少菸草製品之消費，但因第13(2)條又規定因憲法原則而不能採取全面禁止措施之國家得僅採限制之手段，便賦予跨國菸草公司空間遊說菸草生產大國或發展中國家採取較為寬鬆之菸草廣告管制手段。因此，在跨國界貿易與網路發達之今日，各國對於菸草廣告禁止之不同步調（可能係因跨國菸草公司之遊說）或執法能力之不足（無法禁止跨界廣告），便將使 FCTC 所主張全面禁止菸草廣告之嚴格措施無法落實（內國居民仍可透過其他管道接觸菸草廣告），菸草控制政策之強度亦因此大幅下降。Framework Convention on Tobacco Control, U.N. Doc. A56/8. Geneva: WHO, Feb. 27, 2005.

186 以下僅以跨國製藥企業可能侵害藥物近用權利之主要型態作為討論核心，另如不適當之藥物研發資源配置、不適當之藥物行銷策略等，限於篇幅限制故不在本文中做詳細討論。

問題；但一般而言，跨國製藥企業往往憑藉其經濟實力，不適當地介入各國政治因素之運作，並遊說國家在政策之優先排序上，將僅具軟法(soft law)性質之藥物近用權利保障置於較不優先之地位。如美國藥價競爭與專利期間回復法案 (Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984，亦稱為 Hatch-Waxman Act) 之立法目的，原係希望透過藥價競爭(drug price competition)及回復專利期(patent term restoration)兩大規範主軸，一方面簡化學名藥申請許可上市之程序，藉此滿足消費者儘速取得較便宜學名藥之關切 (藥物近用權利之保障)；另一方面則透過允許新藥申請人之專利期間回復作為補償原開發藥廠之手段，繼續促進藥物之研發與創新活動，以尋求健康照護政策與藥物智慧財產權保護間之平衡¹⁸⁷。但在實際操作上，原開發藥廠卻利用包括上市審查因專利訴訟中止30個月¹⁸⁸、180日市場獨家銷售期間¹⁸⁹等手段阻撓學名藥進入市場¹⁹⁰，

¹⁸⁷ 吳全峰 (註6)，頁616-617。

¹⁸⁸ 學名藥廠必須於申請「簡略新藥許可申請」(Abbreviated New Drug Applications, 簡稱 ANDA) 之20天內，通知與其學名藥具相關性專利之專利權人與依據該專利開發新成份新藥之「新藥許可申請」(New Drug Applications, 簡稱 NDA) 所有人；若專利權人或 NDA 所有人可於收到通知後45天內提出專利侵權訴訟，食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)之上市許可審查則將自收到專利權人或 NDA 所有人之相關通知(notice)之日起中止30個月。詳見 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, 21 U.S.C. § 355 (j)(2)(A)(vii)(IV)、(j)(2)(B)、(j)(5)(B)(iii)。

¹⁸⁹ Hatch-Waxman Act 為鼓勵學名藥廠於排除專利爭議後儘速提出 ANDA 申請上市，以加速學名藥上市速度，並促進市場競爭，若學名藥廠提出上市許可申請，而專利權人（原開發藥廠）未於45日內提起專利侵權訴訟，或雖提起訴訟卻遭法院敗訴判決，則 FDA 便可核准學名藥廠之 ANDA 申請，且該第一家申請許可上市之學名藥廠便可因此於市場上販售該學名藥，並於180日內享有獨家銷售權(market exclusivity period)。詳見21 U.S.C. § 355 (j)(4)(b)(iv) (1984)。

¹⁹⁰ 舉例而言，在 Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corporation 乙案中，專利藥廠於收到學名藥廠所提出之上市申請後，便不斷提出增列專利於橘皮書(orange book)中（此即稱為遲延表列專利(late-listed patents)，並藉由不斷增列專利取得複數之30個月上市審查中止期間，以阻擋學名藥廠進入市場以延長其市場獨占期間。後醫療照護現代化法案（Medicare Prescription Drug Improvement and Modernization Act，以下簡稱 Medicare Act）已作出修正，將學名藥廠之 ANDA 審查僅會因原開發藥廠所提起之專利侵權訴訟而中止一次(single 30-month period)，從而避免原開發藥廠請求複數上市審查中止期間而

美國聯邦貿易委員會（Fair Trade Committee，以下簡稱 FTC）對此類反競爭行為亦曾提出報告¹⁹¹；但美國國會於2002年所提出之修正草案卻在製藥產業之龐大壓力下遭到否決¹⁹²，從而使得 Hatch-Waxman Act 之操作漸漸傾向藥物智慧財產權之保障，而規範藥價競爭之主軸便顯得相對模糊甚至是隱藏消失¹⁹³。另如醫療照護現代化法案（Medicare Prescription Drug Improvement and Modernization Act，以下簡稱 Medicare Act）禁止聯邦醫療保險(Medicare)¹⁹⁴運用其龐大之議價能力(bargain power)爭取低價產品（而必須由個別小型私人健康保險公司進行議價）¹⁹⁵，美國國會並非不理解此設計將導致藥價無法獲得實質之調降¹⁹⁶，但在製藥企業之遊說下仍將製藥

阻礙學名藥上市之可能。更多有關專利藥廠利用 Hatch-Waxman Act 相關機制延長專利保護之策略，可參見 *Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corporation*, 276 F.3d 1368 (2002)。楊代華，處方藥產業的法律戰爭——藥品試驗資料之保護，頁52-60（2008年）。黃慧嫻，專利連結(Patent Linkage)——藥品研發與競爭之阻力或助力？談藥品查驗登記程序與專利權利狀態連結之發展（上），科技法律透析，21卷2期，頁33-35（2009年）。

191 FDA, GENERIC DRUG ENTRY PRIOR TO PATENT EXPIRATION: AN FTC STUDY 39-64 (2002), available at <http://www.ftc.gov/os/2002/07/genericdrugstudy.pdf> (last visited May 15, 2012).

192 Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁219-220。

193 後 Medicare Act、Final Rule on Generic Drugs 及相關訴訟（如 *Torpharm, Inc. v. Shalala*、*Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corporation*、*Mova Pharmaceutical Corp. v. Shalala*）對於 Hatch-Waxman Act 中不當之管制手段進行修正或解釋，但其中仍存在許多灰色地帶。案件內容請參考 *Torpharm, Inc. v. Shalala*, 1997 WL 33472411 (D.D.C., 1997)、*Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corporation*, 276 F.3d 1368 (2002)、*Mova Pharmaceutical Corp. v. Shalala*, 140 F.3d 1060 (1998)。

194 聯邦醫療保險(Medicare)為美國為65歲以上民衆所設置之醫療健康保險計劃；但少數符合特定要件之65歲以下民眾亦可加入 Medicare，其中包括殘障者，永久性腎衰竭以及肌萎縮性脊髓側索硬化症（路葛雷克氏症）患者。Social Security Administration, Medicare 1 (2012), available at <http://www.ssa.gov/pubs/10043.pdf> (last visited May 15, 2012).

195 See generally Part D of Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act, Pub. L. No. 108-173, 117 Stat. 2066 (2003).

196 Lee H. Rosebush & Jonathan A. Havens, *Pharmacy Billing: The Importance of Establishing It Systems and Compliance Policies*, 14(3) J. HEALTH CARE COMPLIANCE 53, 53 (2012). Darius Lakdawalla & Wesley Yin, *Insurer Bargaining and Negotiated Drug Prices in Medicare Part D*, National Bureau of Economic Research (NBER)

產業之利益置於民眾藥物近用權利之上¹⁹⁷。

類似不當政策干預之情況亦廣泛出現在全球化之藥物市場運作中。以藥物智慧財產權與公共健康之平衡機制發展為例，由於限制藥物智慧財產權以保障健康人權之相關措施，將不可避免對跨國製藥企業之經濟利益產生極大之衝擊；因此，為維護市場上之（獨占）利潤與回饋，跨國製藥企業便利用其優越之經貿實力與強勢之市場地位¹⁹⁸，（1）或間接透過遊說母國／投資國（investor country/home country，多為已開發國家／製藥先進國），要求其利用市場開放或經貿制裁等經貿談判工具，以壓迫開發中國家承諾放棄行使 TRIPS 之例外規定或接受自由貿易談中之 TRIPS-plus 規範；（2）或藉由抽回企業本身於開發中國家之投資項目，以龐大之經濟壓力（economic coercion）直接脅迫居於市場弱勢之地主國／被投資國（host country，多為開發中國家），以迫使其放棄為保障健康人權而對藥物智慧財產權所施加之限制。若再考慮跨國製藥企業不限於藥物市場，甚至擴及其他投資面向之廣泛投資項目，其經濟實力與政治影響力甚至將遠超過其母國，使其在採取維護藥物智慧財產權或追求經濟利益之相關商業行動，直接地（如透過不當之定價策略）或間接地（如遊說本國政府施壓）¹⁹⁹限制或侵害民眾之藥物近用權

Working Paper 15330, 32, 2009, available at http://www.nber.org/papers/w15330.pdf?new_window=1 (last visited May 17, 2012). Milt Freudenheim, *A Benefit to Insurers*, N.Y. TIMES, Mar. 31, 2006, available at <http://www.nytimes.com/2006/03/31/business/31medicare.html?pagewanted=all> (last visited May 17, 2012). Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁226-228。

197 Erich Andreas Drotleff, *The Medicare Part D Prescription Drug Benefit: Who Wins and Who Loses?*, 8 MARQ. ELDER'S ADVISOR 127, 136-40 (2006). Jonathan Weisman, *Prescription Bill Fuels Lobbying Blitz on Hill: Competition Fierce for \$400 Billion Pot*, WASH. POST, June 13, 2003, at A6. Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁228。

198 跨國製藥企業之優勢經貿實力亦使其具備充分之能力得以運用不正當之競爭手段，排除學名藥廠進入市場或延續其市場獨占之期間；詳見後文第肆、二節之討論。

199 Crow, *supra* note 10, at ii15.

利之可能性大幅增加。

首先，就母國對跨國製藥企業之支持而言，不論是 FTA 之談判或開發中國家智慧財產權法規範之修訂，跨國製藥企業往往憑藉其優越經貿實力，間接透過母國展現其訴求，並以經貿壓力脅迫發展中國家接受不合理之藥物智慧財產權要求（如在 FTA 中要求加入 TRIPS-plus 條款），以達到其所期待之公共政策修正重塑之目標，並維持其商業上最大之經濟收益；也因此，FTA 之履行或內國法規範之修正，其結果往往較 TRIPS 協定更加遠離健康人權維護之本旨，並進一步侵害開發中國家民眾之藥物近用權利。如在美韓雙邊自由貿易協定之談判過程中，美國貿易代表署（United States Trade Representative，以下簡稱 USTR）便受到藥物研究與製造商美國協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，以下簡稱 PhRMA）之遊說與壓力²⁰⁰，在維護其本國製藥企業經濟利益之前提下²⁰¹，透過自由貿易協定之雙邊(bilateral)協商模式，要求韓國接受包括專利扣合(patent linkage)等 TRIPS-plus 機制²⁰²；而韓國在龐大之經濟利益誘惑與壓力下，亦不得不同意美國

200 由 PhRMA 所關心之議題觀察，包括資料專屬權、專利連結、藥物採用證明(Certificate of Pharmaceutical Product, CPP)、健康保險支付制度是否違反國民待遇原則、醫藥分業、學名藥以實際交易價格(actual transaction price, ATP)支付等，均已為美韓雙邊自由貿易協定知談判議題所涵蓋。USTR, NATIONAL TRADE ESTIMATE REPORT ON FOREIGN TRADE BARRIERS 2008, 339-40, 342, 345, available at http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2008/NTE/asset_upload_file365_14652.pdf (last visited Dec. 7, 2010).

201 Susan Scafidi, *Case Study: RESPONSE: The “Good Old Days” of TRIPS: The U.S. Trade Agenda and the Extension of Pharmaceutical Test Data Protection*, 4 YALE J. HEALTH POL’Y L. & ETHICS 341, 341 (2004).

202 其他相關納入專利扣合機制之自由貿易協定尚包括美國與中美洲自由貿易協定(CAFTA)第15.10(2)條、美國與約旦之自由貿易協定(US-Jordan FTA)第4(23)條、美國與新加坡之自由貿易協定(US-Singapore FTA)第16.8(4)(c)條、美國與智利之自由貿易協定(US-Chile FTA)第 Article 17.10(2)(b)-(c)條、美國與澳洲之自由貿易協定(US-Australia FTA)第17.10(5)條、美國與摩洛哥之自由貿易協定(US-Morocco FTA)第15.10(4)條；以及目前正在進行談判之美國與馬來西亞之自由貿易協定(US-Malaysia FTA)。吳全峰（註6），頁610-13。Correa, *supra* note 151, at 401.

針對藥物智慧財產權保障之諸多要求——包括美韓 FTA 第18.9.1條中承諾專利扣合制度之實施，及第5.2條承諾對學名藥之支付價格應以市場競爭價格(competitive market-derived prices)為原則——以換取其他經濟利益（如要求美國修改貿易救濟之規定）²⁰³。但學者便批評，韓國在藥物智慧財產權之退讓，將大幅延後較便宜學名藥在發展中國家之上市時程²⁰⁴，甚至完全排除學名藥製造之可能性，使美國跨國製藥企業之市場獨占優勢得以維持，同時也對韓國民眾近用藥物之權利形成嚴重負面影響²⁰⁵。或有論者認為，TRIPS-plus 條款均為開發中國家在自由意志下所自願接受、簽訂之 FTA 內容，因此即使其協商過程背後有跨國製藥企業之介入，仍無法遽然認為其有不正義之情形²⁰⁶；但問題在於，在經貿實力不對等之前提下，不僅不能期待 FTA 談判過程之公平性，更無法期待開發中國家在接受相關雙邊協議時能行使多少自由意志²⁰⁷。尤有甚者，有鑑於開發中國家往往不願或沒有能力投入已然有限之資源承擔相關爭端訴訟之成本，跨國製藥企業便透過遊說其母國運用貿易制裁或提出爭端訴訟等手段，迫使開發中國家對執行 TRIPS 例外規定所規範之公共健康措施採取較為保守甚至是放棄之立場²⁰⁸；如巴西²⁰⁹、南

203 在美韓雙邊自由貿易協定談判之過程中，因美國市場對於韓國實具有一定之重要性（美國是韓國之第三大貿易伙伴，第二大出口市場，第三大進口國，也是外資來源的第一名），在覬覦美國龐大之市場及東亞其他國家之競爭壓力下，便同意美國針對藥物專利權保障之許多要求，以換取更大之經濟利益。William H. Cooper & Mark E. Manyin, *The Proposed South Korea-U. S. Free Trade Agreement*, CRS Report for Congress, 4-6 (Aug. 2, 2006), available at http://www.sice.oas.org/TPD/USA_KOR/Studies/CRSREPORT_e.pdf (last visited on Nov. 23, 2010). Schott et al., *supra* note 157 at 10.

204 Galantucci, *supra* note 147, at 1103-04.

205 陳美利，專利制度與公共衛生需求之調和——以醫藥物專利相關制度之發展為核心，東吳大學法學院法律學系碩士論文，頁3（2005年）。

206 Matthew Turk, *Bargaining and Intellectual Property Treaties: The Case for a Pro-Development Interpretation of TRIPS But Not TRIPS Plus*, 42 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 981, 1005-12 (2010).

207 Pogge, *supra* note 91, at 75-76.

208 林彩瑜（註81）文，頁291。

209 巴西為有效防治 AIDS，遂藉由當地製藥產業之自製能力與產能，大量生產便

非²¹⁰、泰國²¹¹在嘗試援引國際藥物智慧權體系下之強制授權規範，藉以生產廉價學名藥以確保民眾受國際人權法保障之近用藥物權利時，均受到 PhRMA 之嚴重干擾，包括向 USTR 提出訴願 (petition) 要求將這三個國家列於特別301條款之觀察名單中²¹²，以貿易制裁 (trade sanctions) 作為威脅手段，強迫其停止符合 TRIPS 協定義務例外排除之相關措施²¹³；其中美國甚至對巴西依 WTO 爭端解決規則與程序了解書之規定提出控訴申請²¹⁴。

其次，除母國之支持外，跨國製藥企業亦已具備足夠之經濟實力，得獨自以撤資或提起國內訴訟等手段，直接對發展中國家施壓

宜之愛滋病學名藥 (ARV)，導致藥物之價格大幅下降 (達82%)；但美國認為巴西之專利法授權當地公司製造專利藥物違反 TRIPS 協定，且對進口產品歧視而屬保護主義措施，因此除貿易制裁之威脅外，亦於2000年透過 WTO 提出訴訟。林彩瑜，貿易與公共衛生之法律問題——世界貿易組織法律研究 (二)，頁22-31 (2009年)。倪貴榮，WTO 智慧財產權保護與公共健康議題之發展趨勢，經社法制論叢，31期，頁135 (2003年)。

210 南非為解決AIDS之健康問題，遂修正相關法規允許衛生部門跨越 (override) 醫療產業之智慧財產權保障，以平行輸入之方式自國外引進價格較便宜之AIDS藥物，並透過強制授權之方式於國內製造價格較便宜之AIDS學名藥；但跨國製藥企業認為南非之修正案容許其政府剝奪專利藥廠之智慧財產權且不需加以補償，不僅違反南非憲法第25條之規定，亦違反TRIPS協定第27條有關專利權保護客體不應歧視之規定，遂於南非法院提起訴訟；而美國及歐盟亦以貿易制裁為威脅手段施壓南非修改其法規。林彩瑜 (註81)，頁294-295。陳美利 (註205)，頁32。Kara M. Bombach, *Can South Africa Fight AIDS? Reconciling the South African Medicines and Related Substances Act with the TRIPS Agreement*, 19 B.U. INT'L L.J. 273, 273-306 (2001).

211 泰國在針對心臟病藥物Kaletra進行強制授權時，美國雖然同意泰國之作為並未違反WTO之相關規範，但仍將泰國置於特別301條款之特別觀察名單中，認為其未對智慧財產權提供適當之保障，並以貿易制裁作為威脅泰國停止強制授權之手段。Office of the U.S. Trade Representative, 2007 Special 301 Report 27 (2007). Ed Silverman, *US Trade Rep: Thailand on Watch List*, *Pharmalot*, Apr. 30, 2007, available at http://www.pharmalot.com/2007/04/us_trade_rep_thailand_on_watch/ (last modified on Oct. 28, 2009).

212 See generally, Silverman, *supra* note 211.

213 OXFAM, *supra* note 13, at 22.

214 雖然在種種因素之考量下 (如國際輿論壓力)，美國最終撤銷相關訴訟並停止貿易制裁或報復等手段威脅，但其在PhRMA之支持下，仍不斷利用雙邊貿易談判之機會，要求開發中國家採取TRIPS-plus規範以保障其製藥產業之發展。Joseph, *supra* note 19, at 445-46. Galantucci, *supra* note 147, at 1091.

以迫使其修正立場。舉例而言，跨國製藥企業便以停止投資作為威脅，企圖影響巴西政府要求降低 AIDS 藥物價格，及企圖援引內國專利保護法之強制授權條款以自行製造之立場²¹⁵；而南非醫藥製藥者協會(South Africa Pharmaceutical Manufacturers Association)及39家跨國製藥企業亦聯合於南非法院對南非政府提起訴訟，主張南非政府允許平行輸入之法案違反 TRIPS 協定及南非憲法²¹⁶。我國在藥物智慧財產權與藥物近用權利之衝突調和上，亦面臨同樣之挑戰：如在藥事法修正增訂第40-2條並賦予新成分新藥5年之資料專屬權保護時²¹⁷，因考量資料專屬權對於學名藥進入市場之時程與民眾藥物近用權利均有負面影響²¹⁸，故立法院便明確表達不應給予新成分新藥以外之任何新藥資料專屬權保障²¹⁹。但歐洲商會（European Chamber of Commerce Taipei，以下簡稱 ECCT）仍持續施壓並連續於其立場報告(position paper)中提出建議，指出台灣政府應給與藥物之新適應症3年之獨立資料專屬權保護²²⁰（但歐盟本身對於新適

215 Editorial, *Brazil Fights for Affordable Drugs Against HIV/AIDS*, 9(5) Revista Panamericana de Salud Pública 331, 333 (2001), available at <http://www.paho.org/english/dbi/es/v9n5-tema-brazil.pdf> (last visited Dec. 6, 2010).

216 陳美利（註205），頁32。

217 藥事法第40條第2項：「新成分新藥許可證自核發之日起五年內，其他藥商非經許可證所有人同意，不得引據其申請資料申請查驗登記。」同條第3項：「新成分新藥許可證核發之日起三年後，其他藥商得依本法及相關法規有關藥品查驗登記審查之規定提出同成分、同劑型、同劑量及同單位含量藥品之查驗登記申請，符合規定者，得於新成分新藥許可證核發屆滿五年之翌日起發給藥品許可證。」

218 鄭慧文、余萬能、林鴻柱，藥品新適應症資料專屬權適法性之探討，醫事法學，18卷1期，頁37（2011年）。

219 對於新成分新藥以外的新藥，例如新療效、新複方、新使用途徑的新藥，原本行政院案擬藥事法修正案時，亦賦予3年資料專屬權保護年限，但未獲立法院支持。行政院經濟建設委員會，「2011年台灣白皮書」議題辦理情形，頁13-9（2011年6月22日），<http://www.cepd.gov.tw/dn.aspx?uid=10347>（最後瀏覽日：2012年5月17日）。楊代華（註190），頁219-21。黃慧嫻（註190），頁33-35。

220 EUROPEAN CHAMBER OF COMMERCE TAIPEI, 2011-2012 POSITION PAPERS 137 (2012), available at <http://www.ecct.com.tw/file/Publications/201110141812114963.pdf> (last visited May 20, 2012).

應症亦僅給予1年之保護)²²¹；美國商會（American Chamber of Commerce in Taipei，以下簡稱 AmCham）亦透過白皮書(white paper)呼應 ECCT 擴張資料專屬權保護範圍之訴求，並進一步要求我國醫藥法制應增設專利扣合制度以便實質延長對於原開發廠專利藥物之保護期間²²²。

前述影響國家健康照護或智慧財產權政策之行為（不論直接或間接），均凸顯出跨國製藥企業在維護藥物智慧財產權及其商業利益時，所可能採取政策干預手段之廣泛及對公共健康議題影響之深遠；因此，若忽略跨國製藥企業在藥物近用權利保障上所應負擔之人權責任，而仍以國家作為落實藥物近用權利之核心主體，則可能正當化跨國製藥企業嘗試影響政策以廣泛限制學名藥進入市場、提高專利藥保障門檻等行為，而對民眾藥物近用權利產生極大之限制。

二、不適當之藥物定價策略

藥物市場有其特殊性²²³，其一是資訊不對等 (information

221 各國對於新適應症資料保護之規定如下：

國家名稱	法規名稱	新適應症資料專屬權保護期限
美國	Hatch Wasman Act 21 USC 355(C)(3)(D)(ii)、(iii)、(iv)	3年
歐盟	Directive 2001/83/EC	1年
日本	日本藥品管理條例第18-3條	4年
南韓	Article 26-2 of Pharmaceutical Affairs Law	4年
紐西蘭、澳洲、 中國、新加坡、 加拿大		NO

鄭慧文、余萬能、林鴻柱（註218），頁37。

222 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN TAIPEI, 2011 TAIWAN WHITE PAPER 100 (2011).

223 除本文所述之資訊不對等與低價格彈性外，藥物市場尚有外部性、不確定性、政府之高度干預等特性；而這些特性，基本上為醫療保健市場所共有之

asymmetry)，因製藥企業對於藥物應運用於何種疾病之治療與預期之結果擁有較一般民眾更多之醫療專業知識²²⁴；其二是藥物市場之產品與健康或生命具有緊密且不可替代之關聯性（尤其是第三線抗生素或治療特殊疾病之專利藥物），使其價格需求彈性(price elasticity of demand)偏低而不易受到價格變動之影響²²⁵。這些特性，搭配藥物智慧財產權之市場獨占，遂使藥物市場失靈(market failures)之現象更形嚴重，並導致藥物之供需失衡。因此，當跨國製藥企業強調其營利之商業性質，並主張其不應負擔健康人權保障等與其追求經濟利益極大化目標相違背之責任時²²⁶，該主張在藥物市場失靈之前提下便不具有正當性——主要原因便在於，企業增加利潤之商業行為應建立在消費者所獲得之資訊充分且購買行為屬自願(willing)之前提下，始具有其正當性；但若在資訊不對等且價格彈性偏低之影響下，利用其市場獨占之地位賺取超越其藥物研發或製造之不合理利潤，其正當性便有值得進一步檢視之空間²²⁷。如人權委員會特別報告員在對秘魯有關健康人權之觀察報告中，便對跨國製藥企業利用其受藥物智慧財產權保障之市場獨占地位，訂定非一般民眾所能負擔之高昂藥價，對民眾近用可負擔藥物(affordable medicines)之權利形成人權障礙(human rights obstacles)，表達高度之關切與憂慮²²⁸；而此亦突顯出跨國製藥企業與藥物近用權利間不可

特性。謝啟瑞（註168），頁9-11。

224 謝啟瑞（註168），頁10。

225 張清溪、許嘉棟、劉鶯釗、吳聰敏，經濟學——理論與實際（上冊），頁106-107（2000年）。

226 JEFFERY ROBINSON, PRESCRIPTION GAMES: MONEY, EGO AND POWER INSIDE THE GLOBAL PHARMACEUTICAL INDUSTRY 20 (2001) (quoting Bernard Lemoine, director-general of France's National Pharmaceutical Industry, "I don't see why special effort should be demanded from the pharmaceutical industry. Nobody asks Renault to give cars to people who have not got one.").

227 Joseph, *supra* note 19, at 436.

228 如在Paul Hunt對秘魯有關健康人權之報告中，便強調在秘魯與美國所簽訂之自由貿易協議(Free Trade Agreement, FTA)中，要求秘魯提供較TRIPS協定更為嚴格(TRIPS-plus)之藥物智慧財產權保障，可能使跨國製藥企業藉此針對所

避免之緊密關係²²⁹，亦突顯其商業行為應受規範之必要性。

以 Hazel Tau v. GlaxoSmithKline, Boehringer 乙案為例²³⁰，南非競爭委員會便發現 GlaxoSmithKline（以下簡稱 GSK）及 Boehringer Ingelheim（以下簡稱 BI）在治療 AIDS 之逆轉錄病毒藥物（antiretrovirals，以下簡稱 ARVs）市場中，各佔 82.4%（nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors，以下簡稱 NRTIs）及 52%（non-nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors，以下簡稱 NNRTIs）之佔有率²³¹；但若再以科學證據顯示不同 ARVs 間並不具有替代性，則 GSK 及 BI 之市場佔有率將達 100%，兼以該（替代性低）藥物之價格需求彈性偏低，GSK 及 BI 將享有完全之市場獨占與絕對之價格支配能力。而在相關國際比較中，GSK 及 BI 更被發現利用其市場優勢(market dominance)訂定遠比其他發展中國家之專利藥或學名藥價格(international best price offer – branded /generic product)為高之藥物價格（見表一）。

有「新用途(new use)」之藥物重新主張20年之專利權保障期間，或要求秘魯政府成立全國性藥物智慧財產權之管制機構(a national drug regulatory body)，從而得以進一步延緩或阻止該國價格上可負擔學名藥(generic medicines)之生產與供應。Paul Hunt, *Right of Everyone to Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health: Mission to Peru*, Para. 48, U.N. Doc. E/CN.4/2005/ 51/Add.3 (Feb. 4, 2005).

229 KHOSLA & HUNT, *supra* note 11, at 9.

230 Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at para. 60.5.

231 THE CENTRE FOR APPLIED LEGAL STUDIES (CALS), THE PRICE OF LIFE. HAZEL TAU AND OTHERS V. GLAXOSMITHKLINE AND BOEHRINGER INGELHEIM: A REPORT ON THE EXCESSIVE PRICING COMPLAINT TO SOUTH AFRICA'S COMPETITION COMMISSION 38 (2003), available at http://www.aidslex.org/site_documents/T012E.pdf (last visited Nov. 25, 2010).

表一 ARVs 藥物價格之比較²³²

	Product	Price sold to private sector	International Best Price Offer—branded product	WHO pre-qualified generic	International Best Price Offer—generic
Adult Formulations Per Tablet / Capsule					
	AZT (300mg)	US\$ 0,92	US\$ 0,60	US\$ 0,25	US\$ 0,19
GSK	Lamivudine (150mg)	US\$ 1,02	US\$ 0,32	US\$ 0,14	US\$ 0,09
	AZT/lamivudine (300mg/150mg)	US\$ 1,27	US\$ 0,85	US\$ 0,36	US\$ 0,28
BI	Nevirapine (200mg)	US\$ 0,57	US\$ 0,60	US\$ 0,23	US\$ 0,15
Annual Costs Per Adult Or Child					
	AZT (300mg)	US\$ 674,52	US\$ 438,00	US\$ 180,00	US\$ 140,00
	Lamivudine (150mg)	US\$ 741,59		US\$ 100,00	US\$ 66,00
			US\$ 234,00		
GSK	AZT/lamivudine (300mg/150mg)	US\$ 926,98	US\$ 620,50	US\$ 265,00	US\$ 204,00
	AZT (50mg/5ml solution)	US\$ 528,14	—	US\$ 160,60	—
	Lamivudine (10mg/ml solution)	US\$ 408,47	—	US\$ 113,88	—
BI	Nevirapine (200mg)	US\$ 417,14	US\$ 438,00	US\$ 166,00	US\$ 112,00

另，雖然 GSK 及 BI 拒絕提供研發成本之相關資訊²³³，但南非競爭委員會從已透漏之初步證據(powerful prima facie evidence)卻不難發現藥物研發與定價間之關係十分薄弱，且其因高昂之藥價所獲得之利潤亦遠高於正常之收益範圍(a normal rate of return)²³⁴。相關研究則進一步發現，假設 GSK 宣稱其2001年總收入之14.85%用於藥物研發(R&D costs)、14%用於技術移轉權利金(licensing fee)、16.2%則為其利潤(profits)，因此其藥物之生產成本(manufacturing

232 Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at paras. 33-44.

233 Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at para. 64.

234 Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa), at para. 65.

costs)為總收入之 $(100\%-14.85\%-14\%-16.2\%)=54.95\%$ ，因此其藥物之售價便為該藥物生產成本之 $(100\% / 54.95\%)=1.82$ 倍²³⁵。依照此標準，假設 lamivudine (150mg)之生產成本為0.14美元（此標準係採學名藥廠所願意提供經 WHO Access to HIV/AIDS Drugs and Diagnostics of Acceptable Quality 計畫認可符合一定品質之 lamivudine 學名藥之最佳藥價(WHO pre-qualified generic)），則其合理利潤之售價應為 $(0.14 * 1.82) \div 0.25$ 美元；但 lamivudine (150mg)在南非之藥價卻為1.02美元（見表一），其利潤高達400%。而此價格係在藥物研發成本、生產成本等相關資訊不明下所作出之推算；設若藥物之研發成本較14.85%更低，則跨國製藥企業之利潤將更為驚人。

但藥物市場之資訊不對稱與低替代性所造成之市場失靈，卻未在 TRIPS 協定相關規範或調和機制中完整地納入規範考量；雖然公共健康議題曾被提及，但 TRIPS 協定主要仍以國際貿易規範之角度思考藥物智慧財產權制度之建立，遂不免使藥物智慧財產權與藥物近用權利間產生鴻溝²³⁶。因此，如何避免跨國製藥企業濫用其藥物智慧財產權所賦予之市場獨占地位，排他地任意訂定遠超出低度開發國家民眾所能負擔之藥物價格，並造成民眾無法輕易取得與其生命健康密切相關之基本藥物，便為國際人權規範下藥物近用權利保障之重要議題。

三、不適當之藥物智慧財產權保護手段

對跨國製藥企業而言，延長專利藥之智慧財產權保障並延後學名藥上市之時程，為延續其商業利益之重要手段；但不適當之藥物智慧財產權手段卻可能直接與民眾之藥物近用權利保障產生衝突。以美國 Hatch-Waxman 之發展為例，原開發藥廠於申請 NDA 時需

235 THE CENTRE FOR APPLIED LEGAL STUDIES (CALS), *supra* note 231, at 38.

236 林彩瑜（註209），頁54-55。吳全峰（註6），頁633。

提供其專利藥之相關專利資訊登錄於 Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence (又稱為橘皮書(Orange Book))中²³⁷,以作為未來學名藥廠開發學名藥、申請許可上市時專利迴避之依據²³⁸;但原開發藥廠卻浮濫將專利資訊登錄於橘皮書中,造成學名藥廠進入市場之實質障礙²³⁹。FTC 之調查亦發現,原開發藥廠與學名藥廠可能透過協議之方式濫用藥物智慧財產權之保障以達到市場獨占地位之延續^{240、241}——如由原開發藥廠給付高額之和解金,以交換學名藥廠承諾不於一定期間推出學名藥²⁴²;或由原開發藥廠與學名

237 橘皮書中所登載之內容包括(1)藥品安全性及有效性之完整調查報告(full reports of investigations which have been made to show whether or not such drug is safe for use and whether such drug is effective in use);(2)藥物完整成分之明細(a full list of the articles used as components of such drug);(3)完整敘述藥物之組成(a full statement of the composition of such drug);(4)完整敘述製造、組成、包裝藥物之方法與設備(a full description of the methods used in, and the facilities and controls used for, the manufacture, processing, and packing of such drug);(5)若FDA要求,應附上藥物及其成分之樣本(such samples of such drug and of the articles used as components thereof as the Secretary may require);(6)使用於藥物之標籤樣本(specimens of the labeling proposed to be used for such drug);(7)其他依Federal Food, Drug, and Cosmetic Act §505(B)規定所要求進行之評估(any assessments required under section 505B)。21 U.S.C. § 355 (b)(1) (2004)。

238 楊代華(註190),頁53。

239 因學名藥廠若利用橘皮書中所登載之專利項目以製造學名藥,則登記該專利項目之原開發藥廠即可藉此提出專利訴訟,並享有 Hatch-Waxman Act 所賦予之30個月上市許可審查中止期間(不論訴訟勝負)。21 U.S.C. § 355 (j)(5)(B)(iii) (2004)。楊代華(註190),頁53-54。Marcia Angell 著,曾育慧譯(註14),頁212。

240 黃慧嫻,淺析美國藥品上市審查程序之專利連結機制及其實施對我國可能產生之影響(上),科技法律透析,18卷6期,頁2(2006年)。

241 後 Medicare At 雖對相關原開發藥廠與學名藥廠合作之方式有所規範,包括要求原開發藥廠與學名藥廠間之任何協議,必須向 FTC 及司法部(Department of Justice)通報;但須注意者為,Medicare Act 並非完全禁止原該發藥廠與學名藥廠間之協議,主要是因為該等協議往往涉及專利權之保障,而專利權之本質本就在賦予專利權人專屬獨佔市場之地位及因此獲取利益之權利,故不宜遽然認定該類協議即造成市場競爭之障礙。黃文鴻,藥品許可證與專利權資訊扣合機制之研究,頁36,行政院衛生署九十六年度委託科技研究計畫 DOH96-TD-D-113-024 (2007年)。

242 如在 Valley Drug v. Geneva Pharmaceuticals 乙案中,Abbott Laboratories 擁有

藥廠合作生產品牌學名藥(branded generic drug)或授權學名藥(authorized generic drug)，以控制其價格與銷售²⁴³。

進一步，在目前製藥科技進步且繁複之前提下，一項藥物所涉及之專利可能十分密集，亦使得眾多專利間互相形成障礙的危險性大增（此即專利叢林(patent thicket)之現象）²⁴⁴；因此，即令政府有意願意有資源介入藥物研發，跨國製藥企業卻仍有可能以其所掌握之既有藥物智慧財產權，對包括政府在內之其他有意進行藥物研發者（尤其是受忽略疾病之藥物研發）或生產者提起訴訟，而形成進入市場之障礙，並造成民眾近用藥物之權利受到實質限制。舉例而言，NF-kB 訊息傳導途徑(NF-kB cell signaling pathway)對包括癌

Hytrin 藥品之相關專利，Geneva Pharmaceuticals 及 Zenith Goldline Pharmaceuticals 分別依 Hatch-Waxman Act 提出 Paragraph IV ANDA，而 Abbott Laboratories 亦提出專利侵權訴訟。後 Abbott Laboratories 與 Zenith Goldline Pharmaceuticals 達成和解，並於和解契約中約定（1）Zenith Goldline Pharmaceuticals 承諾除非有其他廠商合法於市場中銷售 Hytrin 之學名藥或 Hytrin 之專利到期，Zenith Goldline Pharmaceuticals 將不會銷售任何 Hytrin 之學名藥，或轉讓其上市許可相關之權利；（2）Abbott Laboratories 承諾於一定期間內，每三個月給付 Zenith Goldline Pharmaceuticals 美金6,000,000元。後 Abbott Laboratories 亦與 Geneva Pharmaceuticals 簽訂類似之和解契約。由於該和解契約之約束，即使 Geneva Pharmaceuticals 及 Zenith Goldline Pharmaceuticals 贏得專利侵權訴訟之勝訴判決，其亦無法於市場中銷售 Hytrin 之學名藥；而由於無任何之商業行銷活動，便導致180日市場獨家專屬期間無法起算；因此 Valley Drug Co.（Hytrin 之經銷商）便主張該三家公司之和解契約係屬違反公平交易之行為並違反反托拉斯法(Sherman Act)。雖然初審法院在本案件中認為該三家公司所作之和解契約係屬水平競爭者瓜分市場之行為，應認屬違反反托拉斯法之行為；但上訴法院卻認為本案涉及專利權之保障，而專利權之本質本就在賦予專利權人專屬獨佔市場之地位及因此獲取利益之權利，則不宜在未經詳細分析獨占之效果及相關因素便遽以認定該和解契約係當然(per se)違反反托拉斯法。Valley Drug v. Geneva Pharmaceuticals, 350 F.3d 1181 (2003). 黃文鴻（註242），頁33。

²⁴³ 黃文鴻（註242），頁34。

²⁴⁴ Amy Kapczynski et al., *Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations*, 20 BERKELEY TECH. L.J. 1031, 1053-54 (2005). Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross-Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, in *INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY* 119 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2000).

症、骨質疏鬆、動脈硬化等疾病之治療機轉有基本之重要性（因其對多數細胞之存活至關重要），因此幾乎所有針對這些疾病之治療與藥物均有可能與 NF-kB 相關之智慧財產權有關；也因此，當 Ariad Pharmaceutical（NF-kB 之專利權人）針對多數藥廠提出侵權訴訟時，其影響不可謂不大。另如美國藥廠 Astra-Zeneca 在其所生產之藥物 Prilosec（佔全球銷售量首位之胃灼熱治療藥物）之專利權即將屆滿前，便同時控告多家學名藥廠侵犯其產品之二線專利（包括活性代謝物(active metabolites)²⁴⁵專利），並導致學名藥廠因被法院判定侵權（如侵犯 Prilosec 膠囊膜衣專利）而放棄上市²⁴⁶。而類似之障礙並不限於藥物本身之成份內容²⁴⁷，尚及於藥物研究或生產時所需要之工具與設備。

另就國際藥物智慧財產權之規範設計而言，其本就有利於居市場強勢主導地位者，若再加上 TRIPS 協定之例外規定有設計上之限制與矛盾（詳見第參節之說明），遂使跨國製藥企業得以利用其中之模糊空間，極度擴大藥物智慧財產權之保障範圍以極大化其經濟利益之追求，而忽略對藥物近用權利之侵害。舉例而言，TRIPS 協定第31(h)條及第31(j)條有關強制授權之規定，主張會員國在實施強制授權時，應「考慮各個專利之經濟價值下，針對個別情況應給付相當報酬（即權利金(remuneration)與權利人」²⁴⁸，且「有關權利

245 所謂活性代謝物是指病患服用藥品後在體內所產生之化合物。

246 Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁214-45。

247 如有關新適應症資料專屬權之保障，雖有論者認為將鼓勵製藥企業對於已知藥物進行更深入之研究，以促進醫藥產業進步；但亦不否認，該權利可能被專利藥廠濫用以作為阻擾他人進入市場之工具，亦成為開發中國家與已開發國家間之重要歧見來源。Arti K. Rai, *Proprietary Rights and Collective Action: The Case of Biotechnology Research with Low Commercial Value*, in INTERNATIONAL PUBLIC GOODS AND TRANSFER OF TECHNOLOGY UNDER A GLOBALIZED INTELLECTUAL PROPERTY REGIME 292 (Keith E. Maskus & Jerome H. Reichman eds., 2005). JOHN P. GRIFFIN & JOHN O'GRADY, *THE TEXTBOOK OF PHARMACEUTICAL MEDICINE* 353 (2002). Susan K. Sell, *supra* note 146, at 194, 212.

248 Article 31(h) of the TRIPS, "...the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the

金之決定，應由會員司法機關審查，或由其上級機關為獨立之審查」²⁴⁹；但此規定不啻將強制授權正當性之判斷，從會員國得於未損及他國利益之前提下，基於主權得自行認定「國家緊急危難或其他緊急狀況(national emergency or other circumstances of extreme urgency)」²⁵⁰ 必要性(necessity)²⁵¹之主導權，轉移至製藥企業手中²⁵²。詳言之，在 TRIPS 協定第31(j)條之規定下，強制授權之正當性判斷，某種程度從由進口會員國（買方，主要為發展中國家）掌控較大權力以決定是否具備「國家緊急危難或其他緊急狀況」等必要性條件以及後續之市場進入權利之買方市場機制，轉移到由具備較大議價能力(bargain power)之出口會員國或製藥企業來決定是否出售或決定價格之賣方市場機制²⁵³。但在由買方市場轉移到賣方市場之過程中，專利權人（製藥企業）得藉由杯葛權利金之補償額

authorization.”

249 Article 31(h) of the TRIPS, “... any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member.”

250 Article 31(b) of the TRIPS, “... to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly.”

251 Doha宣言第5(c)段便強調，所謂緊急急迫之情形，除國家自行有權決定判斷外，並例示包括HIV/AIDS、結核病、瘧疾及其他傳染病之流行均可視為國家處於緊急情況或其他極度危急環境。Paragraph 5(c) of the TRIPS, “Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.”

252 Alan O. Sykes, *TRIPS, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha "Solution"*, 3 CHI. J. INT'L L. 47, 57 (2002).

253 牛惠之（註137），頁38。

度而達到質疑強制授權正當性之目的²⁵⁴，亦使得製藥企業之（私人）經濟利益有機會凌駕 WTO 例外規定希望平衡健康人權與自由貿易之核心（公共）價值。因此，跨國製藥企業是有可能亦有機會因追求自身之經濟利益，而濫用其經濟實力嘗試限制發展中國家利用強制授權相關規定，並導致 TRIPS 協定原本對具備藥物需求之發展中國家所設定之權利保障範圍受到實質限縮²⁵⁵。雖然2003年決議第3段已暫時豁免希望使用強制授權之適格醫藥物進口國（eligible importing Member，即符合條件之進口成員方）²⁵⁶之權利金補償義務；但醫藥物出口國（exporting Member，即使用2003年決議之制度生產醫藥產品並出口到「適格醫藥物進口國」之成員方）²⁵⁷仍需依據 TRIPS 協定第31(h)條規定，在考量醫藥物進口國之經濟水準並結合考慮該強制授權所帶來之經濟價值，給予專利權人（製藥企業）充分的報酬²⁵⁸。換言之，當符合條件的進口成員方對同一產品行使強制許可時，該成員方可不支付專利權人相當補償金之理由，並非排除 TRIPS 第31(h)條之規定，而係由於出口方已

254 牛惠之（註137），頁37-38。

255 Correa, *supra* note 151, at 400-02.

256 所謂「符合條件的進口成員方」係指任何最不發達成員國家方，以及任何向 TRIPS 理事會發出通知，表明其希望使用此制度作為進口方意願的成員方。按照規定，成員方可在任何時候通知 TRIPS 理事會它將全部或有限制性地使用該制度（例如隻在國家緊急狀態、其他特別緊急情況或公共非商業性使用場合才使用）。Paragraph 1(b) of the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.

257 Paragraph 1(c) of the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.

258 Paragraph 3 of the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, “Where a compulsory licence is granted by an exporting Member under the system set out in this Decision, adequate remuneration pursuant to Article 31(h) of the TRIPS Agreement shall be paid in that Member taking into account the economic value to the importing Member of the use that has been authorized in the exporting Member. Where a compulsory licence is granted for the same products in the eligible importing Member, the obligation of that Member under Article 31(h) shall be waived in respect of those products for which remuneration in accordance with the first sentence of this paragraph is paid in the exporting Member.”

支付相關補償；也因此，在2003年決議之規範下，強制授權正當性之判斷仍同樣受到 TRIPS 協定第31(h)條及第31(j)條之制約（2003年決議第9段）²⁵⁹，亦即專利權人（製藥企業）仍得藉由杯葛權利金補償額度而質疑強制授權正當性（僅是質疑對象由實施強制授權之開發中國家，轉移至出口醫藥產品至實施強制授權國家之製藥先進國家），跨國製藥企業阻礙健康人權在國際藥物智慧財產權制度下保障之可能性，並未能因此獲得緩減。而跨國製藥企業的確也可能利用藥物智慧財產權體系下平衡健康人權保障機制之漏洞——不論該漏洞是為尋求會員國共識所刻意製造之模糊空間，抑或是法規範制定之闕漏——嘗試挑戰強制授權並尋求其商業利潤；如開發中國家一般認為權利金補償額度應為營業額或毛利之1%-5%，但已開發國家卻認為其比例應為5%-10%²⁶⁰，其間之差異便可能構成日後爭執之焦點。

由前述案例不難發現，單純依賴國家政策或 TRIPS 協定顯然並無法完善調合處理藥物智慧財產權保障與公共衛生政策之衝突，亦無法完全避免跨國製藥企業之濫用；因此，藉由跨國製藥企業健康人權責任之建立，應可某種程度補充 TRIPS 協定例外條款之不足，並呼應發展中國家主張經濟典範（藥物智慧財產權之保障）並不宜作為無限上綱之絕對價值。

259 Paragraph 9 of the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, “This Decision is without prejudice to the rights, obligations and flexibilities that Members have under the provisions of the TRIPS Agreement other than paragraphs (f) and (h) of Article 31, including those reaffirmed by the Declaration, and to their interpretation. ...”

260 JAMES LOVE, COMPULSORY LICENSING: MODELS FOR STATE PRACTICE IN DEVELOPING COUNTRIES, ACCESS TO MEDICINE AND COMPLIANCE WITH THE WTO TRIPS ACCORD paras. 39, 40 (Jan. 21, 2001), *available at* www.cptech.org/ip/health/cl/recommendedstatepractice.html (last visited May 15, 2012).

伍、跨國製藥企業是否應負擔藥物近用權利保障之人權責任？

綜前兩節所述，因國家角色在藥物近用權利之保障上有其侷限性（第參節），而跨國製藥企業亦可能因商業利益之追求或商業手段之不當而直接或間接地侵害民眾之藥物近用權利（第肆節）；因此，跨國製藥企業在藥物近用權利之保障上所應扮演之角色，便引起諸多討論。如 MDGs 便認為藥物近用權利之內涵不盡然均係專屬於國家公部門之權責，包括可負擔之藥物價格、可信賴之藥物供應系統、合理之藥物研發清單等，均可能與跨國製藥企業之商業活動產生直接或間接之互動；因此主張不應僅單純強調國家保障藥物近用權利之人權義務，而應進一步重視國家與製藥產業之合作以提供發展中國家經濟上可負擔之基本藥物²⁶¹。CESCR General Comment No. 14第48段亦強調，對健康人權之侵害雖可能由國家不當之法律或行政行為所直接造成，但其他社會實體(entities)卻也有可能因國家管制不當或鬆散，而有實質侵害健康人權之行為²⁶²；因此，第42段及第45段便主張，締約國和其他能夠提供國際援助與經濟、技術合作之行為者(actors)——包括公民社會各個組成部分，如政府間與非政府組織、公民社會組織、私營企業²⁶³——對健康人權之實踐亦負有責任，並應協助發展中國家落實其健康人權之保障義

261 U.N., *supra* note 68, at ix, 51, 54-55, 63.

262 Paragraph 48 of General Comment No. 14, “Violations of the right to health can occur through the direct action of States or other entities insufficiently regulated by States. ...”

263 Paragraph 40 of General Comment No. 14, “While only States are parties to the Covenant and thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, including health professionals, families, local communities, intergovernmental and non-governmental organizations, civil society organizations, as well as the private business sector - have responsibilities regarding the realization of the right to health. State parties should therefore provide an environment which facilitates the discharge of these responsibilities.”

務²⁶⁴。學者亦認為若缺乏政府、非政府組織、企業之三方合作，而僅將藥物近用問題之解決視為國家遵守 ICESCR 之最終義務，則將對該權利之保障形成不可預期之負面影響，且無法期待政府之公共健康政策能產生實際之效果²⁶⁵。因此，為回應 MDGs 所提「與製藥企業合作以提供發展中國家可負擔之基本藥物」²⁶⁶之內容，聯合國人權委員會特別報告員(Special Rapporteur) Paul Hunt 便於2010年草擬「製藥企業與藥物近用之人權準則」(Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relation to Access to Medicines，以下簡稱 Guidelines for Pharmaceutical Companies)²⁶⁷，要求國家以外之所有國家與國際行為者(national and international actors)——包括製藥企業——均應擔負保障藥物近用之人權責任^{268·269}（詳見第

264 Paragraph 45 of General Comment No. 14, “For the avoidance of any doubt, the Committee wishes to emphasize that it is particularly incumbent on States parties and other actors in a position to assist, to provide ‘international assistance and cooperation, especially economic and technical’ which enable developing countries to fulfil their core and other obligations indicated in paragraphs 43 and 44 above.”

265 Patricia H. Werhane & Michael E. Gorman, *Intellectual Property Rights, Access to Life-Enhancing Drugs, and Corporate Moral Responsibilities*, in *ETHICS AND THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY* 275 (Michael A. Santoro & Thomas M. Gorrie eds., 2005).

266 Target 8e of the MDGs, “In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries.”

267 Published in the report to the General Assembly of the UN Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard of health. U.N. General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, U.N. Doc. A/63/263 (Aug. 11, 2008).

268 Preamble of the Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relation to Access to Medicines.

269 在此需要說明者為，就跨國企業之人權責任基礎究竟應為條約法、習慣法、國際法原則，學界尚有爭論；惟限於篇幅，且此議題並非本文之討論重點，故本文並無法進行深入之分析。但本文認為，既然相關國際人權文件對跨國企業人權責任之規範，已建立多數國家所承認之國際法一般法律原則，則應可依此作為主張跨國製藥企業應負擔藥物近用權利保障之人權責任之基礎。舉例而言，「跨國公司及其他工商企業在人權方面的責任準則」(Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights，簡稱 Norms for TNCs) 第1條已規定，「跨國公司和

陸節之討論)。

問題在於，即令國際間對於跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任已展開討論（但尚無共識）；但對於相關義務之架構與具體內涵卻仍嫌過於空泛與模糊：包括國家在藥物近用權利保障上之困境，是否必然標示著跨國製藥企業應負擔與國家一致之義務範圍？跨國製藥企業所應負擔尊重、保障、實踐藥物近用權利之國際人權責任具體內涵為何？跨國製藥企業應對於藥物近用權利之人權責任究係屬具強制力規範之法律責任(legal responsibilities)抑或僅具宣示性質之道德責任(moral responsibilities)？藥物近用權利作為受益權(positive rights)，跨國製藥企業所應負擔之人權責任強度是否適合與保障防禦權(negative rights)之人權責任強度相當？廣泛且道德陳義過高之跨國製藥企業人權責任標準，雖然看似對完整地保障民眾藥物近用權利，但在現實中是否可能面臨具體落實困難程度過高之困境？因此，本文便嘗試從跨國企業之人權責任出發，嘗試逐一檢視跨國製藥企業對藥物近用權利所應負擔之國際人權義務之範圍、內容、與架構。

其他工商企業在其各自之活動與影響範圍內，有義務促進並確保國際法和國內法承認人權之實現、尊重、與保障」；而聯合國人權委員會(United Nations Commission on Human Rights, UNCHR)更進一步建議經濟社會理事會(Economic and Social Council)應將 Norms for TNCs 視為具法律地位之文件，並認為跨國企業對於其核心活動(core activities，如涉及勞動權與環境權之保障)或因其而發生之衍生活動(derivative activities)，均應負擔人權之法律責任(legal liability)。再加上聯合國人權委員會亦已草擬「製藥企業與藥物近用之人權準則」(Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relation to Access to Medicines，以下簡稱 Guidelines for Pharmaceutical Companies)，對跨國製藥企業保障藥物近用權利之國際法原則有所規範。類似之國際人權文件應足以建立多數國家公認且合乎邏輯之規則，而跨國製藥企業對於受 ICESCR 所保障之藥物近用權利，自應依國際法原則而負擔相關人權責任。U.N. ECOSOC, *Sub-Comm'n on the Promotion and Prot. of Human Rights, Responsibilities of Transnational Corporations and Related Business Enterprises with Regard to Human Rights*, U.N. Doc. E/CN.4/2004/116 (Apr. 22, 2004). Melina Williams, *Privatization and the Human Right to Water: Challenges for the New Century*, 28 MICH. J. INT'L L. 469, 490-91 (2007). Nwobike, *supra* note 8, at 137.

一、跨國企業在人權體系之地位

在深入討論跨國製藥企業在藥物近用權利體系中之地位前，本節首先需要界定國際組織對跨國公司與人權保障責任之態度與回應。

傳統上，國際人權法係以國家為基本單位而合意制定，故亦以國家做為主要規範對象²⁷⁰——如政治與公民權利公約（International Convention on Civil and Political Rights，以下簡稱 ICCPR）第2條²⁷¹及 ICESCR 第2(1)條²⁷²——均以國家作為人權義務之主體，並以主權國家為基本單位嘗試規範國家間關係(inter-state relations)與建立良好秩序；僅在特殊之情境下——如戰爭罪(war crime)、違反人道罪(crime against humanity)、殘害人群罪(genocide)²⁷³、酷刑罪(torture)²⁷⁴、使人為奴隸罪(slavery)²⁷⁵、強制勞動罪(forced labor)²⁷⁶、種族隔離罪(apartheid)²⁷⁷、強迫失蹤罪(forced disappearances)²⁷⁸等——始例外以個人做為人權之義務主體²⁷⁹。加

270 1 OPPENHEIM'S INTERNATIONAL LAW: PEACE 19 (Robert Jennings & Arthur Watts KCMG QC eds., 2008).

271 Article 2(1) of the ICCPR, "Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

272 ICESCR, *supra* note 93, at article 2(1).

273 *See, e.g.*, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

274 *See, e.g.*, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

275 *See, e.g.*, Article 8 of the ICCPR, and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery.

276 *See, e.g.*, Article 8 of the ICCPR.

277 *See, e.g.*, Programme of Action Against Apartheid, U.N. SCOR, 38th Sess., Supp. for Oct.-Dec. 1983, at 58, 63, U.N. Doc. S/16102 (1983) (calling on "corporations and employers" to "withdraw from any commercial operations in South Africa").

278 *See, e.g.*, Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons.

279 STEVEN R. RATNER & JASON S. ABRAMS, ACCOUNTABILITY FOR HUMAN RIGHTS ATROCITIES IN INTERNATIONAL LAW 13 (2001). 姜皇池（註21），頁377。

上國際人權通常被視為公領域(public realm)之事項而對政府治理民眾之行為有所約束，對企業之私領域(private realm)商業行為通常不予干涉並由市場規則予以規範（法規範之功能僅在維持自由市場之平等性與自由性）²⁸⁰。因此，跨國企業——指在多數國家經營之經濟實體，不論其法律形式、本國(home country)或活動所在國(country of activity)、單獨或集體經營²⁸¹——多被認為仍應以遵循本

280 RALPH G. STEINHARDT, PAUL L. HOFFMAN & CHRISTOPHER N. CAMPONOVO, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAWYERING: CASES AND MATERIALS 662 (2009).

281 廣義之跨國企業係指所有之國際性商業營利組織，並不以公司型態出現者為限；亦不僅以某特定國家為其母國，而可能為數個依據不同國家法律所設立之公司而組成之關係企業集團，且該集團可能為公有、私有或混合形式者，均屬之。近年來之發展，更進一步將「多國籍」僅作為跨國企業之判斷標準之一，而主張任何工商企業若與跨國公司有任何關係，或其活動之影響不完全限於當地，則應視為廣義之跨國企業並負擔人權保障之責任。因此，跨國公司應可定義為「包括於不同國家設立經營據點或分公司(branch offices)或子公司(subsidiaries)，並為商業活動之單一跨國公司；或非單一跨國公司，但在形式上分屬單一或複數國家所成立之各自獨立之公司或其他實體，但於業務上彼此密切相連，且由單一或少數公司或個人掌控整體業務協調、資源指揮調度機制之企業集團」。Paragraph 20 of the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, “The term ‘transnational corporation’ refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries - whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.” Paragraph 21 of the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, “The phrase ‘other business enterprise’ includes any business entity, regardless of the international or domestic nature of its activities, including a transnational corporation, contractor, subcontractor, supplier, licensee or distributor; the corporate, partnership, or other legal form used to establish the business entity; and the nature of the ownership of the entity. These Norms shall be presumed to apply, as a matter of practice, if the business enterprise has any relation with a transnational corporation, the impact of its activities is not entirely local,” Paragraph 6 of the Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, “... Multinational enterprises include enterprises, whether they are of public, mixed or private ownership, which own or control production, distribution, services or other facilities outside the country in which they are based. ...” 陳俊仁，公司社會責任之國際法實踐——論跨國企業監理套利規範之演繹與規範困境，中華國際法與超國界法評論，4卷2期，頁421（2008年）。

國法律規範為主，而不具國際人權法之主體地位²⁸²，亦不需負擔實踐國際人權之法律義務。

然而，在經濟全球化之現實環境下，世界秩序主要由主權獨立國家運作並維持之概念被逐漸打破，國際貿易將跨國界之個人與環境緊密地串連起來²⁸³，使得主權國家必須面對權力受到限制或干涉之複雜環境，面對監督與保障人權之義務受到多元之挑戰²⁸⁴，遂使跨國企業之人權責任漸受重視。從跨國企業對世界經濟之影響力來觀察，跨國企業(multinational enterprises (MNEs) / transnational corporations (TNCs))之總產值約佔全球 GDP 之10%，而出口額約佔全球出口總值之44%²⁸⁵；因此，作為經濟全球化之主要推動力，跨國企業在經濟領域已逐漸較（具政治權力之）國家佔有更具優勢且決定性之地位²⁸⁶。尤其在國際關係已從政治、軍事實力之競爭轉移至經濟實力之競爭後，跨國公司作為國際上深具實力之經濟實體，不僅對國家內部事務擁有日益升高之影響力，對於個人人權之保障亦展現深遠之影響²⁸⁷。

也因為跨國企業憑藉其充沛之經濟資源，不僅可對國際人權之保障作出正面貢獻²⁸⁸，相對地亦有能力大規模地涉入嚴重人權侵害

282 姜皇池（註21），頁390。

283 Carolyn Dresler & Stephen P. Marks, *The Emerging Human Rights to Tobacco Control*, 28(3) HUM. RTS. Q. 599, 634 (2006).

284 Ellen R. Shaffer et. al., *Global Trade and Public Health*, 95(1) AM. J. PUB. HEALTH 23, 23 (2005).

285 詳言之，跨國企業之數量已由1970年之7,000家迅速攀升至1995年之40,000家，目前則有將近64,000跨國企業，且在各國擁有870,000家分支機構；資源與權力則大幅集中於少數企業手中——目前跨國企業之總產值約為3.4兆美元（約佔全球 GDP 之10%），而出口額則為2.8兆美元（約佔全球出口總值之44%）；且全球約1/4之資產係由300家跨國企業所擁有，1/2之投資由25家跨國企業所掌握。Picciotto, *supra* note 21, at 6-7.

286 SUSAN STRANGE, *THE RETREAT OF THE STATE* 47 (1996).

287 Ratner, *supra* note 279, at 462.

288 舉例而言，跨國企業可藉由促進貿易之自由流通、創造開發中國家工人之就業機會並提高工資，擴大開發中國家民眾可利用購買社會財貨（如食物、健

之情事（而非僅是傳統侵權法上對少數個人之權利侵害）²⁸⁹；因此，傳統國際人權法之國家主義模式所映照出之體系架構（將國際人權之義務主體侷限於國家而忽略跨國企業之影響）便相對顯得不夠充分且不實際²⁹⁰，亦開始受到不同法院之挑戰²⁹¹。如在 *Doe v. Unocal* 乙案中，跨國企業(Unocal)知悉並協助當地軍政府（緬甸）進行強制勞動等違反國際人權典範之行為（如提供情資與物資予緬甸軍隊），便被美國法院認為係對人權之直接侵犯並應對該人權犯行負責²⁹²；在 *Sosa v. Alvarez-Machain* 乙案中（涉及墨西哥籍醫師被美國政府綁架），美國最高法院除承認國際習慣法(international customary laws)可為普通法所為請求(common law claims)之基礎外²⁹³，更進一步主張應考慮「國際法之範圍是否應擴張至個人或企業之違反行為」²⁹⁴，並被引作為後續主張企業人權責任之基礎²⁹⁵；

康熙護等）之財富與資源，並藉此作為增長經濟與解決貧困之動力，間接藉由活絡之經濟活動與自由貿易達到人權保障之目的。See, e.g., AMRITA NARLIKAR, *THE WORLD TRADE ORGANIZATION: A VERY SHORT INTRODUCTION* 2, 28-29 (2005). William H. Meyer, *Human Rights and MNCs: Theory Versus Quantitative Analysis*, 18 HUM. RTS. Q. 368, 368 (1996).

289 這種兩難局面便形成跨國企業與人權典範間之緊張關係。Geoffrey Chandler, *The Evolution of the Business and Human Rights Debate*, in *BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: DILEMMAS AND SOLUTION* 22, 28-29 (Rory Sullivan ed., 2003).

290 Arghyrios A. Fatouros, *On the Implementation of International Codes of Conduct: An Analysis of Future Experience*, 30 AM. U. L. REV. 941, 951 (1981).

291 For example, the Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy court considered that “corporations may also be held liable under international law, at least for gross human rights violations.” Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc., 244 F. Supp. 2d 289, 319 (S.D.N.Y. 2003).

292 *Doe v. Unocal*, 395 F.3d 978 (2003). 但需注意者為此案因 Unocal 與原告 Earthrights International 達成和解，法院並未做出終局判決及有關跨國企業人權責任之具體結論。

293 *Sosa*, 542 U.S. at 729.

294 According to the Supreme Court, “A related consideration is whether international law extends the scope of liability for a violation of a given norm to the perpetrator being sued, if the defendant is a private actor such as a corporation or individual.” *Sosa v. Alvarez-Machain*, 542 U.S. 692, 729 (2004).

295 Katherine Gallagher, *Civil Litigation and Transnational Business*, 8 J. INT’L CRIM. JUST. 745, 752 (2010).

在 *Ngcobo v. Thor Chemicals Holdings Ltd.* 乙案中，英國法院對於跨國企業在南非因疏於採取適當措施，導致工人受可預測之水銀毒害而侵害其健康人權時，亦採取類似之立場²⁹⁶。

再從國際人權法規範觀察，UDHR 第30條對於人權義務主體之規定，亦強調個人(person)、集團(group)應與國家同樣受到該宣言之規範，而不得有任何破壞本宣言所載之任何權利和自由之活動或行為²⁹⁷；因此，該條項可被視為隱含將（跨國）企業納入國際人權規範之意圖。既然在國際人權法已嘗試廣泛地將國家以外之集團及個人均納入規範時，則跨國企業作為獨立之法人且有能力為企業之行為負責（如負擔民事侵權責任），實無法律上之理由認為跨國企業可豁免其國際人權責任²⁹⁸。除 UDHR 外，因近來跨國企業於國際人權侵害事件所扮演之決定性角色逐漸被揭露，故要求跨國企業負擔國際人權義務(obligation)——或至少是國際人權責任(responsibility / accountability)²⁹⁹——之聲浪便逐漸興起，並被相關國際文件所承認³⁰⁰。舉例而言：

- (1) 2000年公佈之「聯合國全球盟約」(United Nations Global Compact)³⁰¹，便嘗試透過一項策略性、抽象性之政策提案，

²⁹⁶ *Ngcobo v. Thor Chemicals Holdings Ltd.*, [1995] T.L.R. 10 (Eng. C.A.).

²⁹⁷ Article 30 of the UDHR, “Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.”

²⁹⁸ Beth Stephens, *The Amoralism of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, 20 BERKELEY J. INT’L L. 45, 77-78 (2002).

²⁹⁹ 由於跨國企業在國際人權體系中所應扮演之角色仍有諸多爭議，因此多數國際文件與學術討論均避免較有法律強制意味之「義務(obligation)」一詞，而改用較為中性之「責任(responsibility / accountability)」一詞代替。

³⁰⁰ Geoffery Chandler, *The Evolution of the Business and Human Rights Debate*, in *BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: DILEMMAS AND SOLUTIONS* 26 (Rory Sullivan ed., 2003).

³⁰¹ Press Release, Secretary General Proposes Global Compact on Human Rights, Labour, Environment, in address to World Economic Forum in Davos, U.N. Doc.

要求跨國企業凝聚共識並共同遵守國際人權、勞動標準、環境保護等國際原則³⁰²，以引導跨國企業之商業行為邁向更美好之人權標準。

- (2) 2003年聯合國促進與維護人權小組(UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights)進一步通過「跨國公司及其他工商企業在人權方面的責任準則」(Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, 簡稱 Norms for TNCs)³⁰³，對於跨國企業之人權責任採取較為廣泛且明確之規範立場³⁰⁴，例示包括平等機會與非歧視待遇

SG/SM/6881 (Feb. 1, 1999), *available at* <http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.html> (last visited Dec. 4, 2010).

- 302 TNCs are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles:

- (A) Human Rights: (1) Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and (2) make sure that they are not complicit in human rights abuses.
- (B) Labour: (3) Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; (4) the elimination of all forms of forced and compulsory labour; (5) the effective abolition of child labour; and (6) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
- (C) Environment: (7) Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; (8) undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and (9) encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.
- (D) Anti-Corruption: (10) Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

United Nations Global Compact, The Ten Principles of the UN Global Compact, *available at* <http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/index.html> (last visited Dec. 4, 2010).

- 303 U.N. ECOSOC, Sub-Comm'n on the Promotion and Prot. of Human Rights, Fifty-fifth Session, Economic, Social and Cultural Rights: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights (hereinafter "the Norms for TNCs"), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (Aug. 26, 2003).

- 304 Chandler, *supra* note 300, at 26.

(right to equal opportunity and non-discriminatory treatment)、人身安全權利(rights of security of persons)、勞工權利(rights of workers)、消費者保障(consumer protection)、環境保護(environmental protection)等。同時，在執行層面亦要求跨國企業於活動及影響範圍(sphere of activity and influence)內，應定期彙報並採取其他措施充分執行本準則³⁰⁵，並受國際與國家機制之定期監督與核查³⁰⁶，且對因未能遵從準則而受不利影響之個人、實體或社區應提供立即、有效與適當之賠償³⁰⁷。雖 Norms for TNCs 僅為準則而不具法效性³⁰⁸，但一般認為該準則對於跨國企業應所負起之人權責任之內涵具有實質闡釋之意義，並作為聯合國「保護、尊重、實踐之企業與人權框架」(“Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights，以下簡稱 Business and Human Rights Framework)之基礎。

- (3) 2011年聯合國人權理事會(Human Rights Council)通過人權與跨國公司及其他工商企業問題秘書長特別代表(Special Representative of the Secretary-General “on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises”) John Ruggie 所提之「企業與人權指導原則」(Guiding Principles of Business and Human Rights，以下簡稱 Guiding Principles)³⁰⁹，並宣示包括國家應負擔保障人權之

³⁰⁵ Paragraph 15 of the Norms for TNCs.

³⁰⁶ *Id.* at Paragraph 16.

³⁰⁷ *Id.* at Paragraph 18.

³⁰⁸ 聯合國人權委員會(Human Rights Council)之後甚至拒絕就該準則採取行動，並另行設立人權與跨國公司和其他工商企業問題秘書長特別代表(Special Representative of the Secretary-General “on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises”)一職，以著手一個新的進程(即後文所提企業與人權指導原則(Guiding Principles of Business and Human Rights))。

³⁰⁹ Human Rights Council, Seventeenth Session, Guiding Principles on Business and

義務(the state duty to protect human rights)、企業應負擔尊重人權之責任(the corporate responsibility to respect human rights)、應廣泛建立企業侵犯人權案件中之救濟途徑(the need for greater access to remedy for victims of business-related abuse)三大原則³¹⁰。該指導原則除要求國家本身必須採取適當措施以防止、調查、處罰及救濟其管轄範圍內之私人行為者(企業)對人權之侵害³¹¹，國家對於其所擁有或控制之企業、由國家提供實質性支援之企業(business enterprises that receive substantial support and services from State agencies)、與國家簽訂契約之企業應負擔有效監督之責任並以確保該企業尊重人權³¹²。進一步，該指導原則亦重覆強調企業尊重人權(包括消除商業行為可能對人權產生之負面影響)之責任³¹³，包括明確界定企業所應負擔人權責任之範圍泛指國際公認之人權內涵，且最低限度應包括國際人權憲章(International Bill of Human Rights)及國際勞工組織(International Labour Organization)通過之工作中基本原則與權利宣言(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)³¹⁴、說明企業可能造成人權侵害之商業活動應同時包括作為與不作為³¹⁵，更重要的是賦予企業關於人權保障之合理注意義務(human rights due diligence)³¹⁶——如企業應確認

Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (hereinafter “Guiding Principles”), UN Doc. A/HRC/17/31 (Mar. 21, 2011). 本指導原則係人權與跨國公司及其他工商企業問題秘書長特別代表 John Ruggie 針對實施聯合國「保護、尊重、實踐之企業與人權框架」所提之最終報告。

310 *Id.* at Paragraph 6.

311 *Id.* at Annex (I)(A)(1).

312 *Id.* at Annex (I)(B)(4), (5) & (6).

313 *Id.* at Annex (II)(A)(11), (15) & (16).

314 *Id.* at Annex (II)(A)(12).

315 *Id.* at Annex (II)(A)(13).

316 *Id.* at Annex (II)(B)(17)-(21).

其所造成之人權負面影響是否來自於供應商或客戶之經營背景，是否涉及特定業務、產品或服務，同時亦需確認相關些因素對人權影響之程度³¹⁷。最後，國家必須採取適宜措施（包括立法、行政、司法或非司法等方式）確保因企業活動而受有人權侵害之受害者獲得有效救濟³¹⁸；且企業亦應建立或參與有效之申訴機制(grievance mechanism)³¹⁹，以便使相關救濟結果可以得到立即且直接之落實。

- (4) 經濟合作開發組織（Organization for Economic Co-operation and Development，以下簡稱 OECD）亦於1976年通過並多次修正「跨國企業準則」（Guidelines for Multinational Enterprises，以下簡稱 Guidelines for MNEs）³²⁰，除一般性要求跨國企業應依據地主國政府的國際義務及承諾尊重受其業務活動影響者之國際人權外³²¹，亦明確例示跨國企業之義務應包括定期且充份揭露相關資訊(disclosure)³²²、勞動關係(employment and industrial relations)中勞動人權之保障（如消除任何形式之強制勞動及童工）³²³、環境保護(environmental protection)³²⁴、打擊賄賂(combating bribery)³²⁵、消費者權益

317 *Id.* at Annex (II)(B)(17).

318 *Id.* at Annex (III)(A)(25). 進一步，相關救濟程序應確保其有效性，包括應具備合法、可獲得性、可預測性、平等性、透明度、權力兼容、參與與對話等要件。*Id.* at Annex (III)(A)(31).

319 *Id.* at Annex (III)(B)(29).

320 本準則係附於「OECD 國際投資暨多國企業宣言與決議」(OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises)。The OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises: Basic Texts: Guidelines for Multinational Enterprises (hereinafter “Guidelines for MNEs”), OECD DAF/IME (2000) 20 (Nov. 8, 2000).

321 *Id.* at chapter II paragraph 2.

322 *Id.* at chapter III.

323 *Id.* at chapter IV.

324 *Id.* at chapter V.

325 *Id.* at chapter VI.

(protecting consumer interests)保障³²⁶等；在執行層面之規範亦較為具體，包括設立「國際投資暨多國企業委員會」(the Committee on International Investment and Multinational Enterprises)³²⁷及各國之「國家聯絡點」(National Contact Points)³²⁸，除針對指導綱領範圍內各事項交換意見並提出年度報告外，並可在特殊情況(specific instances)下提供相關法律或便利於達成共識及非對抗性之方法（如和解或調解），以協助企業界、勞動組織及其他有關當事人處理與本準則相關之爭議³²⁹。

- (5) 在特定領域中，如國際勞工組織（International Labour Organization，以下簡稱 ILO）於1977年通過之「跨國企業與社會政策原則之三方宣言」（Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy，以下簡稱 Tripartite Declaration）³³⁰及1998年通過之「工作基本原則與權利宣言」（the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work），便要求跨國公司應尊重各國之勞動人權，並將特定勞動標準定位企業應盡之特有責任：如平等機會與待遇(equality of opportunity and treatment)³³¹、就業安全(security of employment)之權利保障³³²、符合基本

326 *Id.* at chapter VII.

327 Section II of the OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises: Decisions of the OECD Council, OECD DAF/IME (2000) 20 (Nov. 8, 2000).

328 *Id.* at section I.

329 The OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises: Basic Texts: Decisions of the OECD Council: Procedural Guidance, OECD DAF/IME (2000) 20 (Nov. 8, 2000).

330 Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (hereinafter Tripartite Declaration), 17 I.L.M. 422 (1978) (amended 2000, 2006).

331 *Id.* at paragraphs 21-23.

332 *Id.* at paragraphs 24-28.

需求的生活工資(living wage)³³³、最低勞動年齡(minimum age)之尊重³³⁴、勞動安全與衛生條件(safety and health)³³⁵、結社自由(freedom of association and the right to organize)之保障³³⁶等。

雖然前述國際文件對於跨國企業之國際人權責任規範多屬自願性、非拘束性之軟性道德規範，其執行與落實多仍需依賴各國內國法之配合（即跨國企業之間接人權責任，詳見後文第陸-二節之討論）與非政府組織（non-governmental organizations，以下簡稱NGOs）之監督³³⁷，使跨國企業之直接人權責任仍不明確且有所保留；但其仍提供跨國企業國際人權責任之體系輪廓與有限之執行機制³³⁸，並對後續分析跨國製藥企業與藥物近用權利間之關係，提供（除國際貿易典範外）國際人權典範之理論與政策基礎。

二、跨國製藥企業在健康人權體系之地位

從前節之分析不難發現，相關國際文件對於跨國企業之人權責

³³³ *Id.* at paragraphs 33-35.

³³⁴ *Id.* at paragraph 36.

³³⁵ *Id.* at paragraphs 37-40.

³³⁶ *Id.* at paragraphs 42-48.

³³⁷ STEINHARDT, HOFFMAN & CAMPONOV, *supra* note 280, at 714.

³³⁸ 舉例而言，Norms for TNCs 第18段主張跨國企業應對由於未能遵從該準則而遭受不利影響之個人、實體與社區提供立即、有效和適當之賠償（“[i]n connection with determining damages, in regard to criminal sanctions, and in all other respects, these Norms shall be applied by national courts and/or international tribunals, pursuant to national and international law”），且其亦允許不同主體（包括政府、企業、勞工團體、工會、NGOs、公眾團體）提出調查跨國企業是否遵守 Norms for TNCs 相關規定之主張。Guidelines for MNEs 主張建立之國家聯絡點(National Contact Points)除可作為經驗交流之平臺，亦可為解決在具體情況下與本準則之實施有關而出現之人權侵害問題提出有效及時且符合適用法律之建議，並負責實際調查跨國企業可能侵犯人權事件之相關程式。進一步，在各介入方同意之情況下，可嘗試取得各方認可非對抗性手段（例如調解或仲裁）以處理相關問題；若各介入方未能就出現相關問題達成一致見解，則可發佈聲明或提出有關執行準則之適當建議。

任似已有較為充分且正在進行之討論；但檢視目前有關跨國企業之人權責任之架構，卻不難發現就健康人權保障之部分卻顯得相對薄弱——如 *Guidelines for MNEs* 僅要求跨國企業針對其員工採取適當的步驟以確保其職業健康及安全³³⁹以及一般性對公共健康環境之管理制度³⁴⁰，並未提及跨國企業是否有類似國家在資源許可範圍內漸進滿足健康人權之義務。換言之，相較於跨國企業一般人權責任之討論——其多將重心置於國際人權之防禦功能面與跨國企業之不應作為；對於給付功能面向為主之健康人權保障，跨國企業是否亦應負擔積極作為並投入資源以保障該受益權利，學界與實務界並無太多之討論³⁴¹。尤其有關跨國製藥企業與藥物近用權利間之關係，相關討論多仍以傳統國際法上作為人權保障義務主體之國家為核心³⁴²，對於跨國製藥企業是否應負擔藥物近用權利之保障義務未有相對應比重之重視——如 *Guidelines for MNEs* 在智慧財產權與公共健康議題之關注上，僅要求跨國企業提供有關企業活動潛在健康影響之資訊，並與受影響之社區進行協商³⁴³；但類似之空泛規範對於如何要求跨國企業調整智慧財產權保障之策略以實踐其藥物近用權利保障之責任並未提供具體操作之可能性。尤其 *Guidelines for MNEs* 進一步規定跨國企業人權責任之實踐尚需符合國際協定與所在國法律或行政慣例之框架³⁴⁴；因此，在 TRIPS 協定與 FTAs 等規範限制下（詳見第參節之討論），跨國製藥企業追求經濟利益而忽略藥物近用權利保障之商業行為，正當性便更難被質疑。

但誠如本文第肆節所分析，忽視跨國製藥企業超越國界之鉅額

339 Paragraph (IV)(4)(b) of the *Guidelines for MNEs*.

340 *Id.* at (V)(1).

341 Dresler & Marks, *supra* note 283, at 634.

342 有關國家在國際藥物智慧財產權制度下之健康人權保障義務，請參考吳全峰（註6），頁657-681。

343 Paragraph (V)(2) of the *Guidelines for MNEs*.

344 *Id.*

投資與深遠之政經影響力對藥物近用權利之影響³⁴⁵，將導致健康人權在國際藥物智慧財產權制度下之保障，出現難以落實之困境。因此，理論與規範上之空白，遂使得跨國製藥企業在藥物近用權利保障上所應扮演之角色更顯模糊：跨國製藥企業是否應違背其追求最大商業經濟利益之宗旨，即令在擁有市場獨占之優勢下，仍有義務以較低之價格提供藥物與發展中國家之民眾（經濟之可近性）？進一步，跨國製藥企業是否有義務投入資源研發發展中國家民眾所需要之藥物（實質之可近性），即使其利潤較研發已開發國家民眾所需之慢性病藥物明顯為低？本文認為，國家雖然不可否認地應負擔第一線之人權義務(primary obligation)以保障可達到最高水準之健康與藥物近用權利，但該義務實應為國家與跨國製藥企業所應共同分享之義務(shared responsibility)³⁴⁶；也因此，前節所述有關跨國企業之國際人權責任準則與規範，對於藥物近用權利保障內容之空泛，便具有進一步補充之空間。

（一）限制：傳統健康人權之概念

跨國製藥企業之藥物近用權利保障責任之所以面臨論述與實踐之困境，可能就在於健康人權之軟性道德權利(moral right)性格，其內容之空泛與保障強度之不確定，不僅使國家有極大之判斷空間，得以恣意地詮釋健康人權保障與經濟效率追求間之平衡關係，亦使得跨國製藥企業得以據此主張免除其藥物近用權利保障之人權責任。

傳統上，健康人權（包括藥物近用權利）被視為軟性之道德權利(moral rights)，因此就國家實踐健康人權——屬受益權(positive rights)——之義務而言，僅被要求於有限資源內漸進保障該權利之義務(progressive realizations)；換言之，只要在「超出國家可運用之

345 Crow, *supra* note 10, at ii15.

346 *Id.*

合理資源」(beyond available resources)範圍外，國家即得以資源有限或經濟效率為理由，正當化其政策所附加於健康人權之限制³⁴⁷。相對而言，政治與公民權利——屬防禦權(negative rights)——則屬具強制力之法律權利(legal rights)，而國家有義務應竭盡一切資源以立即滿足對該權利之保障(immediate realizations)³⁴⁸。因此，由受益權與防禦權之區隔，不難發現國際人權義務可粗分為「必要義務」(must)與「應為義務」(ought to)：前者（屬政治與公民權利之範疇）指依法律規範強行要求所應盡之義務，國家除非有 ICCPR 第4(1)條規定之情事（社會緊急狀態威脅國家生存且符合比例原則）³⁴⁹，否則應立即滿足所有之權利；而後者（屬經濟、社會、文化權利之範疇）則屬宣示性之義務，蓋 ICESCR 第2(1)條雖規定國家應承擔盡最大能力採行一切適當方法逐漸達到相關權利的充分實

347 ICESCR, *supra* note 93, at article 2(1). See also paragraph 1 of the CESCR General Comment No. 3, "...the [ICESCR] provides for progressive realization and acknowledges the constraints due to the limits of available resources" Paragraph 9 of the CESCR General Comment No. 3, "...The concept of progressive realization constitutes a recognition of the fact that full realization of all economic, social and cultural rights will generally not be able to be achieved in a short period of time...." Paragraph 9 of the CESCR General Comment No. 14, "The notion of 'the highest attainable standard of health' in article 12.1 takes into account both the individual's biological and socio-economic preconditions and a State's available resources. ..." Soobramoney v. Minister of Health, KwaZulu-Natal 1997 (12) BCLR 1696 (CC) at para. 20 (S. Afr.). Government of the Republic of South Africa v. Grootboom 2000 (11) BCLR 1169 (CC) at paras. 14-15, 70 and 77 (S. Afr.).

348 The immediate realization of human rights means that state parties have the obligation to immediately respect, protect, and fulfill such rights regardless of whether or not enough resources are available. United Nations Development Programme, *supra* note 24, at 93.

349 Article 4(1) of the ICCPR, "In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin."

現³⁵⁰，但國家對權利之保障是否已超過其可利用資源之範疇與能力，卻存在廣泛之解釋空間³⁵¹，需要真正發揮人權保障之作用尚須具體制度性規定之補充³⁵²。雖然 CESCR General Comment No. 3 仍認為兩者均屬國家之法律責任³⁵³；但不可否認，在權利內容之實踐與國家義務之評估上，兩者仍有明顯(significant)之區隔³⁵⁴。而藥物近用權利因其漸進滿足之道德權利特性，國家之人權義務往往被視為落入後者之範疇，亦即僅有在特定條件滿足下（合理資源範圍內），未滿足藥物近用權利保障義務之國家行為始有被非難之可能³⁵⁵。

但藥物近用權利之道德權利色彩與漸進式滿足原則所造就之開放性格，卻使國際人權文件在藥物近用權利與其他權利或經濟利益相衝突之艱難案件(hard cases)中，無法發揮適當之調和功能，亦無法期待其可在類似案件中提供有效且足以監督(monitorable)之機

³⁵⁰ ICESCR, *supra* note 93, at article 2(1).

³⁵¹ 吳全峰、黃文鴻（註27），頁147。

³⁵² 吳全峰、黃文鴻（註27），頁149-150。

³⁵³ Paragraph 9 of the CESCR General Comment 3, "... The concept of progressive realization constitutes a recognition of the fact that full realization of all economic, social and cultural rights will generally not be able to be achieved in a short period of time. In this sense the obligation differs significantly from that contained in article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights which embodies an immediate obligation to respect and ensure all of the relevant rights. Nevertheless, the fact that realization over time, or in other words progressively, is foreseen under the Covenant should not be misinterpreted as depriving the obligation of all meaningful content. ..."

³⁵⁴ *Id.*

³⁵⁵ 如南非憲法法院在 *Soobramoney v. Minister of Health* 乙案中，亦認國家實踐健康人權之義務有其界線且僅需漸進達成即可，而有限資源之配置便可作為國家限制民眾健康人權之正當化理由(justifications)；因此，當公立醫院以資源有限為由，僅提供洗腎醫療服務給急性腎衰竭病人或符合腎臟移植之慢性腎衰竭病人，並拒絕提供該服務予不可逆之慢性腎衰竭病人時，該健康照護政策並未侵犯民眾之健康照護人權，因提供洗腎醫療服務予所有病人將竭盡國家之醫療資源，而非屬合理可用之醫療資源範圍內。*Soobramoney v. Minister of Health, KwaZulu-Natal*, 1997 (12) BCLR 1696 (CC), at paras. 11 and 19.

制，具體檢視國家以資源有限或經濟效率為理由所附加於健康人權之限制是否具有正當性(justifiability)³⁵⁶。換言之，國際人權法規範中雖揭示國家對於民眾可達到之最高健康水準(highest attainable standard of health)應負擔廣泛之人權義務；但在該廣泛之人權概念下，國家對於不同健康照護需要(healthcare needs)或藥物需求(pharmaceutical needs)是否應負擔一致抑或應擔負比重不同之義務，該需要之滿足相較於其他權利或經濟利益是否均具有優先性，卻未見深入分析與討論³⁵⁷。

藥物近用保障之道德權利性質，遂使得跨國製藥企業是否應負擔實踐該權利之人權責任出現重大分歧與爭論³⁵⁸。首先，跨國製藥企業往往據此主張，藥物近用權利性質上屬受益權，涉及健康照護資源之提供與重分配以滿足民眾可達到之最高健康水準；但不論對於貧窮階級提供廉價藥物或規劃健康照護資源之配置，均應屬國家公共或社會行政所應涵蓋之範圍，且亦僅有國家始具備足夠之公權力得以協調社會不同團體之需要³⁵⁹。而因確保每個人有適當之平等機會(fair opportunities)使用關鍵服務或設備（包括藥物）應屬社會責任³⁶⁰，故要求跨國製藥企業負擔資源分配正義(distributive justice)之責任，並提供廉價藥物以保障個人追求理想生活目標之平等機會(fair opportunities)，並不合理；跨國製藥企業之責任應僅限於，在社會所創造並維持之平等市場環境中，確保其商業模式係遵循法律規範運作³⁶¹。

356 吳全峰，健康人權發展困境之初探，中央研究院週報，1348期，頁12（2011年）。

357 吳全峰（註356），頁12。

358 Leisinger, *supra* note 18, at 4.

359 *Id.* at 6.

360 Jeffery D. Sachs 著，鐵人庸譯（註84），頁326-327。JEFFERY D. SACHS, COMMON WEALTH: ECONOMICS FOR A CROWDED PLANET 220 (2008).

361 Leisinger, *supra* note 18, at 4.

其次，因藥物近用權利屬受益權，其保障需要相當程度社會資源之投入，故要求跨國製藥企業犧牲其商業利潤或窮盡其資源滿足其人權責任，顯然不實際亦違反市場運作之規則³⁶²。觀察包括相關國際文件亦可發現，受 ICESCR 保障之健康人權均未受到明確之規範，即使有論及相關權利亦僅是宣示性地要求跨國企業適當考慮 (take due account of) 公共健康之需求 (Guidelines for MNEs 第 V 段)，或僅要求跨國企業負擔尊重 (respect)——而非保障 (protect) 或實踐 (fulfill)——健康人權之責任 (Norms for TNCs 第 12 段、Guiding Principles 第 II 節)。因此，跨國製藥企業便可主張其人權責任應侷限於「尊重」健康人權（指應避免直接或間接干預健康人權）之義務，而不及於「實踐」（指應採取適當手段以確保健康人權之完全實現）或「保障」（指應確保健康人權不受第三人之任意干預）健康人權之義務。換言之，國際法規範似認為跨國企業之人權責任範圍僅限於不需耗用資源之防禦權（如不歧視³⁶³、不限制工人之結社自由與集體談判權³⁶⁴、不侵犯消費者隱私權³⁶⁵）或具防禦功能之受益權（如避免企業運作引起之嚴重環境污染或健康傷害³⁶⁶），而不及於具給付功能且需要資源投入之受益權^{367、368}；因此，似亦不宜要求跨國製藥企業負擔保障藥物近用權利之人權責任。

362 *Id.*

363 Paragraph 2 of the Norms for TNCs.

364 Paragraph 9 of the Norms for TNCs.

365 Paragraph (VII)(5) of the Guidelines for MNEs.

366 Paragraph (V)(5) of the Guidelines for MNEs.

367 Jan Wouters & Leen Chanet, *Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective*, 6 NW. U. J. INT'L HUM. RTS. 262, 268 (2008). Leisinger, *supra* note 18, at 9.

368 較特殊例外情形為與跨國企業具有契約關係之受雇者，如 Norms for TNCs 第 8 段便強調跨國企業應向工人支付能夠保證他們及其家庭適當生活水準之報酬，且該報酬應適當考慮工人需要享有適足之生活條件並漸進達成該目標 (“Transnational corporations and other business enterprises shall provide workers with remuneration that ensures an adequate standard of living for them and their families. Such remuneration shall take due account of their needs for adequate living conditions with a view towards progressive improvement.”)。

最後，既然作為人權保障首要(primary)義務主體之國家對於藥物近用權利之保障僅限於有限資源內始有漸進滿足之義務，要求私法人（跨國製藥企業）犧牲其商業利潤並負擔較國家嚴格之責任並不合理。換言之，因國家所負擔之健康人權保障義務強度並不及於立即滿足權利保障之「必要義務」，僅及於漸進滿足之「應為義務」；故要求跨國製藥企業負擔與國家相同強度，甚至更嚴格之人權責任，將明顯忽略國家作為人權保障主要義務主體之角色，並混淆國家與企業在功能與本質上之差異³⁶⁹——企業作為私法人，應為經濟與社會發展之積極主體，並藉由商業行為之操作，運用其所擁有之資源以確保投資人之商業利潤；而國家則必須尊重個人（或企業）所擁有之資源與進行商業行為之自由，以及為滿足自身需要（避免虧損以維持企業生存）而採取必要行動或使用必要資源之自由。

若現行國際人權法規範係以前述漸進滿足之概念形塑國家滿足健康人權義務之界線，跨國製藥企業便得以主張其保障藥物近用權利之人權責任亦應在前述範疇內界定；而從 Klaus M. Leisinger 所提有關企業之階層式人權責任架構（*hierarchy of corporate human rights responsibilities*，見圖二）³⁷⁰觀察，則跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任便應落在軟性之「應為(ought to)義務」與純粹道德性之「得為(nice to have)義務」之間，而非屬具法律強制力之「必要(must)義務」³⁷¹。以下本文將就跨國製藥企業之主張做進一

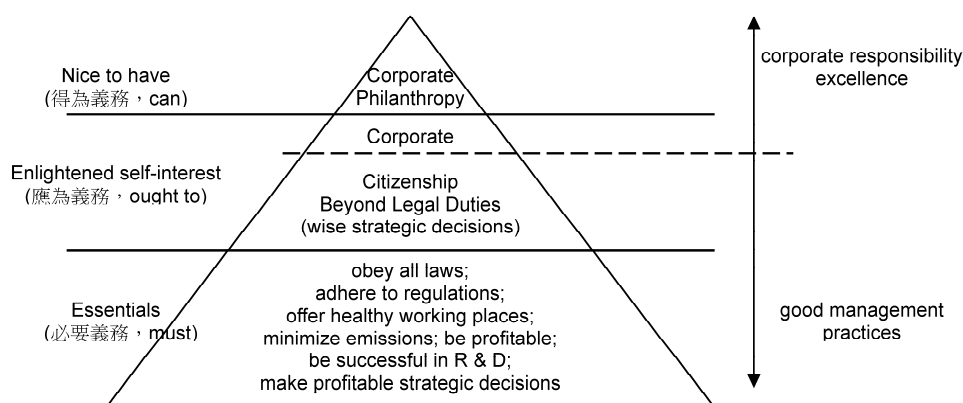
369 RATNER, *supra* note 279, at 493.

370 Leisinger, *supra* note 18, at 9.

371 According to Leisinger, the distinction between “must”, “ought to”, and “can” norms helps to distinguish what is essentially *good management practice* and what constitutes *corporate responsibility excellence*, partly having a “nice to have” character. Only responsibilities in the context of civil and political rights are an integral part of the “must” dimension and hence an essential ingredient of good management practices. However, as far as economic, social, and cultural rights are concerned, the normal business operations of a company then are considered enough to form the main corporate contribution to the preservation of these rights. KLAUS M.

步之分析與說明；但需要事先說明者為，以下之分析主要是立基於傳統健康人權之概念上，但因該概念已受到許多挑戰（詳見第伍、二、（二）節之討論），故跨國製藥企業根據傳統健康人權之概念主張其不應負擔藥物近用權利保障責任之論述，遂也漸受質疑並被推翻（詳見第陸節之討論）。

圖二 企業之階層式人權責任架構
(The Hierarchy of Corporate Responsibilities)



- (1) 因國家對藥物近用權利僅負在合理可利用資源範圍內漸進滿足之義務，則社會最多亦僅能要求跨國製藥企業在資源許可（不影響其商業利潤）之前提下，對藥物近用權利負擔「應為義務」，而不宜超過此限度要求其負擔較國家更為嚴格之「必要義務」。換言之，僅有在(A)國家之法律規範或健康照護政策因政治或經濟因素而不足以因應受國際人權法所保障之藥物近用權利受到限制或侵害之情況，且(B)尊重或實踐

LEISINGER, ON CORPORATE RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS 10, available at <http://www.novartisfoundation.org/platform/apps/Publication/getfile.asp?id=612&el=812&se=471187408&doc=46&dse=5> (last visited May 23, 2010).

健康照護近用權利所耗用之資源係在跨國製藥企業可利用之資源範圍內時，始有正當性期待跨國製藥企業負擔其人權責任，藉由提供藥價折扣或差別訂價、限縮其藥物智慧財產權等個別步驟，漸進滿足民眾藥物近用之需要。類似之精神亦可從 TRIPS 協定有關強制授權之相關規範中窺見：限制跨國製藥企業藥物智慧財產權之強制授權措施，除其他相關條件外³⁷²，尚必須在(A)國家遭遇緊急狀況(national emergency)或其他極度緊急情事(other circumstances of extreme urgency)³⁷³（即國家能力已不足以因應藥物近用不足之問題），及(B)考量藥物專利之經濟價值給付相當報酬予跨國製藥企業³⁷⁴（即考量跨國製藥企業之資源許可範圍），始得准予特許實施強制授權。但類似強制授權所面臨之困境（專利權人得藉由杯葛權利金補償額度而質疑強制授權正當性，詳見第肆、三節之討論），同樣也反映在跨國製藥企業之保障藥物近用權利之「應為義務」上——在藥物研發成本極高，且跨國製藥企業仍應考慮股東、員工、債權人之利益之前提下，所謂資源充沛之要件在現實生活殊難想像；因此，跨國製藥企業在「應為義務」範圍內滿足藥物近用權利保障，便極可能僅屬空泛之人權責任要求，而無落實之可能性。

- (2) 因此多數學者同意且常見之情況為，考量資源有限之現實限制，跨國製藥企業之健康人權責任多已從「應盡義務」落至「得為義務」之範疇——跨國製藥企業並無義務耗盡資源以確保其商業行為相關之公私領域範疇內之藥物近用權利保障，且其對該人權責任之實踐應屬企業自願落實之社會責任

372 包括先致力於以合理商業條件(reasonable commercial term)取得自願授權(Article 31(b) of the TRIPS Agreement)、依個案條件決定(Article 31(a))、限與強制授權目的相符之範圍(Article 31(c))、不得具有專屬性(Article 31(d))等。

373 Article 31(b) of the TRIPS Agreement.

374 Article 31(h) of the TRIPS Agreement.

範疇³⁷⁵，而不宜以法律規範之。詳言之，跨國製藥企業之藥物近用權利保障之人權責任，在其主要內涵仍屬民眾得積極請求為一定給付並涉及資源耗用之受益權前提下，其法律上之意義原已明顯不若在防禦權領域（要求不受國家或第三人任意干預且不涉資源耗用之權利）明確；若再加上資源限制之要件，對於跨國製藥企業人權責任之期待便往往等同於軟性之道德期待(moral expectations)——亦即跨國製藥企業「得」自願決定是否接受有關藥物近用權利保障相關規範（包括良好企業行為(good practice)之落實、對社會正義與平等之尊重等）之約束³⁷⁶，而不被歸類為法律上所應強制處理之議題；而跨國製藥企業是否採行有助於藥物近用之措施，也因此被認為純粹屬企業本身之意願主導之自願慈善行為(purely voluntary philanthropy)，社會不宜亦不應「強制」跨國製藥企業負擔保障藥物近用權利之人權責任。從目前國際人權文件之規範觀察亦可見此趨勢，如 Guidelines for Pharmaceutical Companies 第33-38段雖然針對跨國製藥企業與藥物近用權利間之關係有所著墨，但亦僅及於建議及宣示之性質——如應予考慮(should consider)、應予特別注意(should give particular attention)等不具強制力之用語³⁷⁷。

375 Leisinger, *supra* note 18, at 13-14.

376 *Id.* at 9-10.

377 See, e.g., paragraph 33 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “When formulating and implementing its access to medicines policy, the company should consider all the arrangements at its disposal with a view to ensuring that its medicines are affordable to as many people as possible. In keeping with Guideline 5, the company should give particular attention to ensuring its medicines are accessible to disadvantaged individuals, communities and populations, including those living in poverty and the very poorest in all markets. The arrangements should include, for example, differential pricing between countries, differential pricing within countries, commercial voluntary licences, not-for-profit voluntary licences, donation programmes, and Public Private Partnerships.”（底線為作者所加註）。

既然跨國製藥企業之藥物近用權利保障之人權責任，並非強制之法律義務(legal obligations)，最多僅能被視為企業商業行為下，透過理性判斷所做出自我效益(self-interest)極大化之明智決定(wise strategic decisions)；則藥物近用權利之保障作為「得為義務」，已屬於跨國製藥企業是否履行其優良企業責任(corporate responsibility excellence)之道德範疇，而脫離國際人權典範之約束；跨國製藥企業因此得自行決定其是否願意採取該高道德之標準，對發展中國家民眾之藥物近用權利提供保障。而若其拒絕提供較低價格之藥物或針對發展中國家之流行病進行藥物研發，則依據藥物近用權利之本質，實無理由賦予其強制之法律義務，並對其不作為予以非難或處罰。舉例而言，跨國製藥企業捐贈或降低 AIDS 藥物價格之行為，並非基於保障藥物近用權利之義務，而是在效益主義之考量下，一方面為避免發展中國家採強制授權措施而影響其藥物智慧財產權所能獲得之商業利益，另一方面亦藉此要求發展中國家維持或進一步改善其國內藥物智慧財產權規範，以達到國際藥物智慧財產權規範一致化與貿易自由化之目的³⁷⁸。但若跨國製藥企業在衡量相關利益，雖有能力調低藥物售價但卻仍拒絕提供具經濟上可近性之藥物予發展中國家，其並不因此受任何法律上之非難（至多僅為其企業形象之道德傷害）³⁷⁹。

378 Spectar, *supra* note 159, at 265.

379 若以一般跨國企業觀察，則這類影響更為明顯；如跨國企業對勞動環境之重視，並非基於勞動人權及（廣義）健康人權之義務，而係因虐待勞工(labor abuse)不僅可能導致產品價格之下降，亦將造成社會傾銷(social dumping)——謂社會傾銷係指由囚犯或血汗勞工所製造之產品以非常低的價格出口時，所發生之貿易行為；此係在哈瓦那憲章(Havana Charter)談判時參與國所設想的一種傾銷類型。另如(General Agreement on Tariffs and Trade 1947, GATT 1947)第20(e)條中亦規定對於禁止他國監獄人犯所製造產品之進口，並不構成GATT義務之違反。因此，為避免前述之因素造成各國採取保護主義而不利貿易自由化，並最終對跨國企業之商業利益形成負面影響，故跨國企業便願意

- (3) 跨國製藥企業並不否認其仍應負擔具強制性之「必要義務」，但強調該義務範圍不應包括藥物近用權利（因並無理由要求跨國製藥企業負擔較國家更重之人權責任），而僅限於保障國際人權法中核心且不得談判減損(non-negotiable)之權利（如隱私權、集會結社權等），以及跨國製藥企業作為社會公民所應盡之義務範圍（主要指遵守法律之義務，如遵守反貪污法中禁止賄賂之規範）³⁸⁰。換言之，在必要義務之範疇，跨國製藥企業與藥物近用權利間之關聯性，並不及於放棄智慧財產權所保障之市場獨占地位或直接在市場提供廉價藥物，而係遵守國家為保障民眾消費權益與維持市場秩序所訂定之法律規範，在其商業行為中避免濫用市場地位或獨占力量（如聯合壟斷）阻礙學名藥廠進入市場、防止價格操作並不當地決定或維持藥物價格、禁止足以影響交易秩序或誤導消費者之不當行銷手段或欺罔行為、提供充分且正確之藥物消費資訊、確保產品品質等。

進一步，因跨國製藥企業之基本社會功能僅限於在法律所賦予之權利義務範圍內生產產品（藥物）與提供服務，並販售得利；因此，跨國製藥企業「必須(must)」保障藥物近用權利之範圍，亦僅限於藥物近用保障功能與跨國製藥企業之基本社會功能相重疊之部分。換言之，若跨國製藥企業在從事各項商業活動時，能（A）將消費者（病患）視為其商業活動之主要利害關係人(primary stakeholders)³⁸¹，並提供在科學和醫學上適當(scientifically and medically appropriate)、

避免虐待勞工之情事發生。STEINHARDT, HOFFMAN & CAMPONOVO, *supra* note 280, at 720. 黃佳晴，社會傾銷之研究——經濟全球化下的貿易策略與國際分工，銘傳大學國際事務研究所碩士論文，頁26-33（2005年）。

380 Leisinger, *supra* note 18, at 13-14.

381 Werhane & Gorman, *supra* note 265, at 273.

高品質(good quality)、未過期(unexpired)之藥物³⁸²；(B)在合理之契約條件、適當之工作環境下僱用成年員工，並定期給付足以保障其家庭適當生活水準之薪資報酬；(C)依法繳納稅金以支持社會安全網絡（但是否運用以支持健康人權之保障則為政府之職能）；此時，跨國製藥企業在踐行其基本社會功能時，便已某種程度透過品質控管(quality assurance)保障地主國社會切實地近用安全藥物之機會（實體可近性），與透過合理薪資報酬之給付、稅金之繳納以確保該社會成員經濟上承擔藥價之能力（經濟可近性）³⁸³，而無非難其違反藥物近用權利保障責任之可能性。因此，在面對藥物近用之諸多挑戰時，因藥物近用權利保障之人權責任落入軟性「得為義務」之範疇，故跨國製藥企業若能善盡社會公民之責任（即發揮其應有之社會功能）似為已足，並無多餘之法定義務得要求其作出違反股東利益（利益最大化）之決策³⁸⁴。

（二）擴張：兼具防禦權與受益權特質之健康人權

但前述以簡單之二分法恣意地將藥物近用權利劃入「得為義務」之範疇，並僅要求跨國製藥企業負擔道德性優良企業責任之論述，卻忽略近年來對健康人權之討論已跳脫防禦權與受益權之區隔，而改從健康多元而複雜之概念為基礎，主張健康人權（包括藥物近用權利）內涵之界定應同時兼有防禦權（立即滿足之義

382 Paragraph 12(d) of the CESCR General Comment No. 14, “Quality. As well as being culturally acceptable, health facilities, goods and services must also be scientifically and medically appropriate and of good quality. This requires, *inter alia*, skilled medical personnel, scientifically approved and unexpired drugs and hospital equipment, safe and potable water, and adequate sanitation.”

383 LEISINGER, *supra* note 371, at 10.

384 D. Gordon Smith, *The Shareholder Primacy Norm*, 23 J. CORP. L. 277, 277 (1998). Ian. B. Lee, *Efficiency and Ethics in the Debate about Shareholder Primacy*, 31 DEL. J. CORP. L. 533, 537-39 (2006).

務)與受益權(漸進滿足之義務)之特質³⁸⁵。換言之,因健康並非整全不可分割之概念(undifferentiated and universal conception)³⁸⁶,健康人權(或藥物近用權)並不宜被恣意地簡化為均一地僅在國家可負擔資源之前提下始具有被漸進滿足之地位;舉例而言,WHO 便認為「最低限度之健康」(minimal health)作為健康人權之核心內容,是指國家應滿足民眾達成有生產力之工作狀態並積極參與社會生活之基本需要³⁸⁷,從而該權利內涵應具備核心價值並被優先保障。換言之,不同健康照護服務(或不同藥物)與民眾健康或生命關聯性之緊密程度,應被納入健康人權義務之考量中,並依其功能(functions)將健康人權(或藥物近用權利)依是否受資源有限條件之限制,區分為國家有義務漸進實現之受益權與國家有義務立即實現之受益權³⁸⁸。如 CESCR General Comment No. 14第30-44段便將國家之健康人權義務區分為法律義務(general and specific legal obligations)、核心義務(core obligations,如提供依據世界衛生組織必要藥物行動綱領(WHO Action Programme on Essential Drugs)所列之必要藥物等)及優先義務(obligations of comparable priority,如提供主要傳染病之防疫接種疫苗等)³⁸⁹;另如,在

385 United Nations Development Programme, *supra* note 24, at 93.

386 CHUAN-FENG WU, THE RIGHT TO HEALTH CARE AND HEALTH CARE DISTRIBUTIVE JUSTICE 14 (2007) (unpublished J.S.D. dissertation, University of California Berkeley School of Law) (on file with the University of California Berkeley School of Law Library).

387 WHO, GLOBAL STRATEGY FOR HEALTH FOR ALL BY THE YEAR 2000 15-18 (1981).

388 吳全峰、黃文鴻(註27),頁148。

389 CESCR General Comment No. 14 第43段遂以條列式之方式列舉出健康照護人權中最核心之部分(minimum essential levels),並主張國家有核心義務(core obligations)對該權利內涵為立即之保障,包括:(1)保障民眾(特別是社會邊緣或弱勢族群)在不受歧視之基礎上近用(access)衛生設施、商品和服務之權利;(2)保障民眾近用基本、具充分營養與安全食物之權利,並保證民眾免於饑餓;(3)保障民眾近用基本住所,及近用充分供應且衛生條件保證安全飲用水之權利;(4)提供依據世界衛生組織必需藥物行動綱領(WHO Action Programme on Essential Drugs)所列之必需藥物;(5)確保衛生設施、貨物和服務之公平分配;(6)確保在充分參與和程序透明之基礎上,依據流行病學實際情況,並納入醫療人權保障之指標,制定並定期審查國家公共衛

Soobramoney v. Minister of Health 及 Government of the Republic of South Africa vs. Grootboom 兩案中，南非憲法法院均主張，因特定之社會經濟需要（如一般民眾接受緊急醫療之權利、失怙孩童之健康人權等）具有相對重要性，故應跳脫以資源有限作為健康人權界線之傳統人權思維，而要求國家負有義務窮盡一切資源以立即滿足該需要³⁹⁰。

其次，即使尚有爭議，但部分學者已提出特定部分之健康人權內容應被視為國際法中一般強制規律(peremptory norms of general international law)或絕對法(*jus cogens*)之概念³⁹¹；而藥物近用權利多元內涵中倘有部分符合「國際社會全體接受並公認不許損抑且僅有以後具有同等性質之一般國際法規範始得更動(“norm accepted and recognized by the international community of states as a norm from

生政策、計畫與行動綱領。General Comment No. 14 第 44 段則指出下列健康照護需要優具有優先(comparable priority)之地位：(1) 主要傳染病之防疫接種 (to provide immunization against the major infectious diseases occurring in the community, 預防接種請求權)；(2) 確保孕婦、產婦（產前與產後）、幼兒之衛生保健 (to ensure reproductive, maternal (pre-natal as well as post-natal) and child health care, 孕婦及兒童之健康照護服務請求權)；(3) 國家性與地方性傳染病之預防治療與流行控制，包括必備藥物(essential drugs)請求權；(4) 緊急醫療請求權；(5) 提供醫療衛生人員適當之訓練（包括健康與人權議題之教育）及提供與社區主要健康議題有關之健康教育與相關資訊（如預防與控制疾病之方法）。

390 Soobramoney v. Minister of Health, KwaZulu-Natal 1997 (12) BCLR 1696 (CC) at para. 20 (S. Afr.). Government of the Republic of South Africa v. Grootboom 2000 (11) BCLR 1169 (CC) at paras. 14-15, 70 and 77 (S. Afr.).

391 一般而言，絕對法(*jus cogens*)在國際法上被認為具有優先之位階，而不被條約或其他國際習慣法所修改，亦被認為是公共同意原則之例外。Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law [*jus cogens*]. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.” LOUIS HENKIN, INTERNATIONAL LAW: POLITICS AND VALUES 38-39 (1995).

which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character”)³⁹²之絕對法規時³⁹³，跨國製藥企業就此部分之藥物近用權利內涵是否仍僅需負單純之「得為」社會責任，而對於「必要」（或至少「應為」）之人權責任則可任意迴避³⁹⁴，便引起質疑。如國際刑事法庭(International Criminal Tribunals)在處理南斯拉夫及盧安達內戰中國際犯罪問題中時，便承認 *jus cogens* 規律之規範對象應不僅限於國家而應進一步包含個人³⁹⁵；美國「外國人侵權行為損害賠償法(Alien Tort Claims Act)」中亦改變傳統僅適用於國家之見解，而改承認 *jus cogens* 規律所拘束之對象應包括所有可能之國際法主體——包括個人及跨國企業³⁹⁶。

但那些藥物近用權利那些內涵應被視為屬 *jus cogens* 之規範範圍，並不易判斷；因國際絕對法內涵之實踐義務與及主觀法意念並不容易確認，兼以其不容許任何例外（對積極表示反對之國家亦然）之性質（公共同意之特別例外），某項人權內涵若欲成為此國際體系所確認並接受之基本價值（即國際絕對法），便須符合嚴格之標準³⁹⁷，包括³⁹⁸：（1）須被國際社會接受並承認³⁹⁹；（2）任何

³⁹² Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (“VCLT”).

³⁹³ 丘宏達，現代國際法，頁 64（2006 年）。Eva M. Kornicker Uhlmann, *State Community Interests, Jus Cogens, and the Protection of the Global Environment: Developing Criteria for Preemptory Norms*, 11 GEO. INT’L ENVTL. L. REV. 101, 112 (1998).

³⁹⁴ *Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc.*, 244 F. Supp. 2d 289, 319 (S.D.N.Y. 2003).

³⁹⁵ Sukanya Pillay, *Absence of Justice: Lessons from the Bhopal Union Carbide Disaster for Latin America*, 14 MICH. ST. J. INT’L L. 479, 496-98 (2006).

³⁹⁶ Lauren A. Mowery, *Earth Rights, Human Rights: Can International Environmental Human Rights Affect Corporate Accountability?*, 13 FORDHAM ENVTL. L.J. 343, 367-68 (2002). Gregory G. A. Tzeutschler, *Corporate Violator: The Alien Tort Liability of Transnational Corporations for Human Rights Abuses Abroad*, 30 COLUM. HUM. RTS L. REV. 359, 393 (1999).

³⁹⁷ 聯合國雖未對 *jus cogens* 列出清單，但國際法委員會(International Law Commission)曾列出部分範例，包括關注違反聯合國憲章與規範違法使用武力

損抑皆不被允許⁴⁰⁰；(3) 僅相同位階之國際強制典範(peremptory norms)始能嗣後修改⁴⁰¹。但若從以上標準觀察，藥物近用權利中有關國家核心義務之內涵（搭配 CESCR General Comment No.14第43段之內容觀察）⁴⁰²——包括預防接種請求權、孕婦及兒童之藥物近用權、基本藥物(essential drugs)請求權⁴⁰³、緊急醫療藥物請求權⁴⁰⁴——應可被視為具備 *jus cogens* 性質之內涵⁴⁰⁵：(1) 至2009年已有160個國家簽署批准 ICESCR，即使少數國家並未承認健康人權，但除較邊緣之權利內涵外，在其憲法、國內醫療衛生法規⁴⁰⁶或

之條約；關注任何國際法下規範犯罪行為實行之條約；關注如奴隸買賣、海盜、屠殺等行為之授權條約。而國際社會對於這些行為應合作阻止。而在 Barcelona Traction 乙案中，國際法院提出了“erga omnes”之概念，即所有國家對於某一重要權利，皆可主張擁有法律上之保護利益，而國際社會對其則有保護之義務；而這些普遍義務之來源可能為違法之攻擊行為、大屠殺、關於基本人權的原則（如奴隸之保護、種族歧視）等，而這些列舉在本質上也可視為部分 *jus cogens* 之內涵。2 INTERNATIONAL LAW COMMISSION, YEARBOOKS OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 247-49 (1966). Belgium v. Spain, 1970 I.C.J. 3 (case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.).

398 Laura Westra, *Ecological Integrity and Biological Integrity: The Right to Life and the Right to Health in Law*, 18 TRANSNAT'L L. & CONTEMP. PROBS. 3, 19 (2009). Patricia C. Gunn, *Health Care Refugee*, 6 LOY. U. CHI. INT'L L. REV. 339, 361-62 (2009).

399 Eva M. Kornicker Uhlmann, *State Community Interests, Jus Cogens, and the Protection of the Global Environment: Developing Criteria for Preemptory Norms*, 11 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 101, 112 (1998).

400 所謂不得損抑係指國家不能以條約排除 *jus cogens* 之適用。姜皇池，國際法源（上），月旦法學教室，22期，頁27（2004年）。

401 Article 64 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, “If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.”

402 請參考註389之說明。

403 請參考 WHO Action Programme on Essential Drugs.

404 在 CESCR General Comment 14 中並未特別指出緊急醫療請求權為國家應立即保障之權利，但在各國法規中均可發現相關之立法例，其主要目的即為避免在緊急之狀況下所造成之不必要拖延，以保障民眾之生命權與健康權。

405 因相關分析主要以健康人權為主軸，而藥物近用權利又屬健康人權之重要要素，故為避免分析之冗贅，此部分之分析將以健康人權，而非藥物近用權利，作為分析主軸，但其運用面相仍及於藥物近用權利。

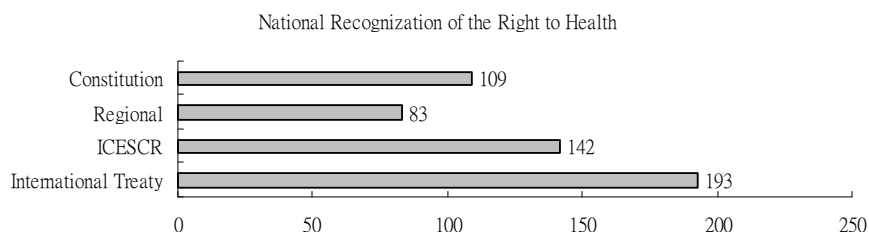
406 如美國之憲法與相關法規並未明確保障健康人權，但1944年之 Economic

判決⁴⁰⁷中仍可散見與健康人權直接相關之核心下位權利概念⁴⁰⁸；因此健康人權核心價值之優先性應已為多數國家所承認⁴⁰⁹。(2) 依

Bill of Rights 便首次導出醫療人權之概念為「接受適當健康照護並有機會達到並享受健康之權利(the right to adequate care and the opportunity to achieve and enjoy good health)」；1974 年之 Health Planning Act 要求中央政府之健康照護政策應「在合理成本之範圍內保障民眾對有品質健康照護服務之可近性(equal access to quality care at a reasonable cost)」；2001 年之病人權利法案(Patients' Bill of Rights)，或是 2005 年送交國會之病人權利法案(Patients' Bill of Rights Act of 2005)與病人保障法草案(Patient Protection Act of 2005)均指出國家應保障民眾自由選擇醫療照護提供者或醫療計畫之權利 (choice of providers and plans)、醫療平等權(nondiscrimination)、接受緊急醫療照護之權利(access to emergency services)、醫療決策參與權(participation in treatment decisions)、醫療隱私權(confidentiality of health information)、個人尊嚴權(respect)、及申訴之權利(complaints and appeals)。Janet O'Keeffe, *The Right to Health Care and Health Care Reform, in HEALTH CARE REFORM: A HUMAN RIGHTS APPROACH* 33, 36 (Audrey R. Chapman ed., 1994).

407 如美國最高法院在 *Mather v. Roe* 與 *Beal v. Doe* 等案中均確認並無所謂「積極權利」之存在(no affirmative right principle)，甚至認為健康人權並非憲法所保障之權利(entitlements)而僅為政府社會福利政策下之利益(benefit)；但特定案例中（如 *Farmer v. Brennan*、*Estelle v. Gamble*、*Estelle v. Gamble*），則認為如犯人及犯罪嫌疑人、精神疾病患者等之健康為憲法所保障之權利。Wing, *supra* note 56, at 163. Gunnar, *supra* note 56, at 173-74. *Maher v. Roe*, 97 S.Ct. 2376 (1977). *Beal v. Doe*, 97 S.Ct. 2366 (1977). *Farmer v. Brennan*, 511 U.S. 825, 832 (1994). *Estelle v. Gamble*, 429 U.S. 97, 103-04 (1976) (citing *Gregg v. Georgia*, 428 U.S. 153, 173 (1976)).

408 Shinn, *supra* note 49, at 115. Eleanor D. Kennedy, *The International Human Right to Health: What Does This Mean for Our National and World?*, 34 IND. L. REV. 1457, 1465 (2001).



409 國際法院規約第38條雖承認國際習慣法，但其要件應具備出清楚之描繪——作為通例之證明而經接受為法律者——亦即包括廣泛之國家實踐(practice)與主觀法之確信(*opinion juris*)，而為國家本於其對法律義務概念之認識而之國家實踐，並非僅是道德義務之規範。若依此標準，則因多數國家對於健康人權之

據 CESCR General Comment No.14第47段⁴¹⁰之規定，固然資源之有限性將國家之健康人權義務限縮於盡一切努力及利用一切可利用資源作為優先問題滿足健康人權之保障即可，但其仍強調第43 段之核心義務(core obligations)應視為不可減損(non-derogable)之健康人權核心價值，而在任何情況下國家對於未履行其核心義務之行為均是不能被正當化的(justified)。既然國家不得以資源有限或內國法之規定片面損抑健康人權核心內涵並規避其人權義務（如前述南非憲法法院在 *Grootboom* 案中便強調國家對失怙孩童健康人權優先滿足之必要性）⁴¹¹，則該核心內涵便應被視為整體國際健康人權體系之根本價值並定位為國際絕對法⁴¹²。（3）既然 CESCR General

實踐往往缺乏主觀法之確信之直接證據，因此健康人權之核心價值是否可被視為國際習慣法便產生疑慮。但在蓮花號案(Lotus case)與尼加瓜(Nicaragua case)案中，卻以單一國家實踐作為之本身歸納出國際習慣，並間接地推知法之確信；而學者亦贊同此作法，並且更進一步認為可以免除對於主觀之法的信念的舉證，而僅以國家實踐就可以導出國際習慣。因此，健康人權之核心價值應可作為國際習慣法並對未簽署 ICESCR 之國家發生效力。France v. Turkey, 1927 P.C.I.J. (Ser. A) No.10. Nicaragua v. U.S, 1986 I.C.J. 14 (June 27). Bruno Simma & Philip Alston, *The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles*, 12 AUST. YEAR BOOK OF INT'L L. 82, 88 (1989).

410 Article 47 of the CESCR General Comment No.14, "In determining which actions or omissions amount to a violation of the right to health, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party to comply with its obligations under article 12. This follows from article 12.1, which speaks of the highest attainable standard of health, as well as from article 2.1 of the Covenant, which obliges each State party to take the necessary steps to the maximum of its available resources. A State which is unwilling to use the maximum of its available resources for the realization of the right to health is in violation of its obligations under article 12. If resource constraints render it impossible for a State to comply fully with its Covenant obligations, it has the burden of justifying that every effort has nevertheless been made to use all available resources at its disposal in order to satisfy, as a matter of priority, the obligations outlined above. It should be stressed, however, that a State party cannot, under any circumstances whatsoever, justify its non-compliance with the core obligations set out in paragraph 43 above, which are non-derogable."

411 Government of the Republic of South Africa v. Grootboom 2000 (11) BCLR 1169 (CC) at paras. 14-15, 70 and 77 (S. Afr.).

412 Maurizio RAGAZZI, THE CONCEPT OF INTERNATIONAL OBLIGATIONS ERGA OMNES 58

Comment No.14已將健康人權依是否受資源有限條件之限制，區分為國家有義務漸進實現之受益權與國家有義務立即實現之受益權，則後者作為國家應優先滿足之核心義務，便表明除非與其他具有相同位階之人權相衝突，否則單純以經濟上利益之追求並不足以修改或限制 CESCR General Comment No.14第47段所強調之健康人權核心內涵；因此，健康人權核心內涵之變動實具備一定之門檻條件而符合其不許損抑之優先價值。進一步，因第43段所規範之健康人權核心內涵多與生命權(right to life)之支持與實踐息息相關，因此應與生命權於國際人權體系中所居之優先位階相當⁴¹³——ICCPR 第4(2)條規定國家即使於緊急狀況亦不得扣減（減免）之權利，（傾向於）被定位為國際絕對法之一部分⁴¹⁴。另，委

(1997). Theodor Meron, *On a Hierarchy of International Human Rights*, 80 AM. J. INT'L L. 1, 19 (1986). 吳錦龍，變動中的 Jus Cogens——緣起、發展與定型（上），台灣國際法季刊，3卷2期，頁206-209（2006年）。

413 Fact Sheet No. 2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights (June 1996), available at <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf> (last visited Dec. 9, 2010). Patricia C. Gunn, *Health Care Refugee*, 6 LOY. U. CHI. INT'L L. REV. 339, 361-62 (2009).

414 Paragraph 11 of CESCR General Comment No. 29, "The enumeration of non-derogable provisions in article 4 is related to, but not identical with, the question whether certain human rights obligations bear the nature of peremptory norms of international law. The proclamation of certain provisions of the Covenant as being of a non-derogable nature, in article 4, paragraph 2, is to be seen partly as recognition of the peremptory nature of some fundamental rights ensured in treaty form in the Covenant (e.g., articles 6 and 7). However, it is apparent that some other provisions of the Covenant were included in the list of non-derogable provisions because it can never become necessary to derogate from these rights during a state of emergency (e.g., articles 11 and 18). Furthermore, the category of peremptory norms extends beyond the list of non-derogable provisions as given in article 4, paragraph 2. States parties may in no circumstances invoke article 4 of the Covenant as justification for acting in violation of humanitarian law or peremptory norms of international law, for instance by taking hostages, by imposing collective punishments, through arbitrary deprivations of liberty or by deviating from fundamental principles of fair trial, including the presumption of innocence." See also SARAH JOSEPH ET AL., THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CASES, MATERIALS AND COMMENTARY 829-33 (2004). 張文貞，國際人權法與內國憲法的匯流——台灣施行兩大公約之後，收於：台灣

內瑞拉最高法院在 *Cruz Bermudez et al v. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social* 乙案⁴¹⁵、加拿大最高法院在 *Chaoulli v. Québec* 乙案⁴¹⁶、印度最高法院在 *Consumer Education and Research Centre and Others v. Union of India and Others* 乙案⁴¹⁷中，均強調部分健康人權之內涵實為完整生命權保障所不可或缺之重要面向。

綜前所述，則與生命權具有密切關聯性之健康人權（或藥物近用權利），便應被視為國際絕對法之一部份，而跨國製藥企業實踐該類權利之義務便不必然應歸屬於「得為義務」或「應為義務」之範疇，而應重新思考是否有納入「必要義務」之可能性。換言之，並不能以自願性之企業責任作為跨國製藥企業滿足藥物近用權利之底線（至少就基本藥物之近用權利而言，因其可立即且有效率地避免因殘疾所造成之死亡，主張跨國製藥企業僅需負擔「得為義務」便可能有所不足）；而就此部分（其內涵請見第陸節說明）具有國際絕對法性質之藥物近用權利內涵，便應要求跨國製藥企業負擔法定之國際人權責任。

第三，在健康人權內涵重要性呈現多元之前提下，將藥物近用權利之人權責任均一地視為跨國製藥企業得自願履行之軟性道德義務，不僅將忽視或矮化某些具有特定重要性且應被視為「必要義務」之權利內涵（如符合國際絕對法規範之內涵）；在跨國製藥企

法學會編，台灣法學新課題（八），頁6-7（2010年）。

415 *See generally*, Decision No. 916 of the Administrative Law Court of the Supreme Court of Justice of Venezuela, Case No. 15.789 (July 15, 1999). 委內瑞拉最高法院在本案中主張生命權與健康人權有緊密之連結，並據此判決ARVs之供應應為健康照護政策中之重要面向。

416 *See generally*, Jacques Chaoulli & George Zeliotis v. Attorney General of Québec & attorney General of Canada, [2005] 1 S.C.R. 791 (Can.).

417 *See generally*, Consumer Education and Research Centre and Others v. Union of India and Others, (1995) S.C.C. (3)42 (India), at paras. 24-30. *See also* Paschim Banga Khet Mazdoor Samity and Others v. State of West Bengal and Another, A.I.R. 1996 S.C. 2426 (India), at para. 16.

業以謀取股東最大利益為經營行為作為前提（至多增加妥善照顧員工及消費者、善盡社會賦予之法定義務等），亦難期待其會嚴肅地看待藥物近用權利之「自願」實踐責任⁴¹⁸，並對於尋求並判斷藥物智慧財產權與健康人權衝突時之合理適當平衡關係(reasonable trade-off)可能產生誤判之後果⁴¹⁹。舉例而言，許多跨國製藥企業藉由積極加入促進藥物近用之計畫——如聯合國「促進近用倡議」(Accelerating Access Initiative, 以下簡稱 AAI)⁴²⁰——並提供發展中國家折扣後之專利藥物，而主張藉由藥物捐贈或折扣得取代對藥物智慧財產權仍有所限制之強制授權制度⁴²¹。但跨國製藥企業在執行類似之自願慈善行為時，卻仍呈現相當之侷限性：許多折扣後之藥物價格仍然偏高且不足已有效保障發展中國家民眾之藥物近用權利⁴²²，且相較於學名藥進入市場競爭後之價格調整，專利藥廠之折扣更顯不足⁴²³。如在南非與美國之 AIDS 藥物智慧財產權爭端案中，跨國製藥企業雖將 AIDS 藥物價格做極大幅度之調降（以每年 600-700 美元之價格，替代每年 15,000 美元之價格），但該價格對於多數南非 AIDS 患者而言，仍超出其可負擔之經濟範圍外⁴²⁴；且若開放學名藥進入市場競爭，則每年 AIDS 藥物價格之降幅可達 90%

418 HENRY J. STEINER & PHILIP ALSTON, AND RYAN GOODMAN, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS IN CONTEXT: LAW, POLITICS, MORALS 1397 (2007).

419 吳全峰（註6），頁653。

420 A discount pricing program launched by five drug companies in cooperation with the WHO in early 2001. See WHO, ACCELERATING ACCESS INITIATIVE: WIDENING ACCESS AND SUPPORT FOR PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS - PROGRESS REPORT (2002), available at whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241210125.pdf; WHO, ACCELERATING ACCESS - FACT SHEET (Dec. 31, 2005), www.who.int/hiv/AAI_fs_4Q2005.pdf (last visited Dec. 6, 2010).

421 Brook K. Baker, *Ending Drug Registration Apartheid: Taming Data Exclusivity and Patent / Registration Linkage*, 34(2-3) AM. J.L. & MED. 303, 332-33 (2008).

422 Heather Watts, *International Trade, Generic Drugs and the Developing World*, 12, Apr. 2002, available at http://www.dww.com/?page_id=1050 (last visited Dec. 6, 2010).

423 Joseph, *supra* note 19, at 436.

424 林彩瑜（註81），頁300。

(以本案為例，約每年150美元)⁴²⁵。但即使跨國製藥企業認知到藥物捐贈或折扣之侷限性，其仍宣稱對藥物之折扣將是比強制授權更適當之必要措施⁴²⁶；進一步依據 TRIPS 協定第8(1)條之規定（會員國為保護「公共健康與營養及對社會經濟和技術發展關重要之公眾利益」所採取之措施須符合 TRIPS 協定同條款下「必要措施(necessary measures)」之意義，亦應侷限於無其他替代方案下對藥物智慧財產權侵害最小之手段始屬之⁴²⁷），跨國製藥企業更主張發展中國家在仍有其他對藥物智慧財產權侵害更小之替代方案（如藥物捐贈或折扣）以保護公共健康等公共利益之前提下，並挑戰與質疑發展中國家行使強制授權之正當性。因此，對跨國製藥企業所應負擔藥物近用權利保障之人權責任之過度寬鬆或忽視，將導致跨國製藥企業在面對藥物智慧財產權與藥物近用權利之衝突時，僅從經濟效益追求之單極觀點出發，並對可能危害企業最大經濟效益追求之藥物近用權利保障措施，採取對立排斥之立場(defensive position)，抑或僅將促進藥物近用視為促進企業形象(public image)之慈善行為(charity)⁴²⁸，或是視為減緩企業傷害之傷害控制措施

425 Individual Members of the Faculty of Harvard University, Consensus Statement on Antiretroviral Treatment for AIDS in Poor Countries 13, 14 Mar. 2001, available at http://www.carroll.edu/~mparker/mcm/consensus_aids_therapy.pdf (last visited Dec. 6, 2010).

426 Baker, *supra* note 421, at 332-33.

427 如在泰國香菸案中，WTO 爭端解決小組認為必要性之判斷必須是在達成相同政策目標之政策工具選擇上，「不能期待有任何其他與 GATT 一致之手段，或與 GATT 規範不一致較少之手段（“[there is] no alternative measure consistent with the [GATT], or less inconsistent with it”）」；因此，既然「有各種符合協定之措施，泰國得以使用作為控制香菸之品質與數量之方法，而此等方法應可達成泰國以限制香菸進口所欲達成之維護健康之政策目標；故小組認定，泰國准許國產香菸之銷售卻不准外國香菸進口，屬於違背總協定之措施，且非協定第20(b)條意義下之『必要』措施」。Report of the Panel, *Thailand – Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes*, paras. 75, 222-26, DS/10/R (Nov. 7, 1990), GATT B.I.S.D. 37S/200 (1990).

428 國際製藥企業 Merk 之前執行長曾宣稱：「Corporations cannot choose to write off the developing world as beyond their business interests. Although philanthropy remains an important role for corporate America, the development of workable,

(如為避免傷害更大之強制授權而提供折扣藥物)，而非（不論是否有無強制法律規範下）對藥物近用權利之積極保障。另一方面，將人權保障之主體限縮於國家，亦將忽略跨國製藥企業能力之充分運用，可能對有效提升並促進藥物近用權利之保障，具有積極之意義。因此，雖然只有國家才是 ICESCR 之締約國從而對遵守公約並保障藥物近用權利負有最終義務⁴²⁹；但誠如 CESCR General Comment No.14第42段所主張，社會之所有成員與個人——包括衛生專業人員、家庭、社區、地方政府、非政府組織及私營企業部門——在實現藥物近用權利方面均應負有責任^{430、431}。

long-term business models is the only real way to ensure that the products and services we generate are truly available to fight global poverty and meet health challenges such as AIDS, malaria and TB.」WHO, PUBLIC HEALTH: INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 114 (2006).

429 但本文並非主張跨國製藥企業仍僅需負擔自願履行之軟性道德義務。詳言之，目前之規範軟性道德規範僅要求跨國製藥企業自願負擔得為(can)義務，以滿足藥物近用權利之保障，較接近慈善行為之性質；但本文係主張跨國製藥企業之人權責任強度應依藥物近用權利之具體內涵而有所調整，而不應一概視為得為義務——如就「藥物市場獨占地位之濫用禁止」與「藥物資訊之透明公開化」應負擔必要(must)義務（屬法律義務），就「與基本健康維持相關之藥物近用」則應負擔應為(ought to)義務（介於法律義務與道德義務之間），僅就「與基本健康維持無關之藥物近用」可負擔得為義務（屬道德義務）（更深入之討論請參考第陸、一節）。惟本文亦不主張跨國製藥企業應負擔與國家相同強度之人權責任。蓋以前者取代後者，不僅將使國家有迴避其應盡人權義務之可能，也可能造成企業過重之負擔（更深入之討論請參考第陸、二節）。

430 Article 42 of CESCR General Comment No.14, “While only States are parties to the Covenant and thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, including health professionals, families, local communities, intergovernmental and non-governmental organizations, civil society organizations, as well as the private business sector - have responsibilities regarding the realization of the right to health. State parties should therefore provide an environment which facilitates the discharge of these responsibilities.”

431 需要說明者為，學界與實務界雖然認為將跨國企業納入國際人權體系架構有其正當性，但對正當性之基礎卻仍莫衷一是；而本文限於篇幅，亦無法針對此一議題進行深入之討論。簡言之，(1) Archie B. Carroll便主張基於利害關係者理論(stakeholder theory)，跨國企業所應關心之對象應從股東或投資者（首要社會利害關係者），擴散至所有可能受其商業活動影響之個人或團體（次要社會利害關係者），以及自然環境、自然物種（非社會利害關係者）。其

三、跨國製藥企業人權責任之擴張對藥物智慧財產權體系之衝擊

但問題在於，若賦予跨國製藥企業較嚴格之藥物近用權利保障責任，是否將因此危害國際藥物智慧財產權之整體架構？尤其對於健康這類屬於非貿易關切之事項（non-trade concerns），多認為若將商業活動以外之強制法律人權義務強加於跨國製藥企業，將可能使WTO 所欲達成之目標——包括減少政府或其他人為干預、降低貿易障礙、促進貿易自由化等——無法達成⁴³²；另一方面，亦將模糊TRIPS 協定維護發明創作人（如原開發藥廠）排他性權利保障、促進知識創造與商業開發、加速新知識技術之廣泛傳播等規範目的⁴³³。如跨國製藥企業便宣稱，藥物近用與智慧財產權間之關聯性

理由便在於跨國企業為利害關係者間契約之連結——如無消費者之參與，企業便無法運作——故利害關係者之期待便應為企業所應負擔人權責任之基礎。(2) 另有學者主張普世權利(universal rights)作為跨國企業人權責任之正當化基礎，強調人權（如勞工權益）應為跨國企業經營之中心思維；包括UN 之 Guiding Principles、OECD 之 Guidelines for MNEs、ILO 之 Tripartite Declaration均採類似之觀點，認為針對貿易自由化所帶來之跨國公司危害人權之問題，已屬國際社會應正視並進行管制之問題（詳見第伍、一節）。(3) 但因普世人權之概念涵蓋範圍甚廣，而可能造成跨國企業過重之負擔，並混淆國家與企業在人權保障上之角色，故J. Elkington便提出三重基線理論(triple bottom line)，並主張單純考慮財務面之單一基線可能無法達成跨國企業永續經營之目標；因此，跨國企業之運作應兼及經濟、社會、環境——即同時涵蓋人類(people)、自然(planet)、利益(profit)三個面向，而在實務之操作上成為其人權責任之基線。李貴英、曾恕真，跨國企業投資行為之規範——企業社會責任之研究，法制論叢，47期，頁7-10（2011年）。陳彥君（註184），頁42-71。ARCHIE B. CARROL & ANN K. BUCHHOLTZ, BUSINESS AND SOCIETY – ETHICS AND STAKEHOLDER MANAGEMENT 70 (2002). J. Elkington, *The Triple Bottom Line*, in THE ACCOUNTABLE CORPORATION 97 (Marc J. Epstein & Kirk O. Hanson eds., 2006).

432 吳全峰（註6），頁632。徐遵慈，貿易與人權——WTO 的難題與挑戰，經濟前瞻，105期，頁89（2006年）。

433 吳全峰（註6），頁632。Ernst-Ulrich Petersmann, *The Human Rights Approach Advocated by the UN High Commissioner for Human Rights and by the International Labour Organisation: Is It Relevant for WTO Law and Policy*, 7 J. ECON. L. 605, 611 (2004); Veijo Heiskanen, *The Regulatory Philosophy of International Trade Law*, 38 J. WORLD TRADE 1, 1 (2004).

十分微弱，尤其前者所牽涉之因素十分廣泛（包括價格控制、通貨膨脹、稅制、分配體系等），且發展中國家所需要之藥物多為非專利藥⁴³⁴；因此，若僅因該微弱之關聯性而破壞藥物智慧財產權體系並賦予跨國製藥企業健康人權責任，將造成以下後果：（1）不符合比例原則，破壞藥物智慧財產權保障專利權人及促進藥物研究發展之目的；（2）將使原本自由競爭之藥物市場出現政府控制之貿易障礙，阻礙藥物之生產與流通；（3）使需藥物智慧財產權為工具始能達成之健康人權目標（如藉由藥物創新與生產以達成之生存發展目標），受到負面影響。因此，國際間對於藥物智慧財產權與藥物近用權利衝突之處理態度便轉趨保守，並認為除非在追求經濟發展及強化人類福祉之規範目的下始有討論之必要性⁴³⁵。

然而，跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任與國際藥物智慧財產權之政策目標間，並非單向平行且互不交集之關係。首先，藥物智慧財產權對於專利權人（專利藥廠）之權利保障，若完全不考慮其與藥物近用權利間之同盟關係(*alliance*)，則不僅後者權利將受到嚴重限縮，對前者權利之保障亦將成為緣木求魚。蓋若忽略藥物智慧財產權對開發中國家公共健康之影響，則開發中國家在對藥物之需求持續與相對應偏高之利潤吸引下，將導致其國內非專利藥廠寧可冒違反智慧財產權法律規範之風險，仍執意要複製專利藥物之可能性大增；其結果不僅使執法成本大幅增加形成負擔，藥物黑市亦將由此而產生，對於藥物之正常流通與原開發藥廠之市場造成嚴重干擾，甚至可能進一步導致藥物濫用之情況，而使該藥物之品質與評價均受到威脅⁴³⁶，大幅降低跨國製藥企業之利潤空間。

434 KARIN TIMMERMANS & TOGI HUTADJULU, THE TRIPS AGREEMENT AND PHARMACEUTICALS 14-15 (Report of an ASEAN Workshop on the TRIPS Agreement and Its Impact on Pharmaceuticals, 2-4 May 2000), available at <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1459e/> (last visited Dec. 13, 2010).

435 徐遵慈（註432），頁89。

436 Werhane & Gorman, *supra* note 265, at 280.

另一方面，藥物黑市之存在亦將對原來國際藥物智慧財產權體系所欲達成排除藥物流通障礙並促進市場自由化之目標，形成障礙⁴³⁷。因此，若僅單純依賴藥物智慧財產權體系而完全忽略其與藥物近用權利之連結，則藥物自由市場與貿易之正常運作並無法達成；惟有同時兼顧藥物近用權利與藥物智慧財產權之整合體系，始能平衡不同權利之衝突並避免開發中國家落入「貧窮陷阱」⁴³⁸，使國際藥物智慧財產權體系不致因開發中國家社經體系之崩潰而瓦解⁴³⁹，並能確實達到促進自由市場經濟、保障專利藥廠專利權與商業利潤之目的。

其次，不論 Amartya Sen 或 Jeffery Sachs 之研究均發現，自由市場經濟與全球化雖然能引導快速之經濟成長並改善所得，但若該成長不能進一步擴展至相關基本社會服務（如醫療、教育、社會安全等）並確保民眾之能力購買需要之基礎健康照護服務（包括藥物），則該國國民之生活品質將大幅受限，經濟成長也將遇到瓶頸⁴⁴⁰。舉例而言，以同樣具有高經濟成長之台灣、中國與巴西作比較，前者對健康醫療之重視所形塑之社會機會擴張，不僅有助於平均餘命之增加，亦有助於普遍之經濟參與，並進一步對產業經濟發展形成正面影響⁴⁴¹；即令未達高度經濟發展之國家（如1994年之中國），因其各種發展核心（包括經濟發展）所在之社會機會（包括

437 若各國對藥品智慧財產權之保障不同，或國際上欠缺對藥品智慧財產權之規範，對於該商品之流通勢必造成嚴重之干擾，並將進一步對國際貿易造成扭曲與障礙，並嚴重影響各國之經濟利益。羅昌發，WTO 下之智慧財產權保護與貿易自由化之關係，收於：GATT/WTO 與我國貿易：國際經貿法研究（四），頁132（1996年）。羅昌發，國際貿易法，頁641（1999年）。吳全峰（註6），頁634。

438 所謂「貧窮陷阱」係指國家因缺乏基本之發展資本（包括人力資本、商業資本、基礎工程資本、自然資本、公共資本、知識資本），而無法確保赤貧者擁有足夠資源與能力作為爬升經濟發展階梯之基礎。Jeffery D. Sachs 著，鐵人庸譯（註84），頁317-318。

439 吳全峰（註6），頁645-646。

440 SEN, *supra* note 82, at 53. Jeffery D. Sachs 著，鐵人庸譯（註84），頁399-402。

441 SEN, *supra* note 82, at 46-49.

醫療基礎設施等）均較巴西保障完整，其平均餘命亦因此偏高（並因此幫助出生率之降低、基礎教育之增強），而得以進一步支持引導(support-led)作為經濟成長基本動力之經濟交易工具性能力之提升⁴⁴²。既然藥物近用權利與藥物智慧財產權間之互動是不可避免且交互影響，若要硬將其連結切割或刻意忽視其間之連結，其結果將導致兩種權利間有系統地彼此貶抑與侵害⁴⁴³；因此，跨國製藥企業若仍拒絕正視藥物近用權利保障責任之重要性，並以藥物智慧財產權保障作為維持其經濟利益之唯一手段，則在地方經濟弱化、國際經濟不平等惡化所導致之市場失靈下，最終必然亦將傷害跨國製藥企業之經營效益。

最後，基本藥物之近用缺乏將導致原可避免之大量人口死亡（尤其集中於青壯年、中產階級）⁴⁴⁴，其所造成之影響不僅是當地國家經濟力、購買力之大幅衰退，亦將造成跨國製藥企業在地主國市場拓展之障礙、勞動人力之損失等對商業經濟利益具有實質意義之傷害⁴⁴⁵。進一步，假設缺乏藥物近用所影響者為傳染性疾病之散播，則其後續影響更不限於特定族群或國家，對商業活動之限制與經濟發展之影響更是全球性的。因此，藥物近用權利保障與藥物智慧財產權保障所欲達成之經濟發展目標並非截然二分；而不適當或不完全之藥物近用權利保障所引發之負面影響力，其廣泛程度（不論就地域性或影響層面而言）亦使跨國製藥企業無法自外於外。因此，跨國製藥企業藥物近用權利保障之人權責任之建立，並非必然與國際藥物智慧財產權體系之政策目標牴觸。

442 *Id.* at 40-41. Jeffery Sachs 亦發現，非洲國家即使有相同之經濟自由，其成長速度仍然較同一層次之國家低約3%，而主要原因便在於包括疾病與健康照護在內之基礎公共建設等議題，在經濟發展之過程中被忽略。Jeffery D. Sachs 著，鐵人庸譯（註84），頁399-402。

443 Jack Donnelly 著，江素慧譯，普世人權：理論與實踐，頁42-43（2007年）。

444 Ellen't Hoen, *TRIPS, Pharmaceutical Patents, and Access to Essential Medicines: A Long Way from Seattle to Doha*, 3(1) *CHI. J. INT'L L.* 27, 31-33 (2002).

445 Werhane & Gorman, *supra* note 265, at 280.

因此，賦予跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任，並不一定必然危及藥物智慧財產權之整體架構。不論是 TRIPS 協定或 TRIPS-plus，其影響層面已非單純之藥物國際貿易，亦非少數藥物近用權利侵害之個案所能涵括；尤其因藥物之生產對社會公共健康具有決定性之影響，已非單純之經濟活動而被賦予明顯之社會性價值，故對醫藥衛生政策制定及藥物生產具有廣泛影響力之國際藥物智慧財產權規範，並不宜被單純視為對屬於私權之藥物智慧財產權保障⁴⁴⁶，而應考慮與藥物近用權利間之同盟關係(alliance)。也因此，藥物智慧財產權典範便藉由其對多數非特定民眾之健康或生命所產生之普遍影響，而與健康人權典範產生必然且不可忽視之連結關係⁴⁴⁷；兩者體系內之法條與規則不應絕對之截然二分且互不干涉，以避免忽略不同典範所堅持之不同價值與目的，從而恣意地將特定價值（不論是藥物智慧財產權或健康人權）置於其他同等重要之價值上⁴⁴⁸。

陸、重新思考跨國製藥企業與藥物近用權利之關係

綜合前文之討論與分析，由於跨國製藥企業對於國際事務與相關法規制定（如國際貿易法）之參與程度日深且具實質之影響力，而健康人權事務（尤其是藥物近用權利之核心內涵）之內涵亦漸趨多元複雜；因此，跨國製藥企業不僅應被賦予保障藥物近用權

446 The preamble of the TRIPS, “[R]ecognizing that intellectual property rights are private rights.”

447 吳全峰（註6），頁643-657。

448 如 TRIPS 協定例外規定之模糊且不統一，若無人權典範之適度補充，將使國家有充分之權限解釋「必要」或「緊急」之意涵，亦使其有可能在無正當理由之情況下恣意地排序經濟利益或公共衛生之重要性，從而不當地顛覆經貿利益與公共衛生之平衡可能性。吳全峰（註6），頁623、630。

利之人權責任，其責任之內容亦應予以細緻化，而不宜以僅具軟性道德規範之社會責任或慈善行為（屬「得為義務」之範疇）加以規範。在某些特定事項上賦予跨國製藥企業直接之人權責任(direct human rights responsibilities)，甚至進一步要求該人權責任強度應達「應為義務」以上⁴⁴⁹，以避免藥物近用權利受侵害或限制之情況發生（詳見第肆節），應有其必要性。尤其跨國（製藥）企業既然要求應被賦予某些特定之國際人權——如歐洲人權法院(European Court of Human Rights)便承認跨國企業應有公平審判(fair trial)、表意自由(freedom of expression)⁴⁵⁰、隱私權(privacy)等權利⁴⁵¹；則相同地，透過國際條約亦同樣地可將直接賦予跨國製藥企業特定之人權責任⁴⁵²。雖然這類人權責任之具體落實多仍回歸到內國法之執行層面，但其重要性在於藉由跨國製藥企業藥物近用權利保障責任之確立，將可建構人權落實之概念體系(conceptual framework)，而不致於因跨國製藥企業之私領域性質而妨礙國家依法強制要求其負擔或實踐國際人權法之具體內涵⁴⁵³。但要強調者為，對於跨國製藥企業直接人權責任之賦予並非嘗試改變國際人權法既有以國家為主體之體系架構，而只是在國家保障人權義務因主客觀因素而無法具體實現時（見前文第參節之說明），藥物近用權利之保障不致成為虛幻之權利保障。

449 Wu, *supra* note 19, at 118-19.

450 Autronic AG v. Switzerland, Eur. Ct. H.R. Series A.178 (1990); 12 (1990) E.H.H.R. 485, at paragraph 47.

451 Michael K. Addo, The Corporation as a Victim of Human Rights Violations, in HUMAN RIGHTS STANDARDS AND THE RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS 187-96 (Michael K. Addo ed., 1999).

452 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS, *supra* note 161, at 56-57. 類似之情況可參考燃油污染損害民事責任國際公約(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage)第3條，其中要求船舶所有人應對船載燃油或源自船舶的燃油引起的污染事故負責。

453 *Id.*

一、跨國製藥企業之直接責任(Direct Responsibilities)

雖然直接透過國際法規課與跨國製藥企業一定之人權責任以保障藥物近用權利有其必要性（如強制揭露營運資訊以避免跨國製藥企業濫用其市場獨占地位），但相關國際文件對於跨國（製藥）企業之直接人權責任要求繁雜且未有定論。

Hunt 所提出要求跨國製藥企業負擔保障藥物近用權利責任之 Guidelines for Pharmaceutical Companies 應可作為後續分析之起點⁴⁵⁴：

- (1) 一般規定(general)（第1-4段）：除再度確認健康人權之重要性外，亦確認僅承認健康人權並無助於該權利之保障，實務運作上之挑戰才是健康人權保障之核心議題；因此強調「跨國製藥企業之策略、政策、計劃、企劃項目、活動均應將國際人權納入考量，包括享有可達到之最高健康標準之權利」⁴⁵⁵以及「製藥企業應避免任何作為，若該做為可能鼓勵國家違反其國內法或國際法所規範人權義務」⁴⁵⁶。
- (2) 弱勢個人、社區與族群(disadvantaged individuals, communities and populations)（第5段）：要求製藥企業應個別關注市場中弱勢族群（包括女性、兒童、老人、赤貧者）之藥物近用權利保障⁴⁵⁷，尤其是有關平等(equality)與不受歧視

⁴⁵⁴ Khosla & Hunt, *supra* note 11, at 2.

⁴⁵⁵ Paragraph 2 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should integrate human rights, including the right to the highest attainable standard of health, into the strategies, policies, programmes, projects and activities of the company.”

⁴⁵⁶ Paragraph 4 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should refrain from any conduct that will or may encourage a State to act in a way that is inconsistent with its obligations arising from national and international human rights law, including the right to the highest attainable standard of health.”

⁴⁵⁷ Paragraph 5 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “Whenever formulating and implementing its strategies, policies, programmes, projects and

(nondiscrimination) 方面之人權議題。而此亦與 CESCR General Comment No. 14第12(b)段所強調之不歧視原則相呼應⁴⁵⁸。

- (3) 資訊透明(transparency) (第6-8段)：確認自國際人權典範中有關資訊透明之規範，應可推論出可以證據推翻之「製藥企業應揭露與藥物近用有關之資訊」之假定 (rebuttable presumption，允許在隱私權保障下之例外)⁴⁵⁹。其中又與以下之責任類型交互為用：

- (a) 公共政策之影響力、宣傳與遊說(public policy influence, advocacy and lobbying) (第17-19段)：確認製藥企業大量資源之遊說行動將可能對藥物近用產生正面（如降低藥物之賦稅）或負面（如提高藥物智慧財產權之保護門檻）之影響⁴⁶⁰；因此要求跨國製藥企業⁴⁶¹與意見領袖、

activities that bear upon access to medicines, the company should give particular attention to the needs of disadvantaged individuals, communities and populations, such as children, the elderly and those living in poverty. The company should also give particular attention to the very poorest in all markets, as well as gender-related issues.”

⁴⁵⁸ 請參閱註54。

⁴⁵⁹ Paragraph 6 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “In relation to access to medicines, the company should be as transparent as possible. There is a presumption in favour of the disclosure of information, held by the company, which relates to access to medicines. This presumption may be rebutted on limited grounds, such as respect for the confidentiality of personal health data collected during clinical trials.”

⁴⁶⁰ Paragraph 17 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should disclose all current advocacy and lobbying positions, and related activities, at the regional, national and international levels, that impact or may impact upon access to medicines.”

⁴⁶¹ Paragraph 18 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should annually disclose its financial and other support to key opinion leaders, patient associations, political parties and candidates, trade associations, academic departments, research centres and others, through which it seeks to influence public policy and national, regional and international law and practice. The disclosure

病人團體、政黨或候選人、行會、學術機構或研究中心⁴⁶²應揭露前者所提供之經濟或其他支持。

(b) 符合倫理之行銷(ethical promotion and marketing) (第39-41段)：主張跨國製藥企業應揭露其行銷之相關計畫內容與成本⁴⁶³。

(c) 公私夥伴關係(public private partnership) (第42-45段)：著重於利益衝突(conflicts of interest)之資訊揭露⁴⁶⁴。

(4) 管理、監督與責任(management, monitoring and accountability) (第9-14段)：確認有效、透明與可監測之機制(effective, transparent and accessible monitoring and accountability mechanisms)為避免藥物近用權利侵害之基本要件，同時提出包括提供定性定量訊息之年度報告(a comprehensive annual report, including qualitative and quantitative information)、外部獨立監督機制(independent external mechanisms)等機制作為制度建立之參考。

(5) 貪污腐敗(corruption) (第15-16段)：確認貪污為藥物近用權利落實之重大障礙，如貪汙問題造成公共健康服務資源之耗盡，便可能使無能力自費負擔必要藥物之赤貧者面臨更嚴重

should extend to amounts, beneficiaries and channels by which the support is provided.”

462 Paragraph 19 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “When providing any financial or other support, the company should require all recipients to publicly disclose such support on all appropriate occasions.”

463 Paragraph 41 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should publicly disclose its promotional and marketing policies and activities, including costs.”

464 Paragraph 43 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “If a company joins a Public Private Partnership, it should disclose any interest it has in the Partnership’s decisions and activities.”

之健康問題；故製藥企業應遵守有關聯合國之反腐敗公約 (Convention against Corruption) 及各國反貪污內國法規範⁴⁶⁵。

- (6) 品質(quality) (第20段)：跨國製藥企業所生產之藥物應符合 WHO 之優良製造規範指引 (Good Manufacturing Practice Guidelines，以下簡稱 GMP Guidelines)；而此亦與 CESCR General Comment No. 14第12(d)段所要求「衛生設施、商品或服務不僅應應考量文化相容性，且必須符合科學和醫學之適當與品質優良標準」相呼應⁴⁶⁶。
- (7) 臨床試驗(clinical trial) (第21-22段)：強調跨國製藥企業之人權責任之應擴及醫療倫理(medical ethics)⁴⁶⁷。
- (8) 受忽略疾病(neglected diseases) (第23-25段)：確認跨國製藥企業應公開承諾（但亦僅止於道德宣示而未賦予其更強烈之責任），促進針對歷史上廣受忽視與貧窮相關疾病之研究與發展⁴⁶⁸。

⁴⁶⁵ Paragraph 15 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “A company should publicly adopt effective anti-corruption policies and measures, and comply with relevant national law implementing the United Nations Convention against Corruption.”

⁴⁶⁶ 請參閱註382。

⁴⁶⁷ Paragraph 21 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “A company’s clinical trials should observe the highest ethical and human rights standards, including non-discrimination, equality and the requirements of informed consent. This is especially vital in those States with weak regulatory frameworks.” Paragraph 22, “The company should conform to the Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, as well as the World Health Organisation Guidelines for Good Clinical Practice.”

⁴⁶⁸ Paragraph 23 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should make a public commitment to contribute to research and development for neglected diseases. Also, it should either provide in-house research and development for neglected diseases, or support external research and development for neglected diseases, or both. In any event, it should publicly disclose how much it contributes to and invests in research and development for neglected diseases.”

- (9) 專利與授權(patents and licensing) (第26-32段)：雖承認 TRIPS 協定之重要性，但亦強調跨國製藥企業應尊重協定中相關例外條款之靈活性(flecibilities)⁴⁶⁹，且應藉由自願之非專屬授權(non-exclusive voluntary licences)促進藥物近用⁴⁷⁰ (值得注意的是，Guidelines for Pharmaceutical Companies 在此處強調自願之重要性，與本文第伍、二、(二)節認為在傳統健康人權概念下，跨國製藥企業主張其人權責任應侷限於自願性之「得為義務」相同)。
- (10) 定價、折扣與捐贈(pricing, discounting and donations) (第33-37段)：承認跨國製藥企業雖然有責任提高利潤與公司價值，但亦有保障藥物近用權利之人權責任⁴⁷¹；因此，跨國製藥企業有責任考慮不同國家之經濟發展與其國民之購買能力⁴⁷²，並擬定包括差別訂價在內之藥物近用計畫⁴⁷³。

469 Paragraph 27 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The company should respect the letter and spirit of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (2001) that recognises a State’s right to protect public health and promote access to medicines for all.”

470 Paragraph 30 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “As part of its access to medicines policy, the company should issue non-exclusive voluntary licences with a view to increasing access, in low-income and middle-income countries, to all medicines. The licences, which may be commercial or non-commercial, should include appropriate safeguards, for example, requiring that the medicines meet the standards on quality, safety and efficacy... They should also include any necessary transfer of technology. The terms of the licences should be disclosed.”

471 Commentary on paragraphs 33-37 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “While recognising they have a responsibility to enhance shareholder value, companies also have a human rights responsibility to extend access to medicines for all, including disadvantaged individuals, communities and populations.”

472 Paragraph 33 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “When formulating and implementing its access to medicines policy, the company should consider all the arrangements at its disposal with a view to ensuring that its medicines are affordable to as many people as possible. ... [T]he company should give particular attention to ensuring its medicines are accessible to disadvantaged individuals, communities and populations, including those living in poverty and the very poorest in all markets. The arrangements should include, for example, differential pricing

- (11) 製藥企業組織(associations of pharmaceutical companies) (第46-47段)：為避免製藥企業利用專業協會作為規避人權責任之手段，故要求其應採取一切合理之步驟確保所參與之專業協會（如 PhRMA）之運作符合本人權準則⁴⁷⁴。

但因限於篇幅，本文並無法逐一討論相關之內容，故僅能參考跨國製藥企業侵害藥物近用權利之常見型態（詳見第肆節之討論），針對較為重要之跨國製藥企業藥物近用權利保障責任進行討論：即針對 Guidelines for Pharmaceutical Companies 中所條示之藥物市場獨占地位之濫用禁止（參考第26段、第32段）、藥物資訊之透明公開化（第6-8段、第39-41段）、藥物近用權利核心價值之實踐（前言、第5段與第33-38段）等內容進行討論⁴⁷⁵。而其中特別值得

between countries, differential pricing within countries, commercial voluntary licences, not-for-profit voluntary licences, donation programmes, and Public Private Partnerships.”

473 Paragraph 34 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “The arrangements should take into account a country’s stage of economic development, as well as the differential purchasing power of populations within a country. The same medicine, for example, may be priced and packaged differently for the private and public sectors within the same country.”

474 Paragraph 47 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “A company that is a member of an association of pharmaceutical companies should take all reasonable steps to ensure the association fully conforms to these Guidelines.”

475 就「禁止濫用獨占地位」與「藥物資訊透明公開化」之規範，或有論者質疑可從既有之內國法規（如公平交易法、消費者保護法），或基於國際人權法課予國家建立相關法制之義務，取得管制跨國製藥企業之依據。但單純倚賴國家實踐藥物近用權利之主張，而間接對跨國製藥企業之商業行為進行管制，仍有其盲點。(1) 國家可能迫於跨國製藥企業之壓力而不願制定或消極執行相關法律，以致無法適當監督跨國製藥企業是否盡到其所應負擔之法律義務。因此，單純依賴國家對跨國製藥企業管制之間接義務以達到禁止濫用獨占地位與藥物資訊透明公開之目的，可能仍有不足。故本文認為除既有之法律規範外（本文並不否定相關法規之重要性），仍應建立跨國製藥企業保障藥物近用權利之直接人權責任。(2) 公平交易法或消費者保護法之關心重點並不一定與藥物近用權保障直接相關；如公平交易法關心之重點為競爭秩序之維持，而消費者保護法對於人民是否得享有完整（包括私人間相互主張）之積極消費資訊公開請求權，亦有所爭議。因此，為避免內國法規之局限性，本文主張除國家管制跨國製藥企業之間接人權義務外，跨國製藥企

注意者為藥物近用權利核心價值之實踐；因藥物近用權利之漸進滿足之軟性權利性質，使得目前國際人權法對於跨國製藥企業是否有直接人權責任透過差別訂價或藥價折扣等方式保障民眾之藥物近用，不無疑問（詳見第伍、二、（一）節之討論）。但本文認為，若藥物近用權利內涵之性質若屬 *jus cogens* 規律之範圍（如涉及生命權之保障），則無需特別要求國家行為參與其中，即可直接要求跨國製藥企業負擔相關人權責任（詳見第伍、二、（二）節之討論）。關於這部分藥物近用權利之內涵（須要求跨國製藥企業負擔資源耗用以滿足受益權之部分），本文嘗試利用 Norman Daniels 之平等機會理論與生物醫學模型(biomedical model)進行分析，並建議與個人最低限度健康標準(minimum standard of health)——即基本能力(basic capabilities)之行使——有密切相關之藥物，始能被視為藥物近用權利之核心內涵⁴⁷⁶（詳見後文第陸、一、（三）節之討論）。

（一）藥物市場獨占地位之濫用禁止

依照 Leisinger 所提階層式企業人權責任架構（見第伍、二、（二）節：圖一），跨國製藥企業應負擔避免濫用市場獨占地位之人權責任⁴⁷⁷，且該人權責任係屬具法律強制力之「應為義務」之範疇：因跨國製藥企業本就應負擔不可談判減損(non-negotiable)之人權責任⁴⁷⁸在遵循法律規範之前提下進行正常之商業活動(normal business activities)⁴⁷⁹。換言之，為避免不適當之藥物定價策略或排除學名藥廠之競爭，跨國製藥企業應負擔人權責任確保公平與公開

業之直接人權責任仍有建立之必要。

476 吳全峰（註6），頁675-680。

477 雖然避免濫用市場獨占地位之人權責任並不會直接與藥物近用權利連結，但若跨國製藥企業疏於落實該責任，卻將間接阻礙政府對藥物近用權利之保障，如造成政府無法負擔龐大之藥費支出，或使政府公共資源過度集中於特定藥物而影響民眾近用其他健康照護之機會。

478 Klaus M. Leisinger, *Capitalism with a Human Face: The UN Global Compact*, 28 JCC 113, 122 (2007).

479 Leisinger, *supra* note 18, at 12.

競爭之維持，且不濫用其因藥物智慧財產權所獲得之市場獨占地位；而這種濫用禁止應包括避免商業行為之詐欺與欺瞞(avoidance of deception or fraud)、尊重國家之商業秩序、不與競爭之企業達成協議以間接或直接決定價格或維持其壟斷獨占之地位⁴⁸⁰、不對非實質或細微之修正(insignificant or trivial modifications)申請專利權保障⁴⁸¹、不尋求更嚴格之藥物智慧財產權保障規定（如要求更嚴格之強制授權條件）⁴⁸²、拒絕賄賂與採取反貪污腐敗措施⁴⁸³、避免不適當之行銷手段、避免訂定不合理之高貴藥物價格⁴⁸⁴等。舉例而言，若專利藥廠藉由給付高額和解金交換學名藥廠放棄推出學名藥、或與學名藥廠合作生產品牌學名藥以控制價格與銷售（詳見第肆、三節之討論）、或將暢銷藥物稍作改變而以原藥之「加強」版本促銷⁴⁸⁵等商業行為，便應視為對此人權責任之違反。

雖然這類不正當合作亦可能受到公平交易法規範之管制⁴⁸⁶（如

⁴⁸⁰ Paragraph 13(a) of the Norms for TNCs.

⁴⁸¹ Paragraph 32 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “In low-income and middle-income countries, the company should not apply for patents for insignificant or trivial modifications of existing medicines.”

⁴⁸² Paragraph 26 of the Guidelines for Pharmaceutical Companies, “...The company should make and respect a public commitment not to lobby for more demanding protection of intellectual property interests than those required by TRIPS, such as additional limitations on compulsory licensing.”

⁴⁸³ Leisinger, *supra* note 18, at 584. 此亦即 Guidelines for Pharmaceutical Companies 第15段所陳述之重點，請參閱註465。

⁴⁸⁴ 如 Leiginger 便強調製藥企業除追求利潤外，亦應負擔避免醫療費用過度攀升(avoiding costly hospitalization)之社會責任(social responsibility)。Id. at 585.

⁴⁸⁵ 如 Lilly 在 Prozac（百憂解，治療憂鬱症之藥物）之專利權屆至前，推出與 Prozac 同等劑量之藥物 Sarafem，僅外觀從綠色改為粉紅、粉紫相間，以及適應症（治療經前症候群）不同。就其適應症不同是否足以申請專利權保護容有爭議，但 Lilly 卻因將該藥物進行兒童試驗而額外取得6個月市場專賣權之展延；但學者對於初有月經之兒童是否有必要以藥物治療，甚至因此給予特定藥物市場專賣權，便出現爭論。Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁217-218。

⁴⁸⁶ 如本文第肆、三節之討論，美國 FTC 便對製藥企業之不公平競爭表達過關切。Competition in the Pharmaceutical Industry: Hearings before the Comm. On Commerce, Science and Transportation of U.S. Senate (2002) (statement of Timothy J.

Valley Drug v. Geneva Pharmaceuticals)⁴⁸⁷，但在私法自治原則之原則下，實無法在公交易法規範之體制下完全禁止專利藥廠與學名藥廠間之協議，尤其當其涉及具市場獨占性質之藥物智慧財產權保障時，如何明確區隔其是否濫用市場獨占地位以獲取不適當之利益，便可能成為爭議核心⁴⁸⁸。因此，如 Medicare Act 亦無法非完全禁止專利藥廠與學名藥廠間之協議，主要原因便是因為該等協議往往涉及藥物智慧財產權之保障，而該權利之本質本就在賦予智慧財產權人專屬獨占市場之地位及因此而獲取利益之權利，故不宜遽然認定該類協議即造成市場競爭之障礙⁴⁸⁹。因此，判斷跨國製藥企業利用其獨佔地位所為之商業行為是否具正當性，若單獨以公平交易法作為規範基礎，便可能有其侷限性——僅重視對市場競爭之影響，而忽略對民眾藥物近用權利之實質限縮——故除公平交易法外，似可另以跨國製藥企業所應負擔之人權責任作為政策工具，判斷該商業行為對藥物智慧財產權之影響，並以此作為補充性之解釋⁴⁹⁰，以填

Muris, Chairman of the Federal Trade Commission), available at <http://www.ftc.gov/opa/2002/04/biovail.shtm>, (last visited Feb. 21, 2008). FTC, *supra* note 191, at 39-64.

487 在本案中，Abbott Laboratories (Abbott)對 Geneva Pharmaceuticals (Geneva)及 Zenith Goldline Pharmaceuticals (ZGP)提出起所擁有專利藥物(Hytrin)之專利侵權訴訟；後兩造分別達成和解，並約定(1) Geneva 及 ZGP 承諾除非有其他廠商合法於市場中銷售 Hytrin 學名藥或 Hytrin 之專利到期，其將不會銷售任何 Hytrin 之學名藥，或轉讓其上市許可相關權利；(2) Abbott 承諾於一定期間內，每3個月給付600萬美元予 Geneva 及 ZGP。由於 Geneva 及 ZGP 已依 Hatch-Waxman Act 提出簡化新藥申請(Abbreviated New Drug Application, ANDA)，並依法享有180日市場獨家專屬期間；但因該和解契約，不僅 Geneva 及 ZGP 無法於市場中銷售 Hytrin 學名藥，且該180日市場獨家專屬期間亦因無任何之商業行銷活動而無法起算，導致其他學名藥廠無法進入市場。本案初審法院認為該三家公司所作之和解契約係屬水平競爭者瓜分市場之行為，應屬違反反托拉斯法之行為；但上訴法院卻認為本案涉及專利權之保障，而專利權之本質本就在賦予專利權人專屬獨佔市場之地位及因此獲取利益之權利，故不宜在未經詳細分析獨占效果及相關因素前便遽以認定該和解契約係當然(per se)違反反托拉斯法。Valley Drug v. Geneva Pharmaceuticals, 350 F.3d 1181 (2003).

488 *See id.*

489 黃文鴻(註242)，頁36。

490 Andrew T.F. Lang, *Re-Thinking Trade and Human Rights*, 15(2) TUL. J. INT'L &

補相關政策之盲點⁴⁹¹。

以不適當之藥物定價為例作說明，南非 *Hazel Tau v. GlaxoSmithKline, Boehringer* 乙案所提出之標準或許可以作為判斷跨國製藥企業是否在藥物智慧財產權之保障下濫用其市場獨占地位，訂定過高之藥物價格(*excessive price*)而對民眾藥物近用權利造成侵害。南非競爭委員會在本案中，主張藥物售價是否合理——攸關其是否違反公平競爭法(*Competition Act*)⁴⁹²——應以以下因素作為判斷標準：藥物價格與其經濟價值(*economic value*)不具合理關係(*reasonable relation*)或超越其經濟價值⁴⁹³；而所謂不合理關係則考慮⁴⁹⁴（1）藥物價格在自由競爭市場中（如無涉藥物智慧財產權之市場獨占權利）是否包含不合理比例之利潤；（2）藥物研發補貼(*allowance*)是否不合理；（3）對藥物研發提供之經濟誘因或對其研發風險之補貼是否不合理；（4）過高之藥物價格是否可能對消費者造成不合理之損害(*detriment*)；（5）過高之藥物價格是否可能對消費者受憲法保障之權利或國際人權造成不合理之侵害(*adverse*

COMP. L. 335, 376-77 (2007).

491 但要強調的是，本文並非主張跨國製藥企業應在公平交易法中扮演主導之角色，甚至負擔審查其契約是否違反公平交易法之規範，從而混淆國家與企業之角色。本文在此僅嘗試說明，若僅以公平交易法規範藥物市場獨占地位之濫用禁止，則關心之重點將被侷限在市場競爭障礙之排除，而忽略民眾藥物近用權利可能受到之實質影響——如專利藥廠與學名藥廠間之協議，雖可能限制民眾藥物近用權利，但卻可能因未造成市場競爭障礙，而不受公平交易法之規範。有鑑於公平交易法之侷限性（且藥物近用權利亦非其關心重點），故本文建議對於跨國製藥企業利用其獨佔地位所為之商業行為是否具正當性，除應考量對市場競爭之影響（公平交易法），亦應將對民眾藥物近用權利之影響納入判斷。

492 Article 8(a) of the Competition Act, “It is prohibited for a dominant firm to: (a) charge an excessive price to the detriment of consumers;”

493 Article 1(1)(vii) of the Competition Act, “(aa) bears no reasonable relation to the economic value of that good or service; and (bb) is higher than the value referred to in subparagraph (aa).”

494 *Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al.* (Competition Commission of South Africa), at para. 60.

impact)。而其中第五點便係以國際人權典範之法理基礎出發，系統性地尋求不同利益或權利衝突之平衡。因此，除藥物智慧財產權與公平交易法規範外，跨國製藥企業亦應負擔相關健康人權責任，不應為實質阻擋學名藥廠進入市場以維持其市場獨占與經濟利益之目的，而濫用藥物智慧財產權制度（如浮濫登錄藥物智慧財產權資訊、不公平競爭、不當聯合行為等）。

最後，跨國製藥企業亦有責任不以撤資或退出市場做為要脅而阻止任何藥物近用權利落實之可能性。詳言之，跨國製藥企業常以撤資或退出市場做為要脅手段，以限縮國家制定對其利潤不利之藥物近用政策之空間；而跨國製藥企業若在該國之藥物市場具獨占地位，其商品或產業往往對民眾之健康亦具重要性（如對特定專利藥之依賴），則其撤資威脅之影響力便相對顯著⁴⁹⁵。因此，跨國製藥企業對於國際藥物智慧財產權體系下之公共健康保障措施（如強制授權），不應再以其經濟實力作為手段，威脅地主國附加 TRIPS 協定所未規範之特定條件，從而大幅降低 TRIPS 協定中公共健康保障面向（藥物近用權利保障）之影響力。此亦為 *Guidelines for Pharmaceutical Companies* 第26段所強調之重點：「跨國製藥企業應充分尊重在 TRIPS 協定下為平衡藥物近用所賦予各國得使用之權利，包括強制授權和平行輸入之規定；且跨國製藥企業應公開承諾不進行遊說以要求政府訂定較 TRIPS 協定更為嚴格之智慧財產權利保障政策，如對於強制許可之額外限制」⁴⁹⁶。

495 舉例而言，跨國藥廠及代理藥商針對台灣中央健康保險局調降藥價之措施，便以70項藥品（包括專利藥）退出台灣市場作為手段，脅迫健保局進行談判。施靜茹，健保砍藥價，藥廠怒：70藥品退場，聯合報，2011年10月28日A4版。

496 Paragraph 26 of the *Guidelines for Pharmaceutical Companies*, “The company should respect the right of countries to use, to the full, the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (1994), which allow flexibility for the purpose of promoting access to medicines, including the provisions relating to compulsory licensing and parallel imports. The company should make and respect a public commitment not to lobby for more demanding

(二) 藥物資訊之透明公開化

藥物市場具有資訊不對等、與健康或生命具不可替代之關聯性等特殊性已如前述（詳見第肆、二節之討論），但造成其市場失靈之原因有一大半源自於跨國製藥企業對相關藥物資訊握有主導權；因藥廠較病人擁有更多有關藥物研發、質量、安全性、有效性之專業知識，遂使得買方（病人）與賣方（藥廠）在資訊不對等之限制下，無法充分發揮需求與供給間調節價格之作用，並造成市場失靈之狀況。因此，為避免不適當之藥物定價策略，在適當可行之範圍內，跨國製藥企業應有責任確保與其業務活動、公司結構、財務狀況與業績等有關之資訊，能及時、定期、可信且充分地揭露⁴⁹⁷。而 *Guidelines for Pharmaceutical Companies* 更進一步擴張揭露藥物資訊之責任範圍，要求製藥企業對於與藥物近用有關之資訊（第6段）⁴⁹⁸、相關遊說活動（第17-19段）⁴⁹⁹、利益衝突（第43段）⁵⁰⁰、行銷成本與計畫內容（第41段）⁵⁰¹、以及與藥物安全、療效、副作用相關之資訊（第39段）⁵⁰²均有主動公開揭露之責任，以避免製藥企業可能對政策之不當影響。

protection of intellectual property interests than those required by TRIPS, such as additional limitations on compulsory licensing.”

497 Chapter II paragraph 1 of the *Guidelines for MNEs*, “Enterprises should ensure that timely, regular, reliable and relevant information is disclosed regarding their activities, structure, financial situation and performance. This information should be disclosed for the enterprise as a whole and, where appropriate, along business lines or geographic areas. Disclosure policies of enterprises should be tailored to the nature, size and location of the enterprise, with due regard taken of costs, business confidentiality and other competitive concerns.”

498 請參閱註459。

499 請參閱註462。

500 請參閱註464。

501 請參閱註463。

502 Paragraph 39 of the *Guidelines for Pharmaceutical Companies*, “The company should take effective measures to ensure that all information bearing upon the safety, efficacy, and possible side effects of a medicine are easily accessible to individuals so they can take informed decisions about its possible use.”

就理論面探討，透過要求跨國製藥企業負擔揭露藥物資訊之人權責任，除可保障消費者之自主選擇權利外，亦可促使其遵守相關藥物近用權利保障之要求，並避免其濫用市場獨占地位之不當商業行為。首先，資訊之揭露(disclosure)與公開(transparency)對於藥物近用權利之保障有其正面意義；蓋知的權利基本上是由自由權所衍生出來的權利——若無適當藥物資訊之公開，而民眾無法近用或獲得正確資訊時，便可能因無法理解產品本身之特性與功能，而無法選擇適當且符合其價值觀與善觀念(conceptions of the good)⁵⁰³之健康照護方式與相對應之藥物，並對其自由選擇之判斷（如選擇何種藥物）造成影響，從而限制其自主權(autonomy)之行使⁵⁰⁴。因此，許多國家在醫療照護領域中均以告知後同意原則(informed consent)約束醫病關係，國際人權體系亦將其視為健康人權中之重要內涵，如 CESCR General Comment No.14第14(b)段便將近用健康照護相關資訊之權利（information accessibility，包括搜尋、接收與傳播相關健康照護資訊與意見之權利）⁵⁰⁵視為健康人權保障之特別法定義務(specific legal obligations)⁵⁰⁶與優先義務(obligations of

503 所謂善觀念是指個人依其價值觀所發展出各種終極目標所組成之有序族系。
JOHN RAWLS, JUSTICE AS FAIRNESS: A RESTATEMENT 19 (2001).

504 吳全峰、黃文鴻（註27），頁153-154。

505 Paragraph 14(b) of the CESCR General Comment No.14, "...Information accessibility: accessibility includes the right to seek, receive and impart information and ideas concerning health issues. However, accessibility of information should not impair the right to have personal health data treated with confidentiality."

506 Paragraph 35 of the CESCR General Comment No.14, "Obligations to protect include ... [s]tates should also ensure that third parties do not limit people's access to health-related information and services." Paragraph 35, "The obligation to fulfil ... include the provision of a public, private or mixed health insurance system which is affordable for all, the promotion of medical research and health education, as well as information campaigns, in particular with respect to HIV/AIDS, sexual and reproductive health, traditional practices, domestic violence, the abuse of alcohol and the use of cigarettes, drugs and other harmful substances. ..." Paragraph 37, "The obligation to fulfil (facilitate)...include: (i) fostering recognition of factors favouring positive health results, e.g. research and provision of information; ... (iii) ensuring that the State meets its obligations in the dissemination of appropriate information

comparable priority)⁵⁰⁷。

另一方面，藥物資訊之不透明亦將使跨國製藥企業之營業決策及商業行為不受監督，而得以規避政策管制（如採取聯合壟斷之行為）或市場監督（如訂定遠高出合理利潤之藥物價格），造成消費者在資訊不對稱之情形下受到不正當之權利侵害。尤其在經濟自由化、臨床實驗全球化之今日，跨國製藥企業之研發過程、生產鏈與決策模式均有某種程度之複雜性，在跨國製藥企業不主動甚至拒絕提供藥物相關資訊之前提下，不論是社會或母國政府均難有系統地收集或近用其在地主國之營業資訊，更遑論對其人權侵害行為進行外部之監督與管制⁵⁰⁸。因此，在跨國製藥企業對於藥物近用權利應負擔一定程度人權責任之前提下，社會對於相關營業及藥物資訊應有知悉之權利；亦即在資訊不對等情形下，以矯正既有之不平等與可能之市場失靈狀況作為目標，要求跨國製藥企業揭露相關資訊便有其實質之正當性⁵⁰⁹。以 AZT 之發展作為例子，便不難發現透明公開藥物資訊對藥物近用之重要性。AZT 本為失敗之癌症用藥，但在 AIDS 出現後，因美國國家衛生研究院及杜克大學研究團隊針對 AIDS 致病機轉之研究，並不斷測試不同之抗病毒藥物 (antiviral agent) 後，始發現 AZT 對 AIDS 之療效（包括確定人體中作用之劑量、進行臨床藥理實驗等）；但在過程中，Burroughs Wellcome 作為專利權人（AZT 甚至非其所研發，而係其以低價購入之失敗產品），卻在未置入任何資源於 AIDS 與 AZT 之相關研究

relating to healthy lifestyles and nutrition, harmful traditional practices and the availability of services; (iv) supporting people in making informed choices about their health.”

507 Paragraph 44(d) of the CESCR General Comment No.14, “The Committee also confirms that the following are obligations of comparable priority: ... (d) To provide education and access to information concerning the main health problems in the community, including methods of preventing and controlling them. ...”

508 陳彥君（註184），頁127-128。

509 陳彥君（註184），頁128。

之前提下，卻仍主張其對於該藥物之研發具有實質貢獻（並刻意忽略公共資源在相關研究之投入），故有權利獲得市場獨占之地位並坐享昂貴藥價之收益⁵¹⁰，從而導致 AIDS 病人近用 AZT 之經濟障礙。但在資訊不對等之前提下（如藥物研發成本之不確定），由於 Burroughs Wellcome 對於藥物研發與應用之成本投入並未公開，因此藥物價格及利潤是否適當、國家藥物近用政策是否能達成其政策目標，均無法作出深入之分析與判斷。美國最高法院於 *Bowsher v. Merk & Co.* 乙案中亦提出類似之質疑⁵¹¹；南非 FTC 在 *Hazel Tau v. GlaxoSmithKline, Boehringer* 乙案中亦發現若製藥企業不公開其投入藥物研發之資金比例，則對於判斷製藥企業是否濫用其市場獨占地位訂定不合理之高貴藥價，將缺乏具體判斷之依據⁵¹²（詳見第肆、二節之說明）。

關於跨國企業資訊之揭露，並非完全沒有先例⁵¹³——如瑞典政府自2009年起便制定統一之指標，要求其境內國營企業提出有關核心勞動基準之年度永續績效報告(annual sustainability report)⁵¹⁴；法國於2001年通過之「新經濟法規」(Nouvelles Régulations Économiques)，要求在市場上具有龐大資本額之跨國公司必須每年提出人權績效報告⁵¹⁵；而 Norms for TNCs 第15段及第16段亦要求跨國企業應定期彙報並評估其商業活動對人權之影響，且應受到

510 Marcia Angell 著，曾育慧譯（註14），頁56-58。

511 *Bowsher v. Merk & Co.*, 460 U.S. 824 (1983).

512 *Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al.* (Competition Commission of South Africa), at paras. 33-44, 64.

513 陳彥君（註184），頁130-132。

514 Christen Broecker, *Better the Devil You Know: Home State Approach to Transnational Corporate Accountability*, 41 N.Y.U. J. INT'L. & POL. 159, 206-08 (2008).

515 The Council of Bars and Law Societies of the European Union [CCEB], *Corporate Social Responsibility and the Role of the Legal Profession: A Guide for European Lawyers Advising on Corporate Social Responsibility Issues* 5 (Sept. 2003), available at <http://www.advokatsamfundet.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiler%2fCCBE%2fCCBE.CSR.pdf> (last visited Dec. 14, 2010).

（既存或有待建立）國際和國家機制之定期、獨立、透明之監督和核查⁵¹⁶。因此，在商業機密與病人隱私權保障之前提下，對於藥物價格政策之制定公式、利潤率之控制、同類藥物價格資訊之公布、報價目錄之發布等，跨國製藥企業均有責任予以系統化地公開；也只有在相關資訊透明化之前提下，社會始有能力判斷跨國製藥企業是否侵害民眾之健康人權——如濫用其市場獨占之地位訂定高貴之藥物價格以獲取超乎合理期待之經濟利益⁵¹⁷。而此亦為 *Guidelines for Pharmaceutical Companies* 第6-8段所強調跨國製藥企業應系統性揭露與藥物近用之相關資訊（包括應建立標準化機制以評估不同公司在不同時間之訊息揭露程度）⁵¹⁸之內涵。

進一步，依前述所分析，揭露藥物資訊之人權責任應視為法律

516 Paragraph 15 of the Norms, “As an initial step towards implementing these Norms, each transnational corporation or other business enterprise shall adopt, disseminate and implement internal rules of operation in compliance with the Norms. Further, they shall periodically report on and take other measures fully to implement the Norms and to provide at least for the prompt implementation of the protections set forth in the Norms. Each transnational corporation or other business enterprise shall apply and incorporate these Norms in their contracts or other arrangements and dealings with contractors, subcontractors, suppliers, licensees, distributors, or natural or other legal persons that enter into any agreement with the transnational corporation or business enterprise in order to ensure respect for and implementation of the Norms.” Paragraph 16, “Transnational corporations and other business enterprises shall be subject to periodic monitoring and verification by United Nations, other international and national mechanisms already in existence or yet to be created, regarding application of the Norms. This monitoring shall be transparent and independent and take into account input from stakeholders (including non-governmental organizations) and as a result of complaints of violations of these Norms. Further, transnational corporations and other business enterprises shall conduct periodic evaluations concerning the impact of their own activities on human rights under these Norms.”

517 Department for International Development, *supra* note 74, at 35.

518 Paragraph 7 of the *Guidelines for Pharmaceutical Companies*, “In conjunction with other pharmaceutical companies, the company should agree to standard formats for the systematic disclosure of company information and data bearing upon access to medicines, thereby making it easier to evaluate the performance of one company against another, as well as the performance of the same company over time.”

強制力之「應為義務」之範疇，除因國際人權法上認為資訊近用（information accessibility，包括尋找、接收與傳播健康照護相關資訊）為重要之健康人權內涵外，各國金融法規、消費者保護法規、或反貪污法規中均可見相類似強制揭露之規定⁵¹⁹，故製藥企業便應負擔遵循相關法規之義務。

（三）藥物近用權利核心價值之實踐

雖然因藥物近用權利之漸進滿足之國際人權地位，使其被視為軟性之道德權利而非具強制力之法律權利；但如前文第伍、二、（二）節所分析，因藥物近用權利之內涵係多元呈現，其部分核心內涵（尤其與生命權緊密相關之部分）所具有之獨特重要性，便使其跳脫傳統受益權之架構而具有國際絕對法之性質（如能滿足具優先性健康照護需要之基本藥物之近用）⁵²⁰。因此，若跨國製藥企業之商業行為可能侵害這類具國際絕對法價值之藥物近用權利核心要素時，實無任何法律上或商業上之理由足以排除跨國製藥企業在此特定情境下作為負擔藥物近用權利保障責任之主體⁵²¹。

其次，從分配正義之觀點觀察，因部份藥物（基本藥物）之近用對於個人作為正常、積極、合作之社會成員(normal, active, and fully cooperating members of the society)⁵²²之基本必要能力之維持（即基本健康，minimal health）具有重要性；亦唯有在適當之基本藥物需求被滿足之前提下，個人所得用以追求其理想生活目標之公平平等機會(fair equality of opportunity)始具有實質且重要之意義。蓋疾病（偏離正常物種功能(normal species functioning)⁵²³之不利狀

519 陳彥君（註184），頁127-128。

520 Shalev, *supra* note 30, at 99.

521 Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc., 244 F. Supp. 2d 289, 319 (S.D.N.Y. 2003).

522 John Rawls, *Social Unity and the Primary Goods*, in UTILITARIANISM AND BEYOND 159, 168 (Amartya Sen & Bernard Williams eds., 1982).

523 NORMAN DANIELS, JUST HEALTH CARE 32 (1995).

態)會使社會成員無法成為正常競爭者(normal competitors)與他人公平競爭有價值之社會職務⁵²⁴，故健康本身對於平等機會即具有實質影響力，並可作為支持自由平等公民自由運用其基本權利與自由之一般性必要手段⁵²⁵，從而具備追求個人最終生活目標(final ends of life)之平等機會(fair opportunities)之本質。而基本藥物近用為維持個人基本健康之重要要素，便與平等機會之維持產生直接之關聯性。因此，當個人因殘疾而處於最低必要能力(basic capabilities)之下且實質影響到其追求生活目標之平等機會時，社會便有義務提供健康照護（包括基本藥物）以協助個人恢復其必要能力。而跨國製藥公司作為社會成員從事商業活動，與其它社會成員相同，均與社會間成立事實上之社會契約關係(social contract)，且依該契約本旨，跨國製藥企業不僅不能從事危害社會之行為，亦應依循社會所建立並承認之分配正義原則，以促進社會整體之福祉⁵²⁶。因此，在社會嘗試解決健康照護分配所面臨之問題，跨國製藥企業並不能自外於社會中不同成員所能共同認可之分配原理原則；故跨國製藥企業對於影響個人基本健康之藥物（通常亦被視為藥物近用權利之核心內涵，而落入前述國際絕對法之範疇），應負擔健康人權之實踐責任應屬適當。

但對於如何判斷藥物近用權利內涵之優先順序——亦即判斷哪些健康照護需要具有優先性且可被賦予國際絕對法之地位——學者間則有不同之爭論⁵²⁷，包括以例示方式列舉符合藥物近用權利核心內容之「健康照護服務清單模式」(list-of-services approach)⁵²⁸、

524 ALLEN BUCHANAN, DAN W. BROCK, NORMAN DANIELS & DANIEL WIKLER, FROM CHANCE TO CHOICE: GENETIC & JUSTICE 74 (2000).

525 JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 174 (1971).

526 賴英照，從尤努斯到巴菲特——公司社會責任的基本問題，台灣本土法學雜誌，93期，頁162-163（2007年）。

527 詳細之分析內容可參考吳全峰（註6），頁672-674。

528 BRIGIT TOEBES, THE RIGHT TO HEALTH AS A HUMAN RIGHT IN INTERNATIONAL LAW 245-46, 272 (1999).

主張滿足個人實現其自主能力之藥物應具優先地位之「自主權保障模式」(autonomy approach)⁵²⁹、建議將特定健康人權內涵（如與生育有關之藥物、與嬰幼兒保健有關之藥物、主要傳染病之疫苗、WHO 基本藥物清單所列之藥物）⁵³⁰列為「核心義務」之「健康人權規範內容模式」(contents of the right to health approach)⁵³¹。但本文認為藥物近用權利之核心內涵應回歸機會平等之社會結構觀，侷限於與基本健康標準之維持具有直接關聯性者始屬之⁵³²（Amartya Sen⁵³³及 Martha Nussbaum⁵³⁴亦主張一定程度之健康應被視為個人之基本能力並受到社會保障）；亦即若藥物之使用能治療或緩解嚴重限制個人平等機會使其無法達到正常競爭門檻之疾病，則該藥物便應被視為藥物近用權利之核心內涵⁵³⁵。而基本健康之內涵，

529 ALASTAIR CAMPBELL, *MEDICINE, HEALTH AND JUSTICE: THE PROBLEM OF PRIORITIES* 48 (1978).

530 See, e.g., Paragraphs 43-45 of the CESCR General Comment No. 14. International Conference on Primary Health Care, *Declaration of Alma-Ata* arts. 6-7 (1978). WHO, *GLOBAL STRATEGY FOR HEALTH FOR ALL BY THE YEAR 2000*, 31-38 (1989). WHO, *PRIMARY HEALTH CARE* 34-50 (1948).

531 TOEBES, *supra* note 528, at 275-76.

532 吳全峰，健康照護資源分配之界線——兼論醫療科技發展下健康照護資源分配之變與不變，收於：邱文聰編，2009科技發展與法律規範雙年刊——科學管制、學術研究自由與多元民主價值，頁326-42（2010年）。吳全峰（註6），頁677。

533 SEN, *supra* note 82, at 87-110. Amartya Sen, *Human Rights and Development*, in *DEVELOPMENT AS A HUMAN RIGHT* 1, 1-8 (Bard Andreassen & Stephen Marks eds., 2006).

534 Martha Nussbaum, *Capabilities and Human Rights*, in *THE PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS: READINGS IN CONTEXT* 212, 212-40 (Patrick Hayden ed., 2001).

535 需特別說明者為，並非僅與生命權密切相關之藥物近用權利始屬 *jus cogens* 之保障範圍。蓋（1）依 CESCR General Comment No.14第47段之規定，包括預防接種請求權、孕婦及兒童之藥物近用權、基本藥物請求權、緊急醫療藥物請求權，均屬健康人權之核心價值而具不可減損之特性，加上（2）相關權利之核心地位亦已因列入 General Comment 而被國際社會廣泛接受承認，且（3）其變動亦須具備一定之門檻條件始符合其不許損抑之優先價值；因此，預防接種請求權、孕婦及兒童之藥物近用權、基本藥物請求權、緊急醫療藥物請求權均應被視為具 *jus cogens* 之內涵（請參考第五、二、（二）節之說明）。而其中基本藥物之判斷標準，本文建議應以該藥物之近用是否與基本健康(minimal health)之維持有關作判斷，以免基本藥物之範圍過於空泛；而基本

Martha Nussbaum 主張應包括生命之維持(life)、生理健康(bodily health)、身體之完整性(bodily integrity)、感官、想像和思考(senses, imagination, and thought)等⁵³⁶，但其內容仍過於空泛而無法明確地區分不同藥物之重要性；John Rawls 及 Norman Daniels 則主張，因擁有最低限度道德能力(moral powers)者——即擁有善觀念(conception of the good)之能力與擁有正義感(sense of justice)之能力者——始有能力從事社會合作並作為自由且平等的公民參與社會生活⁵³⁷，故僅具備與個人維持道德能力有關之藥物使能被視為藥物近用權利之核心內涵。蓋依 Rawls 之理論：因（1）社會之平等基礎就是須保障個人對於由各種理性生活計畫之終極目標(final ends of rational life plans)所組成具有優先條序之族系，擁有形成、修正、實踐(to have, to revise, and to pursue)之能力；以及保障個人對於構成社會合作基本架構之政治正義原則，擁有理解、應用和踐行(to understand, to apply, and to act)之能力，使個人能夠充分參與社會合作之生活（此即平等機會原則之意涵）⁵³⁸；（2）而社會之自由基礎則建立在社會能保障個人有能力在合理與理性之基礎上修正與改善善觀念之能力（此即自由原則之內涵）⁵³⁹。因此，民眾若因經濟因素而無法近用某項藥物，其所導致之殘疾將使個人在面對既有（但

健康之判斷標準，則可以本段內文所提 Rawls, Daniels, Sen 及 Nussbaum 之理論作為參考。

536 Martha Nussbaum, *Capabilities, Human Rights, and the Universal Declaration*, in THE FUTURE OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 25, 44-45 (Burns Weston & Stephen Marks eds., 1999).

537 RAWLS, *supra* note 503, at 20. DANIELS, *supra* note 523, at 18-19.

538 所謂平等原則係指社會與經濟不平等應該這樣安排：（1）符合地位最不利者(the most disadvantaged)之最大好處（差異原則，the difference principle）；（2）在機會的公平平等的條件下，附屬於職務與地位而向所有的人開放（平等機會原則，the fair equality of opportunity principle）。RAWLS, *supra* note 525, at 266-67.

539 所謂自由原則(the liberty principle)係指每個人都擁有平等權利，要求一個最廣泛的、平等的基本自由權的總體系，這個體系與人人享有類似的自由權體系完全相容。*Id.*

需些微修正以符合個人價值觀)之生活秩序與價值時,缺乏適當能力把善觀念轉變為自己內在之價值亦喪失追求其獨特生活目標之手段時,其追求理想生活目標之正常機會範圍亦將因此受到實質限縮⁵⁴⁰;此時作為社會成員之跨國製藥企業自應依循社會所承認之分配原理,負擔起滿足該特定藥物近用權利之保障,以協助落入基本健康以下之成員恢復其基本能力⁵⁴¹。

但從前述分析不難發現,在賦予跨國製藥企業法律義務以滿足如基本藥物近用權利之保障時,既有基本藥物清單之定義——以有效性與安全性(efficacy and safety)、相對成本效益(relative cost-effectiveness)、品質(adequate quality)、公共衛生相關性(如社經環境、疾病分佈、藥廠之設備與庫存)等為基本藥物之判斷標準⁵⁴²——亦須作全面檢討與限縮。蓋現有基本藥物之定義與前述藥物近用權利核心價值之內涵實有差距,其涵括之範圍與以基本能力行使為基礎之基本健康(如與生命維持直接相關之生理或心理功能,或與日常基本生活之運作(daily living activities)密切相關之生理或心理功能)⁵⁴³亦不相當;因此,為使賦予跨國製藥企業時健藥物近用權利核心價值之法律義務具有正當性,藥物近用權利核心價值之界定(如基本藥物之定義)便有進一步釐清之必要。

需要釐清的另一點是跨國製藥企業實踐藥物近用權利核心價值之人權責任強度:(1)就藥物近用權利核心價值之實踐而言,因其屬國際絕對法之範疇,故國家應負擔具法律強制力立即實踐之「必

540 JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISM 313 (1993).

541 吳全峰(註532),頁347。

542 另一標準為,基本藥物通常為單一化合物(single compound),固定量複合劑(fixed dose combination products)須為緊急狀態(如瘧疾、肺結核、AIDS)始得列為基本藥物。WHO, The Selection of Essential Medicines, WHO Policy Perspectives on Medicine No. 4, WHO Doc. WHO/EDM/2000.4, available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.2.pdf (last modified on Oct. 15, 2009).

543 吳全峰(註6),頁678-679。

要義務」而非漸進滿足之「應為義務」⁵⁴⁴；但並不代表跨國製藥企業亦需負擔「必要義務」，因要求跨國製藥企業負擔與國家相同強度之人權責任不僅不合理亦不切實際⁵⁴⁵，亦將混淆兩者之功能與角色⁵⁴⁶。(2) 但本文亦不認為跨國製藥企業僅需負擔僅具軟性道德規範之社會責任或自願性慈善行為之「得為義務」⁵⁴⁷；就與基本健康相關之藥物近用權利（如近用基本藥物或 ARVs），跨國製藥企業仍須負擔「應為義務」^{548、549}，且除非其證明實踐藥物近用權利之核心價值將嚴重減損其商業利益或股東權益，否則不應豁免跨國製藥企業相關人權責任。換言之，本文主張不宜不附理由逕將跨國製藥企業實踐藥物近用權利核心價值之人權責任視為「得為義務」，而應在個案判斷之基礎上(case-by-case base)，由跨國製藥企業負擔舉證責任(burden of proof)證明其實踐該人權責任是否可能超出合理可利用之資源範圍；若是，始有免除「應為義務」之可能性。Leisinger 似乎亦同意本文主張，因在其所提架構中（見第伍、二、（二）節）雖然認為跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任主要落入「得為義務」之範疇，但其亦承認不同藥物對健康人權影響之程度應做個案之判斷，因此主張製藥企業就與生命相關之藥物(life-saving drugs)與疫苗應負擔較嚴格之「應為義務」⁵⁵⁰。而在本

544 吳全峰（註532），頁326-342。吳全峰（註6），頁677。

545 Cristina Baez et al., *Multinational Enterprises and Human Rights*, 8 U. MIAMI INT'L & COMP. L. REV. 183, 223 (2000).

546 Ratner, *supra* note 279, at 493. Glen Kelley, *Multilateral Investment Treaties: A Balanced Approach to Multinational Corporations*, 39 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 483, 524 (2001).

547 Wu, *supra* note 19, at 119, 121.

548 *Id.* at 118-19, 120-21.

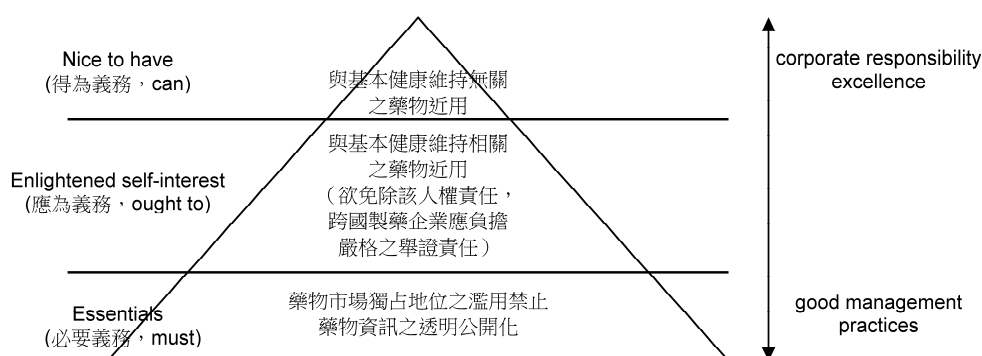
549 簡言之，若藥物之作用係維持或恢復與生命維持直接相關之生理或心理功能，或是恢復或維持與日常基本生活之運作密切相關之生理或心理功能時，該藥物便與個人作為社會自由理性成員所應具備之基本能力有密切關連性，故對該藥物之近用便應被視為藥物近用權利之核心價值；也因此，跨國製藥企業對於此類藥物之近用便應在「應為義務」之範圍內負擔人權責任。See more discussions in Wu, *supra* note 19, at 122-27.

550 Leisinger, *supra* note 18, at 13.

文之架構下，跨國製藥企業便不能任意藉由杯葛（受 TRIPS 協定所保障）權利金補償額度而質疑強制授權正當性（詳見第肆、三節），或在拒絕提供研發成本相關資訊之前提下維持不合理藥物價格（如南非 FTC 在 *Hazel Tau v. GlaxoSmithKline, Boehringer* 乙案中所批評者，詳見第肆、三節），而須證明其反對強制授權、平行輸入、藥價折扣等措施係具有正當理由。⁽³⁾ 至於就與基本健康無關之其他藥物，跨國製藥企業僅需負擔「得為義務」以滿足其近用即可。

就跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任架構，請參見下圖三⁵⁵¹：

圖三 跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任架構⁵⁵²



⁵⁵¹ 但需要說明者為，跨國製藥企業所應負擔之人權責任並非絕對義務；蓋目前國際人權法規對於國家保障藥物近用權利之義務，僅限於漸進滿足該權利之充分實現即可，若要求跨國製藥企業負擔較國家更為嚴格之義務，並不合理。換言之，依漸進滿足之原則，跨國製藥企業若可證明實踐藥物近用權利之人權責任，將嚴重損及其進行正常之商業行為與合理利潤，則其人權責任便應有所限縮。

⁵⁵² 本架構係參考學者所提出之 Modified Hierarchy of Pharmaceutical Corporations' Responsibilities 模型，並作些微調整修正後完成。Wu, *supra* note 19, at 120.

二、跨國製藥企業之人權責任定位

另須注意者為，確立跨國製藥企業對藥物近用權利保障之人權責任，並非表示國家便可從其人權責任中逸脫⁵⁵³，兩者間應建立一種獨立卻又互補之關係。

首先，因國家仍屬人權責任之主要負擔者，故當國家仍具適當資源以滿足民眾藥物近用權利之保障時，則跨國製藥企業之角色便仍應侷限於以營利為目的之私人企業，其是否願意負擔社會責任（而非人權責任）協助國家則屬自願之慈善行為⁵⁵⁴；但當國家無法保障民眾之藥物近用權利時（此時國家需依據 CESCR General Comment No. 14第47段證明其已盡一切努力而仍無能力，而非不願意，滿足其人權義務）⁵⁵⁵，則跨國製藥企業便應負擔人權責任，以填補以國家為中心之國際人權典範無法適當執行之落差⁵⁵⁶。換言之，在目前國際人權典範之架構下，仍應以國家保障藥物近用之人權義務為主，而跨國製藥企業之人權責任為輔，且不應以後者取代前者，以避免國家迴避其應盡之人權義務⁵⁵⁷。因此，跨國製藥企業

553 VILJAM ENGSTRÖM, WHO IS RESPONSIBLE FOR CORPORATE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS? 9 (2002), available at <http://web.abo.fi/institut/imr/norfa/ville.pdf> (last visited Nov. 7, 2012).

554 Peter T. Muchlinski, *Human Rights and Multinationals: Is There a Problem?*, 77 INT'L AFF. 31, 44-46 (2001). GEORGE KELL, CORPORATE CITIZENSHIP: EXPLORING THE NEW RESPONSIBILITIES 24 (2002).

555 Paragraph 47 of the CESCR General Comment No. 14, "In determining which actions or omissions amount to a violation of the right to health, it is important to distinguish the inability from the unwillingness of a State party to comply with its obligations under article 12. ... If resource constraints render it impossible for a State to comply fully with its Covenant obligations, it has the burden of justifying that every effort has nevertheless been made to use all available resources at its disposal in order to satisfy, as a matter of priority, the obligations outlined above. It should be stressed, however, that a State party cannot, under any circumstances whatsoever, justify its non-compliance with the core obligations set out in paragraph 43 above, which are non-derogable."

556 李貴英、曾恕真（註431），頁28。

557 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS, *supra* note 161, at 57.

雖需負擔獨立之人權責任以保障藥物近用權利，但其優先性與強度仍應較國家之人權義務為輕——如國家對於與基本健康維持相關之藥物近用，應負擔必要義務⁵⁵⁸；但跨國製藥企業僅需負擔應為義務——以避免造成兩者在人權保障上之角色混淆，並對企業形成過於沉重之負擔⁵⁵⁹。

其次，國家應負擔間接責任(indirect obligations)，確保跨國製藥企業善盡其人權責任並保障藥物近用權利。詳言之，跨國製藥企業雖然亦可能間接地或直接地參與國際事務，但對相關私法行為之拘束與治理，在尊重各國主權(sovcreignty)行使之前提下，通常仍以國內法規為法源依據⁵⁶⁰；亦即由國家依據其所簽訂並受拘束之國際人權法規與精神，於內國法中訂定對個人及企業人權責任之規範（此及國際人權法之內國法化）。然而，從表面上觀察，國家雖然仍為人權保障義務之主體(human rights obligations on states)，在國際人權法之要求下負擔義務制定相關人權標準，以管制並確保其國民與企業之私法行為不致違反國際人權法之規範；但國際人權典範在內國法之落實，其實亦暗示國家應負擔間接責任確保跨國製藥企業落實藥物近用權利之保障⁵⁶¹。尤其 CESCR General Comment

558 本文在第五、二、(二)節中已說明，依 CESCR General Comment No.14第47段規定，第43段之核心義務（包括對特定藥物之近用）應視為不可減損之健康人權核心價值，而屬應優先被滿足之健康人權義務。

559 如可減少跨國製藥企業因推行藥物近用保障之人權責任所帶來之期待不確定性。葉保強，企業社會責任的發展與國家角色，應用倫理研究通訊，41期，頁38（2007年）。李貴英、曾恕真（註431），頁9。

560 陳彥君（註184），頁5。

561 但國家（包括母國與地主國）應如何要求跨國製藥企業負擔人權責任，目前仍未有定論；而本文限於篇幅，亦無法對此議題進行深入討論。但目前實務多以軟措施來約制跨國製藥企業，包括以同儕壓力(peer pressure)或公眾意見(public opinions)、非政府組織監控等方式，刺激其改變商業行為以達到實踐人權責任之目標；如跨國製藥企業針對南非強制授權政策所提起之訴訟，便在國際組織（如歐洲議會）及非政府組織之壓力下，撤回訴訟。另亦有學者提出以包括貿易制裁／貿易優惠、民事責任（如美國之外國人侵權行為損害賠償法(Alien Tort Claims Act)）、國際準則（包括建立跨國企業之人權績效報告、認證標章、資訊揭露等標準之建立）等方式，促使跨國企業（包括跨國製藥

No.14第51段中強調，若是國家未能採取一切必要措施保護其管轄權內民眾之健康人權不受到第三方（包括跨國製藥企業）之侵犯，則將違反其受 ICESCR 第12條所規範之健康人權保障義務。因此，除跨國製藥企業之直接健康人權責任外，在執行層面亦應考慮國家監督跨國製藥企業實踐前述藥物近用權利保障責任之角色；換言之，包括母國及地主國，均應以嚴密之法律規範，削弱跨國製藥企業侵害藥物近用權利之成本誘因，並同時建立適當之法律規範，詳列跨國製藥企業不應濫用市場獨占地位之商業行為態樣，強制跨國製藥企業揭露藥物、遊說、行銷等相關資訊，並建立健康人權影響評估機制(the right to health impact assessment)協助評估跨國製藥企業是否適當滿足與基本健康相關之藥物近用權利。另，國家亦應建立適當之申訴或訴訟管道，以進一步強化民眾在其藥物近用權利受跨國製藥企業侵害或限制時，得以主張權利並對抗跨國製藥企業之路徑。

柒、未來展望

在國際藥物智慧財產權與藥物近用權利之衝突中，單靠 TRIPS 協定之調和機制或國家之人權保障義務，並不足以確保與民眾生命密切相關之藥物近用權利核心內涵；因此，跨國製藥企業在跨國貿易日趨頻繁之全球化趨勢下，憑藉其豐厚之經濟實力，在此議題上之所應扮演角色便更加突顯。因在藥物智慧財產權與健康人權之衝突中，固然跨國製藥企業之合理利潤、研發與生產之適當經濟誘因有其重要性；但若要使 TRIPS 協定所欲維護之國際貿易自由化與經濟發展目標能夠達成，民眾近用藥物（尤其是基本藥物）之利益

企業）遵守人權責任。陳彥君（註184），頁72-137。林彩瑜（註209），頁25。

亦不可偏廢，因忽視藥物近用權利所造成之經濟負面影響並不會僅留在發展中國家（包括消費力之減弱、人力資源之喪失等），最終仍將影響整體國際社會之經濟可發展性。在此概念架構下，作為彌補國際健康不平等之重要一環，跨國製藥企業保障藥物近用權利之人權責任之發展應有其重要性。而在企業與人權之相關討論仍屬萌芽階段，本文並不激進地嘗試要求跨國製藥企業對「所有」藥物之近用權利保障均應負擔強制之法律責任（應為義務）；但對於目前僅要求跨國製藥企業針對多樣化之藥物近用權利內涵負擔一致而無區別性之道德性、自願性之社會責任（得為義務），本文認為並非完全沒有討論之空間。換言之，本文對於跨國製藥企業所應負擔之藥物近用人權責任採多層次之分析架構，並主張該責任之強度應視藥物近用權利之多元內涵做出不同之判斷——對於與基本健康維持無關之藥物近用，跨國製藥企業雖僅需負擔較低度之「得為」責任即可；但對於與基本健康維持密切相關之藥物近用，卻應進一步負擔「應為」之直接人權責任，並落實至相關藥價決策。另，本文亦嘗試從跨國製藥企業之人權責任為主軸，進一步分析包括藥物市場獨占地位濫用禁止、藥物資訊透明公開、藥物近用權利核心內涵保障等義務對於藥物近用權利保障之重要性，以及其具體內涵，以補足目前藥物近用權利在跨國藥物智慧財產權體系下，所可能出現之人權保障間隙。

然而因管制跨國製藥企業之相關理論基礎發展仍不完全成熟，因此如聯合國人權委員會所暫擬之 *Guidelines for Pharmaceutical Companies* 亦僅具建議性質，其內涵尚屬空泛，如何落實執行亦有很大之討論空間；且國際法上對於是否得直接將跨國製藥企業作為人權責任主體（尤其針對屬受益權部分之藥物近用權利）仍有爭論。類似之爭論對於跨國製藥企業就藥物近用權利所應負擔之人權責任範圍便將產生影響。故本文雖然肯認跨國製藥企業就藥物近用權利之核心內涵應具有直接之人權責任（應為義務），但其內容之

細緻化——包括藥物近用權利內涵之細緻化、跨國製藥企業義務之分類與落實——仍有待未來更深入之研究⁵⁶²。

562 值得注意的是，Thomas Pogge 針對全球性普遍面對之藥物近用問題，建議採取健康影響力基金（Health Impact Fund，以下簡稱 HIF）之方式解決。簡言之，製藥企業於 HIF 註冊其生產之藥物並承諾以指定低價販售後，HIF 會比較以下兩者之健康狀況——（1）使用註冊藥物者之實際健康狀態，與（2）未曾使用該註冊藥物者，或是使用該藥物註冊前兩年內之其他藥物者——當成健康影響指標（亦即註冊藥物之健康影響力），以決定製藥企業獲得之報酬，並由支持 HIF 之國家所提供之資金中提撥酬勞，作為基本藥物之運作及新藥發展所需之資源。Pogge 主張，HIF 之設計可提高製藥企業以病人之健康照護需要（而非其經濟能力）作為研究發展目標之動機；且藉由同意支持之國家與製藥企業之增加，可降低製藥企業在研發或銷售中所面臨之利潤不確定風險。但不可諱言，HIF 之建立通常被視為藥物近用權利保障之一項工具，其運作與跨國製藥企業人權責任之建立並不必然產生衝突；尤其 IHF 之建立仍以道德吸引力作為基礎，而所謂「道德吸引力」便與本文所強調之人權責任若合符節。但因 IHF 架構之理論基礎，除本文所採之人權典範外，尚包括國際正義、普世主義、經濟學理論等，若欲對 IHF 進行完整之介紹與討論，並與本文所架構之跨國製藥企業人權責任進行比較，實非本文之篇幅所能完成，故僅能留作日後再進行深入之分析。有關 IHF 之相關討論請參考 AIDAN HOLLIS & THOMAS POGGE, *THE HEALTH IMPACT FUND: MAKING NEW MEDICINES ACCESSIBLE FOR ALL. A REPORT OF INCENTIVES FOR GLOBAL HEALTH* 3-11 (2008). Thomas Pogge, *The Health Impact Fund and Its Justification by Appeal to Human Rights*, 40(4) J. SOC. PHIL. 542, 542-69 (2009). Amitava Banerjee, Aidan Hollis, & Thomas Pogge, *The Health Impact Fund: Incentives for Improving Access to Medicines*, 375 LANCET 166, 166-69 (2010).

參考文獻

1. 中文部分

- Jack Donnelly 著，江素慧譯（2007），普世人權——理論與實踐，台北：巨流。[Donnelly, Jack. 2002. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 2d ed. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.]
- Jeffery D. Sachs 著，鐵人庸譯（2007），終結貧窮——如何在我們有生之年做到？，台北：臉譜。[Sachs, Jeffery D. 2006. *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. London: Penguin Books.]
- Marcia Angell 著，曾育慧譯（2006），藥廠黑幕：製藥公司如何掏空你的錢包和健康？，台北：商周。[Angell, Marcia. 2005. *The Truth about the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do about It*. New York, N.Y.: Random House.]
- Paul Gordon Lauren 著，徐子婷、司馬學文、楊雅婷譯（2008），國際人權的進展，台北：韋伯。[Lauren, Paul Gordon. 2003. *The Evolution of International Human Rights*. 2d ed. Philadelphia, Penn.: University of Pennsylvania Press.]
- 牛惠之（2006），淺論認定國家緊急狀況與強制授權克流感的正當性與必要性，台灣本土法學雜誌，79期，頁4-12。
- （2007），從WTO自由貿易論「杜哈TRIPS協定與公共衛生宣言」對「國家緊急危難或其他緊急狀況」的解釋與潛在爭議——兼論預防原則的運用，第七屆國際經貿法發展學術研討會，國立政治大學國際經貿組國際法律研究中心主辦，載於 <http://mx.nthu.edu.tw/~hcnui/paper/200804.pdf>。
- 丘宏達（2006），現代國際法，修訂2版，台北：三民。
- 朱懷祖（2006），新藥科技與智慧財產權保護，收於：朱懷祖、梁

啟銘、孔繁璐編，藥物科技發展與智財權保護：藥事法第四十條之一、之二修法論文集，頁2-56，台北：中華景康藥學基金會。

吳全峰（2010），健康照護資源分配之界線——兼論醫療科技發展下健康照護資源分配之變與不變，收於：邱文聰編，2009科技發展與法律規範雙年刊：科學管制、學術研究自由與多元民主價值，頁299-367，台北：中央研究院法律學研究所籌備處。

——（2011），健康人權發展困境之初探，中央研究院週報，1348期，頁10-13。

——（2011），從健康人權之角度論國際藥品智慧財產權制度之發展，收於：洪德欽編，歐盟與美國生物科技政策，頁581-693，台北：中央研究院歐美研究所。

吳全峰、黃文鴻（2007），論醫療人權之發展與權利體系，月旦法學雜誌，148期，頁128-161。

吳錦龍（2006），變動中的 *Jus Cogens* ——緣起、發展與定型（上），台灣國際法季刊，3卷2期，頁167-247。

李素華（2006），從公共衛生之觀點論醫藥專利權之保護與限制，臺灣大學法律學研究所博士論文。

李貴英、曾恕真（2011），跨國企業投資行為之規範——企業社會責任之研究，法制論叢，47期，頁1-42。

林宜男、許佳惠（2005），WTO 醫藥專利與公共健康議題之研析——兼論我國未來之發展趨勢，清華科技法律與政策論叢，2卷1期，頁205-257。

林彩瑜（2004），WTO TRIPS 協定下醫藥專利與公共健康之問題及其解決方向，政大法學評論，78期，頁267-342。

——（2009），貿易與公共衛生之法律問題——世界貿易組織法律研究（二），台北：元照。

林萬億、周淑美（2004），全球化與人類福利，台北：五南。

姜皇池（2004），國際公法：第三講——國際法源（上），月旦法學

- 教室，22期，頁122-135。
- （2008），國際公法導論，2版，台北：新學林。
- 倪貴榮（2003），WTO 智慧財產權保護與公共健康議題之發展趨勢，經社法制論叢，31期，頁129-158。
- 徐遵慈（2006），貿易與人權——WTO 的難題與挑戰，經濟前瞻，105期，頁88-92。
- 張文貞（2010），國際人權法與內國憲法的匯流——台灣施行兩大人權公約之後，收於：台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁1-26，台北：元照。
- 張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏（2000），經濟學——理論與實際（上冊），4版，台北：翰蘆。
- 陳文吟（2002），探討因應醫藥品專利之合理措施，中正法學集刊，8期，頁67-112。
- 陳宜超（2005），生技醫藥公司之投資評估研究——生物倫理與社會責任之價值，國立政治大學科技管理研究所碩士論文。
- 陳俊仁（2008），公司社會責任之國際法實踐——論跨國企業監理套利規範之演繹與規範困境，中華國際法與超國界法評論，4卷2期，頁417-476。
- 陳彥君（2009），跨國公司與國際勞動人權保障——管制類型的觀點，臺灣大學法律學系碩士論文。
- 陳美利（2005），專利制度與公共衛生需求之調和——以醫藥品專利相關制度之發展為核心，東吳大學法學院法律學系碩士論文。
- 曾淑瑜（2010），醫療倫理與法律15講，台北：元照。
- 黃文鴻、吳全峰（2007），藥品許可證與專利權資訊扣合機制之研究，行政院衛生署九十六年度委託科技研究計畫 DOH96-TD-D-113-024。
- 黃佳晴（2005），社會傾銷之研究——經濟全球化下的貿易策略與國際分工，銘傳大學國際事務研究所碩士論文。

黃慧嫻（2006），淺析美國藥品上市審查程序之專利連結機制及其實施對我國可能產生之影響（上），科技法律透析，18卷6期，頁2-7。

——（2009），專利連結(Patent Linkage)——藥品研發與競爭之阻力或助力？談藥品查驗登記程序與專利權利狀態連結之發展（上），科技法律透析，21卷2期，頁24-37。

——（2008），處方藥產業的法律戰爭——藥品試驗資料之保護，台北：元照。

楊智傑（2008），如何解決藥物近用落差與研發落差？——TRIPS下各種解決方案與大學專利政策之檢討，台灣科技法律與政策論叢，5卷2期，頁69-125。

葉保強（2007），企業社會責任的發展與國家角色，應用倫理研究通訊，41期，頁35-47。

劉超（2007），論國際貿易中的人權問題，南京財經大學學報，148期，頁79-82。

鄭慧文、余萬能、林鴻柱（2011），藥品新適應症資料專屬權適法性之探討，醫事法學，18卷1期，頁33-43。

賴英照（2007），從尤努斯到巴菲特——公司社會責任的基本問題，台灣本土法學雜誌，93期，頁150-180。

謝季峰（2003），WTO 智慧財產權規範與藥品可近性的研究——探討藥物專利保護政策與公共衛生的平衡點，國立陽明大學衛生福利研究所碩士論文。

謝啟瑞（1997），健康經濟學，台北：五南。

謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南（2000），專利法解讀，台北：元照。

羅昌發（1996），WTO 下之智慧財產權保護與貿易自由化之關係，收於：GATT/WTO 與我國貿易——國際經貿法研究（四），頁127-166，台北：永然。

——（2010），國際貿易法，2版，台北：元照。

2. 外文部分

- Aaronson, Susan Ariel, and Jamie M. Zimmerman. 2008. *Trade Imbalance: The Struggle to Weigh Human Rights Concerns in Trade Policymaking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Abbott, Frederick M. 2007. The Doha Round's Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines under the Amended TRIPS Provisions. *Journal of International Economic Law* 10:921-987.
- Abbott, Frederick M., and Graham Dukes. 2009. *Global Pharmaceutical Policy: Ensuring Medicines for Tomorrow's World*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Addo, Michael K. 1999. The Corporation as a Victim of Human Rights Violations. Pp. 187-196 in *Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations*, edited by Michael K. Addo. Boston: Kluwer Law International.
- Alexander, Barbara Cochrane. 2001. Lack of Access to HIV/AIDS Drugs in Developing Countries: Is There a Violation of the International Human Right to Health?. *Human Rights Brief* 8(3):12. Available at <http://www.wcl.american.edu/hrbrief/08/3aids.cfm>.
- Alvare, Jose E. z. 2001. How Not to Link: Institutional Conundrums on an Expanded Trade Regime. *Widener Law Symposium Journal* 7:1-19.
- Attaran, Amir. 2004. How Do Patents and Economic Policies Affect Access to Essential Medicines in Developing Countries?. *Health Affairs* 23(3):155-166.
- Attaran, Amir, and Lee Gillespie-White. 2001. Do Patents for Antiretroviral Drugs Constrain Access to AIDS Treatment in Africa?. *Journal of the American Medical Association*

286(15):1886-1892.

- Baez, Cristina, Michele Dearing, Margaret Delatour, and Christine Dixon. 2000. Multinational Enterprises and Human Rights. *University of Miami International & Comparative Law Review* 8:183-338.
- Baker, Brook K. 2008. Ending Drug Registration Apartheid: Taming Data Exclusivity and Patent/Registration Linkage. *American Journal of Law & Medicine* 34(2&3):303-344.
- Banerjee, Amitava, Aidan Hollis, and Thomas Pogge. 2010. The Health Impact Fund: Incentives for Improving Access to Medicines. *The Lancet* 375:166-169.
- Barbour, Virginia, Jocalyn Clark, Susan Jones, and Emma Veitch. 2010. Drug Companies Should Be Held More Accountable for Their Human Rights Responsibilities. *Plos Medicine* 7(9): e1000344. Available at <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000344>.
- Bartels, Lorand. 2002. Article XX of GATT and the Problem of Extraterritorial Jurisdiction: The Case of Trade Measures for the Protection of Human Rights. *Journal of World Trade* 36:353-403.
- Beutz, Molly. 2009. Protecting Rights Online. *Yale Journal of International Law* 34:1-41.
- Bollyky, Thomas. 2011. *Safer, Faster, Cheaper: Improving Clinical Trials and Regulatory Pathways to Fight Neglected Diseases: Report of the Center for Global Development's Working Group on Clinical Trials and Regulatory Pathways*. Washington, D.C.: Center for Global Development.
- Bombach, Kara M. 2001. Can South Africa Fight AIDS? Reconciling the South African Medicines and Related Substances Act with the TRIPS Agreement. *Boston University International Law Journal*

19:273-306.

- Broecker, Christen. 2008. "Better the Devil You Know": Home State Approach to Transnational Corporate Accountability. *New York University Journal of International Law & Policy* 41:159-217.
- Buchanan, Allen, Dan W. Brock, Norman Daniels, and Daniel Wikler. 2000. *From Chance to Choice: Genetics and Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buckley, Marianne. 2011. Looking Inward: Regional Parallel Trade as a Means of Bringing Affordable Drugs to Africa. *Seton Hall Law Review* 41:625-669.
- Campbell, Alastair. 1978. *Medicine, Justice and Health: The problem of priorities*. Edinburgh: Churchill Livingstone.
- Carrol, Archie B., and Ann K. Buchholtz. 2002. *Business – Ethics and Stakeholder Management*. Mason: South-Western College publishing.
- Chandler, Geoffery. 2003. The Evolution of the Business and Human Rights Debate. Pp. 22-32 in *Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions*, edited by Rory Sullivan. Sheffield: Greenleaf.
- Clapham, Andrew. 1996. *Human Rights in the Private Sphere*. Oxford: Clarendon Press.
- Cooper, William H., and Mark E. Manyin. 2006. The Proposed South Korea-U. S. Free Trade Agreement, CRS Report for Congress. Available at: http://www.sice.oas.org/TPD/USA_KOR/Studies/CRSREPORT_e.pdf.
- Correa, Carlos M. 2006. Implications of Bilateral Free Trade Agreements on Access to Medicines. *Bulletin of the World Health Organization* 84(5):397-424.
- Crow, M. E. 2005. The Human Rights Responsibilities of Multinational Tobacco Companies. *Tobacco Control* 14: ii14-ii18.

- Damrosch, Lori Fisler, Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter, and Hans smit. 2001. *International Law: Cases and Materials*. St. Paul, Minn.: West Group.
- Daniels, Norman. 1995. *Just Health Care*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Department for International Development. Increasing Access to Essential Medicines in the Developing World. Available at <http://www.cepis.org.pe/bvsacd/milenio/sidadfid.pdf>.
- DeRoo, Pier. 2011. "Public Non-Commercial Use" Compulsory Licensing for Pharmaceutical Drugs in Government Health Care Programs. *Michigan Journal of International Law* 32:347-394.
- Dresler, Carolyn, and Stephen P. Marks. 2006. The Emerging Human Rights to Tobacco Control. *Human Rights Quarterly* 28(3):599-651.
- Drotleff, Erich Andreas. 2006. The Medicare Part D Prescription Drug Benefit: Who Wins and Who Loses?. *Marquette Elder's Advisor* 8:127-157.
- Editorial. 2001. Brazil Fights for Affordable Drugs against HIV/AIDS. *Revista Panamericana de Salud Pública* 9(5):331-337. Available at <http://www.paho.org/english/dbi/es/v9n5-tema-brazil.pdf>.
- Elkington, J. 2006. The Triple Bottom Line. Pp. 97-129 in *The Accountable Corporation*, edited by Marc J. Epstein and Kirk O. Hanson. Santa Barbara, C.A.: Praeger Publishers.
- Engström, Viljam. 2002. Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations?. Available at <http://web.abo.fi/instut/imr/norfa/ville.pdf>.
- Eyal, Nir, and Samia A. Hurst. 2008. Physician Brain Drain: Can Nothing Be Done?. *Public Health Ethics* 1(2):180-192.
- Fatouros, Arghyios A. 1981. On the Implementation of International Codes of Conduct: An Analysis of Future Experience. *American*

- University Law Review* 30:941-972.
- Feldman, Jamie. 2009. Compulsory Licenses: The Dangers Behind the Current Practice. *Journal of International Business & Law* 8:137-167.
- Ferreira, Lissett. 2002. Access to Affordable HIV/AIDS Drugs: The Human Rights Obligations of Multinational Pharmaceutical Corporations. *Fordham Law Review* 71(3):1133-1179.
- Fisher, William W., and Talha Syed. 2007. Global Justice in Healthcare: Developing Drugs for the Developing World. *U.C. Davis Law Review* 40:581-678.
- Ford, Nathan. 2004. Patents, Access to Medicines and the Role of Non-Governmental Organisations. *Journal of Generic Medicines* 2(1):137-145.
- Galantucci, Robert. 2007. Data Protection in a U.S.-Malaysia Trade Agreement: New Barriers to Market Access for Generic Drug Manufacturers. *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 17:1083-1123.
- Gallagher, Katherine. 2010. Civil Litigation and Transnational Business an Alien Tort Statute Primer. *Journal of International Criminal Justice* 8:745-767.
- Gathii, Ames Thuo. 2005. Third World Perspectives on Global Pharmaceutical Access. Pp. 336-351 in *Ethics and the Pharmaceutical Industry*, edited by Michael A. Santoro and Thomas M. Gorrie. Newark, N.J.: Rutgers University.
- . 2005. International Justice and the Trading Regime. *Emory International Law Review* 19:1407-1430.
- Griffin, John P., and John O'grady. 2002. *The Textbook of Pharmaceutical Medicine*. Oxford: Blackwell.
- Gunn, Patricia C. 2009. Health Care Refugee. *Loyola University of*

Chicago International Law Review 6:339-365.

- Gunnar, William P. 2006. The Fundamental Law That Shapes the United States Health Care System: Is Universal Health Care Realistic Within the Established Paradigm?. *Annals Health Law* 15:151-181.
- Gupta, Vishal. 2005. A Mathematical Approach to Benefit-Detriment Analysis as a Solution to Compulsory Licensing of Pharmaceuticals under the Trips Agreement. *Cardozo Journal of International & Comparative Law* 13:631-660.
- Heiskanen, Veijo A. 2004. The Regulatory Philosophy of International Trade Law. *Journal of World Trade* 38:1-36.
- Henkin, Louis. 1995. *International Law: Politics and Values*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Hestermeyer, Holger P. 2004. Access to Medication as a Human Right. *Max Planck Year Book of United Nation Law* 8(1):101-180.
- Hoen, Ellen't. 2002. TRIPS, Pharmaceutical Patents, and Access to Essential Medicines: A Long Way from Seattle to Doha. *Chicago Journal of International Law* 3:27-46.
- Hollis, Aidan, and Thomas Pogge. 2008. The Health Impact Fund: Making New Medicines Accessible for All. A Report of Incentives for Global Health. Available at http://www.who.int/pmnch/topics/economics/20100505_medicinesaccessible/en/index.html.
- Howse, Robert. 2002. Human Rights in the WTO: Whose Rights, What Humanity? Comments on Petersman. *European Journal of International Law* 13:651-659.
- Human Rights Watch. 2006. "Race to the Bottom": Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship. *Human Rights Watch* 18(8C). Available at <http://www.hrw.org/en/news/2006/08/08/china-internet-companies-aid-censorship>.
- Hunt, Paul. 2005. Right of Everyone to Enjoyment of the Highest

- Attainable Standard of Physical and Mental Health: Mission to Peru. E/CN.4/2005/51/Add.3.
- . 2007. *Neglected Diseases: A Human Rights Analysis*. Geneva: World Health Organization (WHO).
- Individual Members of the Faculty of Harvard University. 2001. Consensus Statement on Antiretroviral Treatment for AIDS in Poor Countries. Available at http://www.carroll.edu/~mparker/mcm/consensus_aids_therapy.pdf.
- International Council on Human Rights. 2002. *Beyond Voluntarism: Human Rights and the Developing International Legal Obligations of Companies*. Versoix: International Council on Human Rights.
- International Intellectual Property Institute. 2000. Patent Protection and Access to HIV/AIDS Pharmaceuticals in Sub-Saharan Africa. Available at http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/pdf/iipi_hiv.pdf.
- International Law Commission. 1966. *Yearbooks of the International Law Commission Vol. 2*. New York, N.Y.: United Nations Publications.
- Jennings, Robert, and Arthur Watts KCMG QC. Eds. 2008. *Oppenheim's International Law: Volume 1: Peace 19*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
- Joseph, Sarah. 2005. Pharmaceutical Corporations and Access to Drugs: The "Fourth Wave" of Corporate Human Rights Scrutiny. *Human Rights Quarterly* 25:425-452.
- Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Melissa Castan. 2004. *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials And Commentary*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
- Kapcynski, Amy, Samantha Chaifetz, Samantha Chaifetz, and Zachary

- Katz. 2005. Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations. *Berkeley Technology Law Journal* 20:1031-1114.
- Kell, George. 2002. Corporate Citizenship: Exploring the New Responsibilities. RIIA Conference Report.
- Kelley, Glen. 2001. Multilateral Investment Treaties: A Balanced Approach to Multinational Corporations. *Columbia Journal of Transnational Law* 39:483-532.
- Kennedy, Eleanor D. 2001. The International Human Right to Health: What Does This Mean for Our National and World?. *Indiana Law Review* 34:1457-1475.
- Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye, Jr. 2000. Globalization: What's New? What's Not? (and So What?). *Foreign Policy* 118:104-119.
- Kessomboon, Nusaraporn , Jiraporn Limpananont, Vidhaya Kulsomboon, Usawadee Maleewong, Achara Eksaengsri, and Prinya Paothong. 2010. Impact on Access to Medicines from TRIPS-plus: A Case Study of Thai-US FTA. *The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 41(3):667-677.
- Khan, Iren. 2005. Understanding Corporate Complicity: Extending the Notion Beyond Existing Laws. Address at the Business Human Rights Seminar (AI Index POL/34/001/2006). Available at <http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL34/001/2006/en/c866d1a9-d44b-11dd-8743-d305bea2b2c7/pol340012006en.pdf>.
- Khosla, Rajat, and Paul Hunt. 2008. Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relation to Access to Medicines: The Sexual and Reproductive Health Context. Available at http://www.essex.ac.uk/human_rights_centre/research/rth/docs/Final_pharma_for_website.pdf.
- Kinney, Eleanor D. 2010. For Profit Enterprise in Health Care: Can It

- Contribute to Health Reform?. *American Journal of Law & Medicine* 36:405-435.
- Lakdawalla, Darius, and Wesley Yin. 2009. Insurer Bargaining and Negotiated Drug Prices in Medicare Part D, National Bureau of Economic Research (NBER). Working Paper 15330. Available at http://www.nber.org/papers/w15330.pdf?new_window=1.
- Lang, Andrew T. F. 2007. Re-Thinking Trade and Human Rights. *Tulane Journal of International and Comparative Law* 15(2):335-414.
- Lee, Ian. B. 2006. Efficiency and Ethics in the Debate about Shareholder Primacy. *Delaware Journal of Corporate Law* 31:533-587.
- Leiginger, Klaus M. 2005. The Corporate Social Responsibility of the Pharmaceutical Industry: Idealism without Illusion and Realism without Resignation. *Business Ethics Quarterly* 15(4):577-594.
- . 2006. On Corporate Responsibility for Human Rights. Available at <http://www.novartisfoundation.org/platform/apps/Publication/getfmfile.asp?id=612&el=812&se=471187408&doc=46&dse=5>.
- . 2007. Capitalism with a Human Face: The UN Global Compact. *Journal of Corporate Citizenship Issue* 28:113-132.
- . 2009. Corporate Responsibilities for Access to Medicines. *Journal of Business Ethics* 85(1):3-23. Available at <http://www.novartisfoundation.org/platform/apps/Publication/getfmfile.asp?id=612&el=2735&se=124414503&doc=184&dse=5>.
- Lieberman, Samuel S., and Adam Wagstaff. 2009. *Health Financing and Delivery in Vietnam: Looking Forward*. Geneva: World Bank Publications.
- Love, James. 2001. Compulsory Licensing: Models for State Practice in Developing Countries, Access to Medicine and Compliance with the WTO Trips Accord. Available at <http://www.cptech.org/ip/>

health/cl/recommendedstatepractice.html.

Marks, Stephen P. 2009. Access to Essential Medicines as a Component of the Right to Health. Pp. 82-101 in *Realizing the Right to Health*, edited by Andrew Claphan and Mary Robinson. Zurich: Rüfer & Rub.

Matthews, Jon. 2010. Renewing Healthy Competition: Compulsory Licenses and Why Abuses of the TRIPS Article 31 Standards Are Most Damaging to the United States Healthcare Industry. *The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law* 4:119-150.

May, Diane K. 1992. Pharmaceutical Crisis in India: Transcending Profits with Human Rights. *Wisconsin International Law Journal* 10(1):40-77.

Maybarduk, Peter, and Sarah Rimmington. 2009. Compulsory Licenses: A Tool to Improve Global Access to the HPV Vaccine?. *American Journal of Law & Medicine* 35:323-350.

McLeland, Le-Nhung, and J. Herbert O'Toole. 1987. Patent Systems in Less Developed Countries: The Cases of Indian and the Andean Pact Countries. *Journal of Law and Technology* 2:229-248.

Meron, Theodor. 1986. On a Hierarchy of International Human Rights. *American Journal of International Law* 80:1-23.

Meyer, William H. 1996. Human Rights and MNCs: Theory Versus Quantitative Analysis. *Human Rights Quarterly* 18:368-397.

Minority Staff of House of Representatives Committee on Government Reform. 2005. Trade Agreements and Access to Medications under the Bush Administration. Available at <http://www.democrats.reform.house.gov/Documents/20050609094902-11945.pdf>.

Mowery, Lauren A. 2002. Earth Rights, Human Rights: Can International Environmental Human Rights Affect Corporate Accountability?. *Fordham Environmental Law Journal* 13:343-373.

- Muchlinski, Peter T. 2001. Human Rights and Multinationals: Is There a Problem?. *International Law Affairs* 77(1):31-47.
- Narlikar, Amrita. 2005. *The World Trade Organization: A Very Short Introduction*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
- Niëns, Laurens M., Alexandra Cameron, Ellen Van de Poel, Margaret Ewen, Werner B. F. Brouwer, and Richard Laing. 2010. Quantifying the Impoverishing Effects of Purchasing Medicines: A Cross-Country Comparison of the Affordability of Medicines in the Developing World. *Plos Medicine* 7(8):1-8.
- Novogrodsky, Noah. 2009. The Duty of Treatment: Human Rights and The HIV/AIDS Pandemic. *Yale Human Rights & Development Law Journal* 12:1-61.
- Nussbaum, Martha. 1999. Capabilities, Human Rights, and the Universal Declaration Pp. 25-64 in *The Future of International Human Rights*, edited by Burns Weston and Stephen Marks. Ardsley, N.Y.: Transnational Publisher.
- . Capabilities and Human Rights. Pp. 212-240 in *The Philosophy of Human Rights: Readings in Context*, edited by Patrick Hayden. St. Paul, Minn.: Paragon House.
- Nwobike, Justice C. 2006. Pharmaceutical Corporations and Access to Drugs in Developing Countries: The Way Forward. *International Journal on Human Rights* 4:127-143.
- O’Keeffe, Janet. 1994. The Right to Health Care and Health Care Reform. Pp. 33-64 in *Health Care Reform: A Human Rights Approach*, edited by Audrey R. Chapman. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Office of the U.S. Trade Representative. 2007. 2007 Special 301 Report.
- Oriola, Taiwo A. 2009. Strong Medicine: Patents, Market, and Policy Challenges for Managing Neglected Diseases and Affordable

- Prescription Drugs. *Canadian Journal of Law & Technology* 7:57-123.
- Outterson, Kevin. 2008. Should Access to Medicines and TRIPS Flexibilities Be Limited to Specific Diseases?. *American Journal of Law & Medicine* 34:317-338.
- Oxfam. 2001. Cut The Cost: Patent Injustice: How World Trade Rules Threaten the Health and Poor People. Available at <http://www.maketrade-fair.com/en/assets/english/patent.pdf>.
- Pécoul, Bernard, Pierre Chirac, Patrice Trouiller, and Jacques Pinel. 1999. Access to Essential Drugs in Poor Countries: A Lost Battle?. *The Journal of the American Medical Association* 281(4):361-367.
- Petersmann, Ernst-Ulrich. 2004. The Human Rights Approach Advocated by the UN High Commissioner for Human Rights and by the International Labour Organisation: Is It Relevant for WTO Law and Policy. *Journal of International Economic Law* 7:605-627.
- Picciotto, Sol. 1999. Introduction: What Rules for the World's Economy?. Pp. 1-28 in vol. 1 of *Regulating International Business: Beyond Liberalization*, edited by Sol Picciotto and Ruth Mayne. London: Palgrave Macmillan.
- Pillay, Sukanya. 2006. Absence of Justice: Lessons from the Bhopal Union Carbide Disaster for Latin America. *Michigan State Journal of International Law* 14:479-519.
- Pogge, Thomas. 2008. Access to Medicines. *Public Health Ethics* 1(2):73-82.
- . 2009. The Health Impact Fund and Its Justification by Appeal to Human Rights. *Journal of Social Philosophy* 40(4):542-569.
- Press Release. 1999. Secretary General Proposes Global Compact on Human Rights, Labour, Environment, in Address to World Economic Forum in Davos. U.N. Doc. SG/SM/6881 Available at

- <http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.htm>
l.
- . 2003. Médecins Sans Frontières, Drugs for Neglected Diseases Initiative: Teaming up to Address Neglect. Available at <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000343>.
- Puymbroeck, Rudolf Van. 2010. Basic Survival Needs and Access to Medicines – Coming to Grips with TRIPS: Conversion + Calculation. *Journal of Law Medicine & Ethics* 38(3):520-549.
- Ragazzi, Maurizio. 1997. *The Concept of International Obligations Erga Omnes*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
- Rai, Arti K. 2005. Proprietary Rights and Collective Action: The Case of Biotechnology Research with Low Commercial Value. Pp. 288-306 in *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, edited by Keith E. Maskus and Jerome H. Reichman. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ratner, Steven R., and Jason S. Abrams. 2001. *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.
- . 1982. Social Unity and the Primary Goods. Pp. 159-185 in *Utilitarianism and Beyond*, edited by Amartya Sen and Bernard Williams. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 1993. *Political Liberalism*. New York, N.Y.: Columbia University Press.
- . 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.

- Ritter, GERALYN S. 2010. Are Drug Companies Living up to Their Human Rights Responsibilities? The Merck Perspective. *Plos Medicine* 7(9):e1000310 (published online in PLoS Medicine, e1000310. doi:10.1371/journal.pmed.1000310). Available at <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000310>.
- Robinson, Jeffery. 2001. *Prescription Games: Money, Ego and Power inside the Global Pharmaceutical Industry*. Oxford: BMJ Publishing Group.
- Rosebush, Lee H., and Jonathan A. Havens. 2012. Pharmacy Billing: The Importance of Establishing IT Systems and Compliance Policies. *Journal of Health Care Compliance* 14(3):57-58.
- Sachs, Jeffery D. 2008. *Common Wealth: Economics for a Crowded Planet*. New York, N.Y.: Penguin Group.
- Savoie, Brent. 2007. Thailand's Test: Compulsory Licensing in an Era of Epidemiologic Transition. *Virginia Journal of International Law* 48:211-248.
- Scafidi, Susan. 2004. Case Study: RESPONSE: The "Good Old Days" of TRIPS: The U.S. Trade Agenda and the Extension of Pharmaceutical Test Data Protection. *Yale Journal of Health Policy Law & Ethics* 4:341-351.
- Scherer, F. M. 1998. The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals. Address at the AIDE Conference on Pharmaceutical Patents, Innovation and Public Health.
- . 2007. Pharmaceutical Innovation. Working Paper No. RWP07-004. Harvard University JFK School of Government Faculty Research.
- Schoonveld, Ed. 2010. *The Price of Global Health: Drug Pricing Strategies to Balance Patient Access and the Funding of Innovation*.

- Farnham: Gower Publishing Limited.
- Schott, Jeffrey J., Scott C. Bradford, and Thomas Moll. 2006. Negotiating the Korea-United States Free Trade Agreement. Policy Briefs in International Economics. Available at <http://www.iie.com/publications/pb/pb06-4.pdf>.
- Sell, Susan K. 2003. Trade Issues and HIV/AIDS. *Emory International Law Review* 17:933-954.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
- . 2006. Human Rights and Development. Pp. 1-8 in *Development as a human Right: Legal, Political and Economic Dimensions*, edited by Bard Andreassen and Stephen Marks. Morsel: Intersentia Publishing.
- Shaffer, Ellen R., Howard Waitzkin, Joseph Brenner, and Rebeca Jasso-Aguilar. 2005. Global Trade and Public Health. *American Journal of Public Health* 95:23-34.
- Shalev, Carmel. 2005. Access to Essential Drugs, Human Rights and Global Justice. Pp. 93-110 in *Bioethics in a Small World*, edited by Felix Thiele and R. E. Ashcroft. Berlin: Springer.
- Shapiro, Carl. 2000. Navigating the Patent Thicket: Cross-Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. Pp. 119-150 in *Innovation Policy and the Economy*, edited by Adam B. Jaffe, Josh Lerner and Scott Stern. Cambridge, M.A.: MIT Press.
- Shinn, Carolynne. 2000. The Right to the Highest Attainable Standard of Health: Public Health's Opportunity to Reframe a Human Rights Debate in the United States. *Health and Human Rights* 4(1):114-133.
- Simma, Bruno, and Philip Alston. 1989. The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles. *Australian Year*

Book of International Law 12:82-108.

Singh, Kavaljit. n.d. War Profiteering: Anthrax, Drug Transnationals and TRIPs. Available at <http://www.madhyam.org.in/admin/tender/War%20Profiteering%20Anthrax,%20Drug%20Transnationals%20and%20TRIPs.PDF>.

Smith, D. Gordon. 1998. The Shareholder Primacy Norm. *Journal of Corporation Law* 23:277-323.

Social Security Administration. 2012. Medicare. Available at <http://www.ssa.gov/pubs/10043.pdf>.

Spectar, Jem M. 2002. Patent Necessity: Intellectual Property Dilemma in the Biotech Domain and Treatment Equality for Developing Countries. *Houston Journal of International Law* 24:227-278.

Steiner, Henry J., Philip Alston, and Ryan Goodman. 2007. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. New York, N.Y.: Oxford University Press.

Steinhardt, Ralph G., Paul L. Hoffman, and Christopher N. Camponovo. 2009. *International Human Rights Lawyering: Cases and Materials*. St. Paul, Minn.: West Group.

Stephens, Beth. 2002. The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights. *Berkeley Journal of International Law* 20:45-90.

Stich, S. P. 1981. The Many Rights to Health and Health Care. Pp. 15-30 in *Rights and Responsibilities in Modern Medicine*, edited by M. D. Basson. New York, N.Y.: A.R. Liss.

Strange, Susan. 1996. *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sykes, Alan O. 2002. TRIPS, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha "Solution". *Chicago Journal of International Law* 3:47-68.

- Thai Ministry of Public Health & National Health Security Office. 2007. Facts and Evidence on the 10 Burning Issues Related to the Government Use of Patents on Three Patented Essential Drugs in Thailand. Available at <http://www.moph.go.th/hot/White%20Paper%20CL-EN.pdf>.
- The Centre for Applied Legal Studies (CALS). 2003. The Price of Life. Hazel Tau and Others V. Glaxosmithkline and Boehringer Ingelheim: A Report on the Excessive Pricing Complaint to South Africa's Competition Commission 38. Available at http://www.aidslex.org/site_documents/T012E.pdf.
- The Council of Bars and Law Societies of the European Union. 2003. Corporate Social Responsibility and the Role of the Legal Profession: A Guide for European Lawyers Advising on Corporate Social Responsibility Issues. Available at <http://www.advokatsamfundet.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiler%2fCCBE%2fCCBE.CSR.pdf>.
- Timmermans, Karin, and Togi Hutadjulu. 2000. The Trips Agreement and Pharmaceuticals: Report of an ASEAN Workshop on the TRIPS Agreement and Its Impact on Pharmaceuticals. Available at <http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1459e/>.
- Toebe, Brigit. 1999. *The Right to Health as a Human Right in International Law*. Amsterdam: Hart/Intersentia.
- Torres, Mary Ann. 2002. The Human Right to Health, National Courts, and Access to HIV/AIDS Treatment: A Case Study from Venezuela. *Chicago Journal of International Law* 3:105-114.
- Trouiller, Patrice, Piero Olliaro, Els Torreele, James Orbinski, Richard Laing, and Nathan Ford. 2002. Drug Development for Neglected Diseases: A Deficient Market and a Public-Health Policy Failure. *The Lancet* 359:2188-2194.

- Turk, Matthew. 2010. Bargaining and Intellectual Property Treaties: The Case for A Pro-Development Interpretation of TRIPS But Not TRIPS Plus. *N.Y.U. Journal of International Law & Policy* 42:981-1029.
- Twinomugisha, Ben Kiromba. 2008. Implications of the TRIPS Agreement for the Protection of the Right of Access to Medicines in Uganda. *Malawi Law Journal* 2:253-305.
- Tzeutschler, Gregory G. A. 1999. Corporate Violator: The Alien Tort Liability of Transnational Corporations for Human Rights Abuses Abroad. *Columbia Human Rights Law Review* 30:359-419.
- U.N. Commission on Human Rights. 2001. Economic, Social and Cultural Rights: The Impact of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on Human Rights: Report of the High Commissioner. E/CN.4/Sub.2/2001/13. Available at [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/590516104e92e87bc1256aa8004a8191/\\$FILE/G0114345.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/590516104e92e87bc1256aa8004a8191/$FILE/G0114345.pdf).
- U.N. High Commissioner for Human Rights. 2001. Access to Medication in the Context of Pandemics such as HIV/AIDS. E/CN.4/RES/2001/33. Available at http://www.temple.edu/lawschool/drwiltext/docs/UN%20Commission%20on%20Human%20Rights%20Res%202001_22.pdf.
- Uhlmann, Eva M. Kornicker. 1998. State Community Interests, Jus Cogens, and the Protection of the Global Environment: Developing Criteria for Preemptory Norms. *Georgetown International Environmental Law Review* 11:101-135.
- . 2008. Millennium Development Goal 8: Delivering on the Global Partnership for Achieving the Millennium Development Goals: Mdg Gap Task Force Report 2008. Available at

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a54bbf1d.html>.

———. 2011. Millennium Development Goal 8: The Global Partnership for Development: Time to Deliver: MDG Gap Task Force Report 2011. Available at http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2011/mdg8report2011_engw.pdf.

United Nations Development Programme. 2000. *Human Development Report 2000*. New York, N.Y.: Oxford University Press.

United Nations Global Compact. The Ten Principles of the UN Global Compact. Available at <http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/index.html>.

United Nations Millennium Project. 2005. Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. Available at <http://www.unmillenniumproject.org/documents/MainReportComplete-lowres.pdf>.

United States Trade Representative. 2008. 2008 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Available at http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2008/NTE/asset_upload_file_365_14652.pdf.

U.S. Food and Drug Administration. 2002. Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An FTC Study. Available at <http://www.ftc.gov/os/2002/07/genericdrugstudy.pdf>.

Watts, Heather. 2002. International Trade, Generic Drugs and the Developing World. Available at http://www.dww.com/?page_id=1050.

Werhane, Patricia H., and Michael E. Gorman. 2005. Intellectual Property Rights, Access to Life-Enhancing Drugs, and Corporate Moral Responsibilities. Pp. 260-281 in *Ethics and the Pharmaceutical Industry*, edited by Michael A. Santoro and Thomas M. Gorrie. New York, N.Y.: Cambridge University Press.

- Westra, Laura. 2009. Ecological Integrity and Biological Integrity: The Right to Life and the Right to Health in Law. *Transnational Law & Contemporary Problems* 18:3-44.
- Wing, Kenneth R. 1993. The Right to Health Care in the United States. *Annals Health Law* 2:161-193.
- Wojahn, Patrick. 2002. A Conflict of Rights: Intellectual Property under TRIPS, the Right to Health, and AIDS Drugs. *UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs* 6:463-497.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- World Health Organization. 1948. *Primary Health Care*. Geneva: World Health Organization.
- . 1981. *Global Strategy for Health for All by the Year 2000*. Geneva: World Health Organization.
- . 1999. *Progress in Essential Drugs and Medicines Policy 1998-1999*. Geneva: World Health Organization.
- . 2002. *Accelerating Access Initiative: Widening Access and Support for People Living with HIB/AIDS: Progress Report*. Available at http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/isbn9241210125.pdf.
- . 2004. *Equitable Access to Essential Medicines: A Framework for Collective Action*. WHO Policy Perspectives on Medicines No. 8. Available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.4.pdf.
- . 2004. *Medicines Strategy: Countries at the Core 2004-2007*. WHO/EDM/2004.2.
- . 2005. *Accelerating Access - Fact Sheet*. Available at http://www.who.int/hiv/AAI_fs_4Q2005.pdf.
- . 2006. *Public Health: Innovation and Intellectual Property*

Rights. Geneva: World Health Organization.

- . 2002. The Selection of Essential Medicines. WHO Policy Perspectives on Medicine No. 4, WHO Doc. WHO/EDM/2000.4. Available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.2.pdf.
- . 2004. *The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium*. Geneva: World Trade Organization.
- Wouters, Jan, and Leen Chanet. 2008. Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective. *Northwestern University Journal of International Human Rights* 6:262-303.
- Wu, Chuan-Feng. 2007. The Right to Health Care and Health Care Distributive Justice. Unpublished J.S.D. dissertation. University of California Berkeley School of Law.
- . 2012. Transnational Pharmaceutical Corporations' Legal and Moral Human Rights Responsibilities. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 7:77-142.

3. 國際條約與官方文件

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299. Available at http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Competition in the Pharmaceutical Industry: Hearings before the Comm. On Commerce, Science and Transportation of U.S. Senate (2002) (statement of Timothy J. Muris, Chairman of the Federal Trade Commission), available at <http://www.ftc.gov/opa/2002/04/biovail.shtm>. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
Decision of the General Council, Implementation of Paragraph 6 of the
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health,
WT/L/540 (Aug. 30, 2003), 43 I.L.M. 509 (2004).
- Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, 21
U.S.C. 355 (1984).
- Fact Sheet No. 2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights (June
1996), available at <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>. Framework Convention on Tobacco Control,
UN Doc. A56/8. Geneva: WHO, February 27, 2005.
- Free Trade Agreement Between the United States of America and the
Republic of Korea, U.S.-S. Korea, March 15, 2012.
- Human Rights Council, Seventeenth Session, Guiding Principles on
Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework (hereinafter “Guiding
Principles”), UN Doc. A/HRC/17/31 (March 21, 2011).
- Intellectual Property and Human Rights, C.H.R. Res. 2001/21 (August
16, 2001), available at [http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.SUB.2.RES.2001.21.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.2001.21.En?Opendocument). Inter-
-American Convention on the Forced Disappearance of Persons.
- International Conference on Primary Health Care, Declaration of
AlmaAta (1978).
- International Convention on Civil and Political Rights.
- International Covenant on Economic, Social and Culture.
- Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act, Pub.
L. No. 108-173, 117 Stat. 2066 (2003).
- Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, at para. 19, U.N. Doc. A/55/L.2
(Sep. 18, 2000).
- OECD Declaration and Decisions on International Investment and

Multinational Enterprises: Decisions of the OECD Council, OECD DAF/FE/IME (2000) 20 (Nov. 8, 2000).

Programme of Action Against Apartheid, U.N. SCOR, 38th Sess., Supp. for Oct.-Dec. 1983, at 58, 63, U.N. Doc. S/16102 (1983).

Statement of Complaint in Terms of Section 49B(2)(b) of the Competition Act 89 of 1998, Hazel Tau et al. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et al. (Competition Commission of South Africa). Available at <http://www.section27.org.za/wp-content/uploads/2010/10/TauvGSKEvidenceAndLegalSubmissions.pdf>. Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy. 17 I.L.M. 422 (1978) (amended 2000, 2006).

U.N. Economic & Social Council, Sub-Comm'n on the Promotion and Prot. of Human Rights, Fifty-fifth Session, Economic, Social and Cultural Rights: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (Aug. 26, 2003).

U.N. Economic & Social Council Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 1990. General Comment No. 3: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Nature of States Parties Obligations. U.N. Doc. E/1991/23 (Dec. 14, 1990).

U.N. Economic & Social Council Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2000. General Comment No. 14: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Right to the Highest Standard of Health. U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (Aug. 11, 2000).

U.N. Economic & Social Council Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2006. General Comment No. 17: Substantive

Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from Any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author. U.N. Doc. E/C.12/GC/17. (Jan. 12, 2006).

U.N. General Assembly. 2008. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. U.N. Doc. A/63/263 (Aug. 11, 2008).

U.N. Human Rights Council. 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. UN Doc. A/HRC/17/31.

U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. 1996. Fact Sheet No. 2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights. Available at <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>.

World Trade Organization, Ministerial Declaration of 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/2, 41 I.L.M. 755 (2002).

4. 判決

Abigail Alliance for Better Access to Developmental Drugs v. Von Eschenbach, 495 F.3d 695 (D.C. Cir. 2007).

Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corporation, 276 F.3d 1368 (2002).

Autronic AG v. Switzerland, Eur. Ct. H.R. Series A.178 (1990); 12 (1990) E.H.H.R. 485.

Beal v. Doe, 97 S.Ct. 2366 (1977).

Belgium v. Spain, 1970 I.C.J. 3, 1970 (February 5).

- Bowsher v. Merck & Co., 460 U.S. 824 (1983).
- Consumer Education and Research Centre and Others v. Union of India and Others, (1995) S.C.C. (3)42 (India).
- Cruz Bermudez et al. v. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Case No. 15.789, Decision No. 916 (1999) (Venez.).
- Decision No. 916 of the Administrative Law Court of the Supreme Court of Justice of Venezuela, Case No. 15.789 (July 15, 1999).
- Doe v. Unocal, 395 F.3d 978 (2003).
- Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97 (1976).
- Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825 (1994).
- France v. Turkey, 1927 P.C.I.J. (Ser. A) No.10.
- Government of the Republic of South Africa v. Grootboom 2000 (11) BCLR 1169 (CC)(S. Afr.).
- Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976).
- Horizon Health Center v. Felicissimo, 638 A.2d 1260 (N.J. 1994).
- Jacques Chaoulli & George Zeliotis v. Attorney General of Québec & attorney General of Canada, [2005] 1 S.C.R. 791 (Can.).
- Maher v. Roe, 97 S.Ct. 2376 (1977).
- Minister of Health & Professor D. McIntyre No v. New Clicks South Africa (Pty) Ltd & Others 2006 (2) SA 311 (CC) (S. Afr.).
- Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others 2002 (10) BCLR 1033 (CC)(S. Afr.).
- Mova Pharmaceutical Corp. v. Shalala, 140 F.3d 1060 (1998).
- Ngcobo v. Thor Chemicals Holdings Ltd., [1995] T.L.R. 10 (Eng. C.A.);
- Nicaragua V. U.S., 1986 I.C.J.14 (June 27).
- Paschim Banga Khet Mazdoor Samity and Others v. State of West Bengal and Another, A.I.R. 1996 S.C. 2426 (India).
- Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc., 244 F. Supp. 2d

289 (S.D.N.Y. 2003).

Report of the Panel, Thailand – Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes, DS/10/R (Nov. 7, 1990), GATT B.I.S.D. 37S/200 (1990).

Right to Choose v. Byrne, 450 A.2d 925, 936-37 (N.J. 1982).

Soobramoney v. Minister of Health, KwaZulu-Natal 1997 (12) BCLR 1696 (CC)(S. Afr.).

Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692 (2004).

Torpharm, Inc. v. Shalala, 1997 WL 33472411 (D.D.C., 1997).

Valley Drug v. Geneva Pharmaceuticals, 350 F.3d 1181 (2003).

Youngberg v. Romeo, 457 U.S. 307 (1982).